

Arbitraje

Rodrigo Bordachar

20% Trabajo en grupo, 27 de agosto

30% Solemne, 15 de septiembre

50% Examen, 9 de octubre

Ayudante: fvsepulv@uc.cl

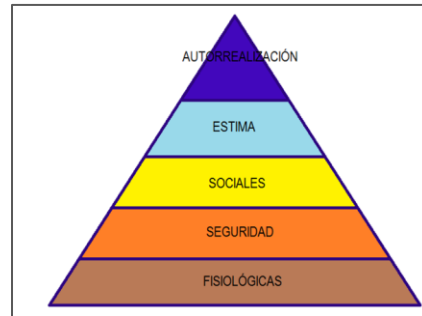
CAPÍTULO I: Introducción a los métodos alternativos de resolución de conflictos

Un conflicto supone un choque de intereses, y en general tienden a ser internos; puede que una de las partes no tenga consciencia del conflicto, sino que sea la otra la que considere que hay un peligro a un bien jurídico propio.

El tema es que el ser humano avanza y la noción del derecho de propiedad implica que nosotros queremos tener algo a costa de otros, lo que es el origen de los conflictos. La vida en sociedad implica conocer las motivaciones personales.

Pirámide de Maslow: Los seres humanos nos movemos a partir de necesidades que se van satisfaciendo.

1. Necesidades fisiológicas (ej. comer).
2. Necesidades de seguridad (ej. cobijarme de la lluvia).
3. Necesidad de amor y pertenencia (ser parte de algo).
4. Necesidad de estima.
5. Realización personal.



1. Métodos “apropiados”¹ de solución de conflictos

a) Auto tutela.

b) Negociación.

c) Mediación. Acá aparece un tercero imparcial que ayuda a las partes a negociar.

d) Conciliación (trámite esencial del juicio ordinario, una vez terminado el período de discusión). A diferencia del mediador, es un juez que entrega a las partes bases de acuerdo que se traducen en propuestas.

e) Tribunales. A diferencia de los métodos alternativos de solución de conflictos, en los juicios o se gana o se pierde.

f) Arbitraje. Ha tendido a ser el mecanismo de solución de controversias a nivel internacional, sobre todo en materias comerciales.

En la contratación internacional se puede aplicar cualquier ley o “Derecho” (por ejemplo, aplicar cuerpos legislativos que no son leyes formales, p.ej acuerdos internacionales tales como los principios UNIDROIT o principios unificados, o aplicar la Lex Mercatorium) a la solución de los conflictos que puedan surgir entre las partes contratantes.

Ahora, si se fija un arbitraje dentro de esta contratación internacional aplicando ley chilena, no necesariamente todos los árbitros tienen que ser chilenos. Si pongo sede en París, puede que ni

¹ Se habla de “apropiado” porque depende de las necesidades del conflicto.

siquiera pisemos esa ciudad porque al definir la sede lo que en realidad se hace es que se aplica la ley de arbitraje de esa sede.

2. Concepto de arbitraje

Jarrosson lo define como una *“institución por medio de la cual un tercero soluciona un diferendo que opone a dos o más partes, en virtud de la misión jurisdiccional que le ha sido confiada por estas”*.

La fuente del arbitraje es justamente la voluntad de las partes, pero ¿el arbitraje existe porque lo reconoce la ley? Mientras menos confianza haya hacia los privados, el arbitraje va a ser menos utilizado o incluso prohibido, a diferencia de lo que sucede en sociedades más libertarias. El profesor cree que no hay materias desvinculadas a los DDFF y el arbitraje sin duda se relaciona con ello porque “no hay libertad sin justicia”, por lo tanto es lógico que yo pueda elegir quién y cómo me juzga.

El arbitraje nace de la libertad y de la propia naturaleza humana, porque emana de mi libertad para decidir quién me juzga. Paradojalmente, cuando en Francia ocurre la Revolución Francesa el arbitraje tiene auge justamente porque los jueces tenían relación directa con la monarquía, entonces había gran desconfianza hacia los jueces.

Otro gran influjo para el arbitraje son los gremios porque ¿quién mejor para solucionar un conflicto que las mismas personas que conocen y ejercen un oficio?

2.1 Elementos del concepto

a) Acuerdo de voluntades. El profesor cree que el arbitraje forzoso no es verdadero arbitraje.

b) Dos o más partes. Eventualmente pueden haber arbitrajes multipartes, y no hablamos de terceros sino más de 2 partes directas.

c) Conflicto

d) Tercero imparcial con misión jurisdiccional, que lo distingue de la mediación y la conciliación. Es decir, conociendo los hechos vamos a calificarlos jurídicamente para dar una solución en derecho o en equidad.

e) Forma no judicial de resolución de controversias. Es decir, los arbitrajes no pertenecen al “sistema judicial” porque aunque nuestra definición de tribunales es amplia, esta es una justicia no judicial.

2.2 ¿Hay un arquetipo arbitral?

Un arquetipo es un modelo.

Hay que tener claro que el arbitraje no es confidencial a menos que las partes así lo pacten. De hecho, el artículo 634 del CPC dice que los expedientes arbitrales se archivan en conjunto con las causas judiciales. Además, los arbitrajes no son solo entre privados, sino que pueden ser entre privados e instituciones del Estado, y cada día hay mayores estándares de transparencia en el ámbito público.

Es muy probable que yo escoja al árbitro por sus **conocimientos acabados** y técnicos sobre algún tema.

Lo que las partes esperan de un árbitro es que este último tenga un **alto nivel de compenetración con el caso**. Esto tanto así que cuando se designa un árbitro no solo se pide declaración sobre independencia sino también de disponibilidad. De hecho, en Chile hay una restricción de 2 años para la solución del conflicto por parte del árbitro, lo que no solo se relaciona con la rapidez sino con la dedicación.

En su relación con las partes, se exige cuidado sobre el conocimiento de las mismas y sus pretensiones. Además, se espera una relación cercana (de fácil acceso al árbitro) sin que eso afecte la independencia del árbitro.

En cuanto al resultado, se espera que la sentencia arbitral sea fundada, coherente y se sustente a sí misma.

Elementos arquetípicos según Jan Paulsson

- a) Individualidad de los arbitrados: que el árbitro conozca a las partes.
- b) Compromiso del árbitro: involucramiento en la causa.
- c) Capacidad de entendimiento de lo debatido (sobre todo conocimiento personal de las materias).
- d) Preocupación por las partes: cercano y amable, pero también distante y autoritario.
- e) Conciencia de las consecuencias de su actuar: el árbitro debe saber que si hace bien o mal su trabajo no pone en riesgo intereses propios, sino derechos de personas. La decisión del árbitro, aunque sea una materia de justicia privada, tiene efectos respecto de toda la sociedad.
- f) Que haya un resultado “condigno”: que el fallo o castigo se merezca o corresponda, que no sea producto de las emociones del árbitro sino que provenga de la justa percepción de las consecuencias apropiadas de la conducta de las partes.

2.3 ¿Es bueno el arbitraje?

No es ni bueno ni malo, sino que ello depende de si es el **método apropiado** para resolver un conflicto o controversia. Es decir, que para el caso concreto sea el método que mejor corresponde.

Por ejemplo, en arrendamientos con cuantías bajas no se justifica el arbitraje, sobre todo porque el árbitro no tiene facultad de imperio entonces va a tener que recurrir a los tribunales ordinarios de justicia.

En sí mismo el arbitraje no es tan caro como se cree comúnmente, porque de todo el costo el tribunal arbitral solo corresponde a un 25%; todo el resto son gastos accesorios que se encuentran también en la justicia ordinaria.

Algunos elementos a considerar

- a) Los métodos heterocompositivos o no adversariales (sin tercero con capacidad dirimente) tienden a minimizar las pérdidas ya sea personales, comerciales, o generales del proceso.

- b) Siempre será mejor llegar a un acuerdo antes que recurrir a una solución adversarial (arbitraje o tribunales).
- c) Un juicio aumenta los costos transaccionales porque es un juego de suma cero²: se gana o pierde todo entonces hay muchos costos.
- d) Para que el arbitraje sea apropiado debe:
 - d.1 Haber igualdad de las partes en el proceso (mismo trato, mismas garantías).
 - d.2 Haber debido proceso; que las partes suficientes oportunidades para exponer sus posturas ante el árbitro. Ahora, lo suficiente va a estar determinado por la ley, y de hecho esto es un elemento muy usado para buscar no ejecutar una sentencia en Chile como argumento para rechazar el exequátur.

2.4 Ventajas o inconvenientes

a) Ventajas

- a.1 Complementa la oferta de acceso a la justicia. Los tribunales ordinarios están atochados en causas, entonces esta es una buena alternativa que aumenta las posibilidades de obtener una solución.
- a.2 Justicia rápida. Si es arbitraje internacional su duración depende de lo que pacten las partes y si es doméstico, son 2 años máximo, además de que los recursos son pocos y renunciables.
- a.3 Conocimientos o competencias técnicas del árbitro.
- a.4 Más baratos.
- a.5 Confidencialidad (salvo algunos casos, como las sociedades que deben informarlo como hecho esencial, y también debe informarse para efectos contables para provisionar resultados del juicio).
- a.6 Evita procesos con excesivo escándalo, manteniendo la discreción de lo que en ellos se ventila.
- a.7 Otras ventajas;
 - a.7.1 Previsibilidad de los costos (sé, ex ante, cuánto me va a costar el juicio).
 - a.7.2 Posibilidad de elección del árbitro.

b) Desventajas

- b.1 El arbitraje vale lo que vale el árbitro: mal árbitro
- b.2 No son baratos porque suponen trámites previos a la jurisdicción ordinaria. Además, puede que alguna de las partes no tenga medios para pagar el árbitro lo que se denomina “impecuniosidad del arbitraje”.
- b.3 No hay solución conciliadora y pacífica (depende de la actitud de las partes).
- b.4 Carecen de imperio por sí mismo. La sentencia tiene capacidad para ser cumplida pero el árbitro no tiene fuerza imperativa.

² Por eso al hacer peticiones concretas, tengo que dejar libertad al juez. Por ejemplo: “solicito que se indemnicen 100 mil pesos, o lo que SS considere ajustado al caso”.

2.5 Clasificación del arbitraje

a) Según la conducción o dirección del procedimiento

a.1 Ad hoc.

a.2 Institucional.

- 1) Son administrados por una institución arbitral (medios técnicos y de control, incluso ético).
- 2) Se someten a un reglamento de dicha institución (sin excepciones, salvo que sean normas expresamente renunciabiles).

a.3 Arbitrajes semi administrados.

b) Según su fuente u origen

b.1 Voluntad: Es lo que se denomina arbitraje voluntario, y su fuente es la voluntad de las partes.

b.2 Ley: En Chile hay arbitrajes forzosos, pero también materias de arbitraje prohibido.

c) Según la manera de resolver la controversia (o las facultades del árbitro)

c.1 Arbitraje de derecho o iuris. El procedimiento y el fallo son conformes a la ley.

c.2 Arbitraje de amigables componedores o árbitros arbitradores. Resuelven en prudencia o equidad, pero eso no significa que puedan fallar conforme a derecho, además de que el procedimiento es libre.

En este caso se puede no comparecer con abogado, por expresa disposición de la ley de comparecencia en juicio (porque no necesariamente se falla conforme a derecho, entonces no hay desigualdad entre una parte que conoce y otra que no conoce el derecho).

c.3 "Arbitraje mixto": Arbitrajes de arbitradores en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo.

En Chile, a juicio del profesor, no hay árbitros mixtos salvo en materia de SPA. En realidad, estamos ante árbitros arbitradores en cuanto al derecho y de derecho en cuanto al fallo.

El árbitro de derecho aplica el procedimiento legal, entonces es una réplica del CPC. Pero ¿en realidad buscaban hacer eso las partes? Es muy importante que para darle flexibilidad al procedimiento hay que darle facultades de arbitrador en cuanto al procedimiento al árbitro.

d) Internacionalidad

d.1 Internos o domésticos.

d.2 Internacionales: pueden ser comerciales o de inversión (entre un inversionista y el Estado que acoge la inversión, siempre que el inversionista sea nacional de un Estado distinto).

e) Sistemas de regulación el arbitraje

e.1 Sistemas dualistas. Chile es dualista porque tenemos el CPC y el COT para materias de arbitraje interno, y hay una ley que regula el arbitraje comercial internacional (ley 19.971).

No porque estén en un mismo instrumento, estamos ante un sistema monista porque por ejemplo Francia regula en el CPC tanto el arbitraje doméstico como el comercial internacional, y lo mismo sucede en Colombia.

e.2 Sistemas monistas. Hay una ley única que se aplica para arbitraje doméstico y arbitraje comercial internacional, pese a que hayan algunas excepciones.

2.6 Arbitraje y nociones vecinas

a) Arbitraje y conciliación o mediación

b) Arbitraje y transacción

c) Arbitraje y peritaje

La gran diferencia es que el perito no tiene una misión jurisdiccional porque el experto, cuando da una opinión, esa opinión es técnica y no supone calificación de los hechos que se ponen a su conocimiento.

Por ejemplo, en relación a la CV el artículo 1809, la norma manifiesta que la determinación del precio puede dejarse al “arbitrio” de un tercero (incluso, la norma francesa original hablaba de “arbitraje”). Pero, ¿es esto arbitraje? No, en realidad acá habría una especie de mandato a este tercero, pero lo más importante es que no hay una misión jurisdiccional.

3. Instituciones arbitrales de networking

Son instituciones que reúnen a personas interesadas en el ámbito del arbitraje, y se centran especialmente en jóvenes.

a) Santiago Very Young (menores de 40 y estudiantes).

b) Arbitraje alumni.

c) Arbitral woman (y Young arbitral woman partitioners, para menores de 40 años).

d) Woman way in arbitration.

e) ICCYAF (Cámara de Comercio Internacional, que tiene una sección para gente joven).

CAPÍTULO II: Fuentes de arbitraje, el acuerdo de arbitraje

1. Fuentes de arbitraje

En Chile hay dos fuentes principales del arbitraje:

a) La ley, para los arbitrajes forzosos.

En el mundo en general no hay arbitraje forzoso. El problema es que el arbitraje es una solución obligatoria para solucionar ciertos conflictos para “desahogar” los tribunales lo que es una mala política, porque eso genera que hayan normas inconstitucionales porque como el arbitraje es caro entonces no todos pueden acceder a la justicia.

El artículo 227 del COT establece casos de arbitraje forzoso, pero también hay otros casos (como los conflictos entre asociaciones de canalistas, derecho marítimo, propiedad intelectual para conflictos referidos a derechos colectivos).

Se genera un incentivo perverso porque cuando tenemos gente que no tiene recursos, se usa que el árbitro percibe el 10% de la masa en casos de particiones. Supongamos que la persona solo se puede eventualmente adjudicar una casa porque la masa hereditaria no es líquida, entonces en ese caso es normal que los árbitros hagan maniobras para asegurar poder pagarse (ej. el árbitro va a querer rematar la propiedad).

b) La voluntad.

¿Por qué voluntad y no consentimiento? Por que por ejemplo, podría haber un arbitraje testamentario entonces el origen del arbitraje es la voluntad unilateral del testador y lo mismo sucede con la “estipulación a favor de otro”.

La voluntad se manifiesta a través de un *acuerdo de arbitraje* (cláusulas arbitrales: cláusula compromisoria o compromiso arbitral).

1. **Cláusula compromisoria.** En Chile, es la que obliga a las partes a concurrir a la justicia arbitral para la resolución de un conflicto.
2. **Compromiso arbitral.** La diferencia con la cláusula, es que acá sí se nombra quién es el árbitro. Si el árbitro no acepta, entonces en ese caso necesariamente las partes tienen que concurrir a la justicia ordinaria. No es tan importante la forma de redacción, sino los efectos del acuerdo. P.ej si nombro muchas personas y todas estas faltan y no manifiesto que a falta de ellas la CAM nombra el árbitro, vuelvo a la justicia ordinaria salvo que haya un nuevo acuerdo.
3. **Contrato de compromisorio.** No es verdaderamente un acuerdo de arbitraje porque *es el contrato que liga a las partes con el árbitro (compromisario)* porque nadie está obligado a ser árbitro, pero si este acepta entonces con ese consentimiento se perfecciona el contrato y nacen sus obligaciones. En este caso si no se dicta sentencia, habría responsabilidad del árbitro porque la obligación del árbitro es resolver el conflicto y las de las partes principalmente el pago de honorarios.

Lo que entendemos en Chile como compromiso y cláusula compromisoria es distinto a lo que se entiende internacionalmente. Cuando hablamos en derecho comparado de cláusula compromisoria estamos ante un acuerdo de voluntades por el cual los contratantes someten el conocimiento del asunto a la justicia arbitral (hay un conflicto futuro). En cambio, el compromiso arbitral es un acuerdo que se alcanza una vez que el conflicto ya se produce.

Efecto positivo del acuerdo de arbitraje

- a) Someter la disputa ante un tercero imparcial.
- b) Otorgarle a la decisión del tercero un carácter vinculante y obligatorio para las partes. Si se demanda ante tribunal ordinario se puede interponer una excepción de incompetencia pero si no la opongo se prorroga la jurisprudencia. Ahora, si no hay acuerdo de arbitraje y se demanda ante un árbitro ahí hay acuerdo tácito de arbitraje si se contesta la demanda.

Ojo que concurrir a la justicia civil (ej. para una cautelar), eso no supone renuncia al arbitraje.

Efecto negativo del acuerdo de arbitraje

- a) Excluir la participación de los órganos jurisdiccionales del Estado.

1.1 Acuerdo de arbitraje en derecho comparado

A priori, hay que tener claro que la UNCITRAL establece al respecto una ley modelo (propuesta normativa con mínimos comunes aceptables).

a) Francia

Tiene un sistema dualista, pero las definiciones del acuerdo de arbitraje son comunes:

“El convenio arbitral adopta la forma de cláusula compromisoria o compromiso”.

La cláusula compromisoria es la convención en virtud de la cual las partes en uno o varios contratos convienen en someter a arbitraje las controversias que pudieran surgir entre ellos.

El compromiso es la convención en virtud de la cual las partes de una controversia existente, deciden someterla a arbitraje.

b) Colombia

Ley 1563/2012

Su nueva ley de arbitraje (dualista) incluye una doble definición del acuerdo de arbitraje, dependiendo de si es doméstico o internacional:

b.1 Doméstico (art 3): *“el pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud del cual las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. El pacto arbitral implica la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante los jueces.- El pacto arbitral puede consistir en un compromiso o en una cláusula compromisoria”.*

b.2 Internacional (art 69): *“el “acuerdo de arbitraje” es aquel por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas o algunas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria o la de un acuerdo independiente”.*

c) Brasil

Es un caso interesante porque no ha suscrito el convenio CIADI (se dan garantías a los inversionistas extranjeros), pero dictaron en el 96 una ley de arbitraje que terminó de revisarse el año 2000, y el tema es que todo se transforma en arbitraje comercial.

En un arbitraje de inversión demandando al estado por no cumplimiento de tratados de inversión, o que se realizaron políticas que afectan las inversiones. entonces si bien este país no se sujeta a las reglas del CIADI, sí puedo dirigirme en contra del Estado. Al final, los tratados multilaterales o

bilaterales de inversión suponen una oferta entre Estados en que no participa el inversionista. Pero se permite acceder a foros internacionales de arbitraje, que son más caros.

Ley 9.307/96

- **Art 4:** la cláusula compromisoria es un acuerdo por el cual las partes contratantes convienen en someter a arbitraje a todas las controversias que puedan surgir con respecto a ese contrato
- La cláusula compromisoria deberá constar por escrito y puede ser insertada en el contrato o documento a que se refiere.
- En los contratos de adhesión, la cláusula solo será eficaz si el adherente toma la iniciativa para instruir el arbitraje o acuerda expresamente, adoptarlo, por escrito, en documento adjunto o en negrita, con una firma o aval especialmente para esa cláusula.
- **Art 9:** el compromiso arbitral es un acuerdo por el cual las partes someten una controversia al arbitraje de una o más personas, pudiendo ser judicial o extrajudicial [...]

La cláusula compromisoria es una suerte de promesa porque puedo demandar a mi contraparte a suscribir un compromiso y si no lo hace, el juez puede hacerlo en su nombre.

d) Perú

Hay posibilidad de llevar arbitraje materias extracontractuales.

Ley de arbitraje peruana, decreto legislativo N° 1071/2008

Artículo 13.- contenido y forma del convenio arbitral. 1. El convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza. (...)

1.2 Acuerdo de arbitraje en Chile

Tenemos una legislación de origen indiano. Además, tenemos un sistema dualista.

Ni el COT ni el CPC definen el acuerdo de arbitraje, y solo en el COT se reconocen los requisitos del compromiso. Solo se hacen referencia en algunos textos al “compromiso” pero no se habla de “cláusula compromisoria”.

El artículo 7.1 de la LACI (ley de arbitraje comercial internacional) manifiesta que: *“El "acuerdo de arbitraje" es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente”.*

Hay que tener claro que el artículo 7 de la ley modelo de UNCITRAL establece dos opciones de definición de acuerdo de arbitraje. Nosotros adoptamos el artículo 7 opción primera por eso es importante determinar dónde va a ser el arbitraje, porque no basta con decir que ese país se

somete a la ley modelo, en tanto, por ejemplo, una de las opciones de esta ley requiere de acuerdo por escrito.

1.2.1 Formas que puede adoptar un acuerdo de arbitraje

Puede incorporarse como (i) una cláusula de un contrato o como (ii) un acuerdo separado. Esta división formal determina dos formas generales de acuerdo de arbitraje.

- **Clausula compromisoria:** somete a arbitraje litigios futuros. Se determina en todo caso, las materias (objeto) sobre los cuales recurrirá el arbitraje.
- **Compromiso:** somete el arbitraje a litigios actuales, que son conocidos de las partes. El objeto del arbitraje será resolver esas determinadas disputas.

Pero en Chile aunque reconocemos ambas formas de acuerdos de arbitraje, sus alcances y efectos distintos.

- Clausula compromisoria (P. Aylwin, *el juicio arbitral*): “es un **contrato** por el cual las partes **sustraen** determinados asuntos litigiosos, **presentes o futuros**, al conocimiento de las jurisdicciones ordinarias y las **someten a juicio arbitral**”.
- Compromiso (P. Aylwin, *el juicio arbitral*): “es una **convención** por la cual las partes **sustraen** determinados asuntos litigiosos, **presentes o futuros**, al conocimiento de las jurisdicciones ordinarias y las **someten al fallo de ciertos árbitros que designan**”.

1.2.2 Efectos del compromiso y la cláusula compromisoria según la ley chilena

Puede nombrarse a uno o varios árbitros, pero es importante que estén todos identificados. Nombrado que sea el árbitro, el efecto de ello es si nos mantenemos o no en el ámbito del arbitraje.

Por ejemplo, una SA es una sociedad de capital entonces nombrar un árbitro está prohibido porque no puede ser que el árbitro dure menos que la sociedad.

“En nuestra legislación la circunstancia decisiva para distinguir la exacta naturaleza jurídica del compromiso y de la cláusula compromisoria debe buscarse en la voluntad de las partes contratantes: si la intención de estas fue sustraer definitiva y permanentemente del conocimiento de la justicia ordinaria determinados conflictos, obligándose a entregar su decisión al fallo de árbitros, se tratara de una clausula compromisoria; y por el contrario, si la voluntad de las partes fue solo la de proceder al nombramiento de un árbitro, que deberá resolver las cuestiones concretas que se sometan a su decisión, se tratara de un compromiso arbitral” (CA Santiago, 26 de enero 1982).

- **Compromiso** designa determinados árbitros, que, si faltan, queda sin efecto; **clausula compromisoria** obliga a llevar a arbitraje todos los asuntos.
- si el árbitro designado en el **compromiso** no acepta, fallece o renuncia antes de la sentencia, vuelve jurisdicción ordinaria; **clausula compromisoria** obliga a las partes o a la justicia a designar un nuevo árbitro.

- El **compromiso** no es un acto *in tuito personae*, pero se ha hecho en atención a la persona del árbitro designado; en la **cláusula compromisoria** no hay tal carácter, y se lleva a arbitraje a cualquiera sea el individuo que se designe como árbitro.

El compromiso no es necesariamente *intuitu personae* porque para serlo, se tiene que celebrar en consideración de la contraparte. Pero en realidad el árbitro es una especie de objeto del contrato.

1.2.3 Efectos necesarios de todo arbitraje para que sea ejecutable

(La cláusula es patológica cuando no se cumplen estos efectos)

1. Que produzca efectos obligatorios para las partes, para lo que se usan formas verbales imperativas (ej. las partes deberán, u otras formas imperativas, no puedo poner “podrán”).
2. Impedir la intervención de tribunales estatales.

Podría ser que la cláusula deba ser interpretada por los tribunales (no intervienen en cuanto a la resolución del conflicto en sí mismo), y para evitar esto debo manifestar que cualquier problema de la cláusula o de su jurisdicción/competencia deba conocerlo el mismo árbitro (principio *competence competence*).

En USA existen los *gateway issues* porque a pesar de que se reconoce el principio “*competence competence*”, si se pone en duda el consentimiento entonces ahí la validez de la cláusula debe ser resuelta por tribunales ordinarios.

3. Dar a el o los árbitros poder para resolver el litigio (de manera definitiva)
4. Permitir la organización de un procedimiento que conduzca en las mejores condiciones a un laudo.

Por ejemplo, hay cláusulas que permiten impugnar un laudo pero en realidad eso es perjudicial para el procedimiento en sí mismo.

1.2.3 Obligaciones que derivan del acuerdo de arbitraje

- a) Obligación de hacer: someter el conflicto al conocimiento de un árbitro y ejecutar lo resuelto por el árbitro.
- b) Obligación de no hacer: no recurrir a la justicia ordinaria y eventualmente no imponer recursos si se han renunciado.
- c) Obligación de dar: remuneración del árbitro (pago de honorarios).

1.2.4 Requisitos del acuerdo

*Recordemos que en arbitraje internacional acuerdo de arbitraje incluye tanto la cláusula como el compromiso. Además, acá cuando hablamos de “arbitraje de derecho” en realidad es un árbitro mixto (procedimiento que determinan las partes y a falta de ello el procedimiento que determine el juez, pero falla conforme a derecho).

REQUISITOS DEL ACUERDO DE ARBITRAJE (LEY CHILENA)

	Compromiso arbitral (art. 234 COT) (*) De faltar no vale el compromiso	Cláusula compromisoria (sin regulación expresa)	Acuerdo de arbitraje (Art. 7 Ley N.° 19.971)
Formales	Debe constar por escrito (solemnidad <i>ad probationem</i>)	Debe constar por escrito	Debe constar por escrito (qué se entiende por "escrito") en el mismo contrato o en un acuerdo independiente.
Partes vinculadas	Expresar el nombre y apellido de las partes litigantes (N.° 1.°) *	Nota: El acuerdo de arbitraje sólo vincula a las "partes" que consintieron en él. En doctrina arbitral se entiende por parte quienes consintieron en el acuerdo, independiente de si "firmaron" el contrato.	
Árbitro	Expresar el nombre y apellido del árbitro nombrado (N.° 2.°) *	No se nombra al árbitro en la cláusula	No se nombra al árbitro en la cláusula compromisoria. Eventualmente en un compromiso, con el conflicto ya surgido, podría nombrarse.
Objeto	Expresar el asunto sometido a juicio arbitral (N.° 3.°) *	Debe tener un objeto determinado o determinable (materias sometidas a arbitraje)	Las controversias que hayan surgido o puedan surgir de una determinada relación jurídica.
Facultades	Expresar las facultades del árbitro (N.° 4.°). Si nada se dice, será árbitro de derecho (excepciones puntuales)	Si nada se dice será árbitro de derecho (excepciones puntuales)	Únicamente puede ser de equidad (<i>ex aequo et bono</i>) si se estipula expresamente.
Lugar y plazo	Expresar el lugar y tiempo para desempeñar funciones (N.° 4.°). Si nada se dice, será en el lugar del compromiso o 2 años	Expresar el lugar y tiempo para desempeñar funciones (N.° 4.°). Si nada se dice, será en el lugar del compromiso o 2 años	Si nada se dice, lo podrían determinar los árbitros. Limitaciones de tiempo dependerán del acuerdo de las partes o del reglamento.

1.2.5 Extinción del acuerdo

EXTINCIÓN DEL ACUERDO DE ARBITRAJE

Cláusula compromisoria	Compromiso arbitral
▪ Mutuo acuerdo	▪ Mutuo acuerdo
▪ Sentencia	▪ Sentencia
▪ Transacción	▪ Transacción
▪ Declaración de nulidad de la cláusula	▪ Declaración de nulidad del compromiso
▪ Falta de objeto litigioso sobreviniente (destrucción de la cosa)	▪ Falta de objeto litigioso sobreviniente (destrucción de la cosa)
▪ Liquidación concursal	▪ Liquidación concursal
	▪ Discordia entre árbitros (árbitros pares)
	▪ Expiración del plazo
	▪ Negativa, incapacidad, recusación, implicancia o fallecimiento del árbitro designado

*La discordia entre árbitros se explica porque pueden haber árbitros pares en nuestro país. Se pone fin al compromiso y no a la cláusula porque si no hay tercero en discordia, se pueden designar nuevos árbitros.

1.2.6 Término del acuerdo arbitral por liquidación concursal

I. Primera aproximación:

1. Los procedimientos concursales son materias de orden público (económico) y el arbitraje debería excluirse de este tipo de procedimientos. No es un absoluto.

Se ha dicho que son una materia de OP y que debiese estar excluida de la autonomía de la voluntad; hay una protección del sistema económico y la igualdad entre acreedores. Por eso se consideraba una materia “inarbitrable”. Esto ha evolucionado y por eso hoy en día se permite incorporar ciertas materias “arbitrables”.

2. En cuanto a sus efectos en el arbitraje, se debe distinguir entre:

- a. Procesos arbitrales no iniciados (contratos con cláusula arbitral pero no se ha trabado la Litis).
- b. Juicios arbitrales en curso
- c. Casos de arbitraje forzoso y Arbitrajes concursales.

II. Efectos de los procedimientos concursales de la ley n.º 20.720 sobre los acuerdos de arbitraje

a) Efectos del Procedimiento de reorganización concursal en el acuerdo de arbitraje.

- El deudor acuerda con sus acreedores el manejo de sus pasivos.
- Se llega a acuerdos de reorganización concursal.
- Art. 68 Ley 20.720 permite incorporar un acuerdo de arbitraje entre el Deudor y uno o más acreedores o entre éstos, con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento, terminación o declaración de incumplimiento del Acuerdo, se someterán a arbitraje. Éste será obligatorio para todos los acreedores a los que afecte el referido Acuerdo.
- Si el árbitro declara la terminación o el incumplimiento del Acuerdo, remitirá de inmediato el expediente al tribunal competente para que éste dicte la Resolución de Liquidación en conformidad a esta ley.

El procedimiento de reorganización busca que la empresa continúe funcionando mediante la renegociación de los pasivos a cargo del veedor. Antiguamente, la ley de quiebras manifestaba que en los convenios con los acreedores, los casos de disputa los conflictos “se pueden o deben someter a arbitraje”. La nueva ley 20.720 mantiene la posibilidad de pactar convenios que incluyan acuerdos de arbitraje pero de forma imperativa.

b) Efectos del Procedimiento de liquidación concursal en el acuerdo de arbitraje

- Los procedimientos de liquidación concursal se llevan ante un juez civil.
- Regla general: acumulación (Art. 142): “Todos los juicios civiles pendientes contra el Deudor ante otros tribunales se acumularán al Procedimiento Concursal de Liquidación. Los que se inicien con posterioridad a la notificación de la Resolución de Liquidación se promoverán ante el tribunal que esté conociendo del Procedimiento Concursal de Liquidación. Los juicios civiles acumulados al Procedimiento Concursal de Liquidación

seguirán tramitándose con arreglo al procedimiento que corresponda según su naturaleza, hasta que quede ejecutoriada la sentencia definitiva”.

- Excepción (Art. 143): Juicios actualmente conocidos por árbitros, arbitrajes forzosos, aquellos sometidos por ley a tribunales especiales.

En la liquidación concursal se busca terminar con las actividades de la empresa. Todos los procedimientos que se inicien respecto del deudor se tienen que acumular al procedimiento concursal, salvo el caso de juicios arbitrales siendo conocidos actualmente por árbitros: el juicio arbitral sigue viéndose por el árbitro una vez trabada la Litis, y lo mismo en el caso de arbitrajes forzosos o conflictos sometidos a procedimientos especiales.

III. Arbitraje concursal en la ley 20.720

- 1) Se regula en la Ley N.º 20.720, artículos 295 y ss.
- 2) Es una forma especial de resolución de conflictos en el concurso.
- 3) Procedimientos concursales de reorganización y liquidación son arbitrables (art. 295 inc. 1.º).
- 4) Pueden ser designados árbitros (titular y suplente), aquéllos inscritos en el Nómina de Árbitros Concursales.
- 5) Reemplazo:
 - 5.1) Acuerdo de acreedores, en procedimiento de liquidación.
 - 5.2) Acuerdo de acreedores y consentimiento de deudor, en procedimiento concursal de reorganización

Hay un procedimiento especial con árbitros especiales que van a tramitar el procedimiento concursal. Es un típico caso en que el legislador saca de la justicia estatal un conflicto para desahogar los tribunales.

La esencia de un procedimiento de liquidación concursal es que los recursos son limitados, entonces, ¿por qué recurrir al arbitraje que tiene costos? Esto es un gran problema, y de hecho después de la dictación de la ley 20.720 no hubo en realidad casos de arbitraje concursal.

La ley, al menos en teoría, permite someter el conocimiento de estos asuntos a un árbitro siempre que esté en la nómina de árbitros concursales que tiene que cumplir con ciertos requisitos (10 años de ejercicio profesional y haber cursado una capacitación ante la súper).

IV. Requisitos para optar al arbitraje concursal en la ley 20.720

- a) Arbitraje en procedimiento concursal de reorganización
 - Petición del deudor, al tribunal competente.
 - Cartas de apoyo de acreedores que representen la mayoría absoluta del pasivo.
 - Debe indicar nombre de los árbitros titular y suplente designados por los acreedores y sus honorarios.
- b) Arbitraje en procedimiento concursal de liquidación

- La junta constitutiva u otra posterior pueden acordar someterse a arbitraje.
- Quórum especial: 2/3 del pasivo con derecho a voto verificado y/o reconocido.
- Deben designar árbitro titular y suplente y fijar sus honorarios.

V. Procedimiento de arbitraje concursal

a) Naturaleza del arbitraje (art. 296)

- a.1 Árbitro de derecho.
- a.2 Tribunal unipersonal.

b) Constitución del arbitraje:

- b.1 Acepta y jura ante el secretario del tribunal competente.
- b.2 Fija domicilio en el territorio jurisdiccional del tribunal.

c) Secretario del tribunal arbitral.

d) Competencia: todo cuanto sea necesario para tramitación de los procedimientos de reorganización o liquidación e incidentes derivados.

e) Fin de la competencia: En el caso del rechazo del acuerdo de reorganización, el árbitro remite el expediente al tribunal competente.

VI. Árbitros concursales

a) Nómina de árbitros concursales.

b) Requisitos:

- b.1) Abogados con experiencia no inferior a 10 años de ejercicio.
- b.2) Cargo incompatible con el de veedor o liquidador.

c) Capacitación.

d) Nómina administrada por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

e) Facultades especiales del árbitro concursal (art. 298).

- e.1) Medios probatorios.
- e.2) Aprueba la prueba de acuerdo con las normas de la sana crítica y deberá consignar los fundamentos de dicha apreciación.

CAPÍTULO III: Separabilidad y eficacia del acuerdo arbitral

El acuerdo arbitral tiene un origen voluntario pero tiene efectos jurisdiccionales (el árbitro cumple con una función jurisdiccional). Y en ese sentido, la mayoría de los asuntos en materia de arbitraje la entrega la doctrina arbitral.

1. Efectos del contrato en el acuerdo de arbitraje

- Regla general en materia contractual: “Lo accesorio sigue la suerte de lo principal”. El acuerdo de arbitraje suele incorporarse como cláusula en un contrato.
- Se declara la resolución de un contrato (contenía un acuerdo de arbitraje) mediante sentencia arbitral: ¿podrían someterse nuevamente a arbitraje cuestiones derivadas (y no demandadas) entre las partes por ese contrato resuelto?
- ¿Puede subsistir el acuerdo de arbitraje a la nulidad del contrato en que va inserta?

Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, entonces si un contrato es nulo todas sus cláusulas lo son. Si le permitimos por cláusula a un árbitro conocer de la validez de un contrato, ¿no es eso contradictorio si esa cláusula también sería nula?

Imaginemos que somos árbitros y nos piden declarar la nulidad del contrato; él árbitro al redactar el fallo va “desapareciendo” hasta que las partes firman en que el árbitro ya no existe porque su jurisdicción emana del acuerdo de arbitraje.

Imaginemos ahora el caso en que un árbitro declara la resolución de un contrato. Respecto del contrato resuelto, si no se pidió en sede arbitral la indemnización de los perjuicios, ¿quién es competente para conocerlos? Si el demandante se dirige a los tribunales ordinarios el demandado probablemente opondrá excepción de incompetencia.

Acá se aplican dos principios sumamente relevantes: **el principio de separabilidad y el principio de competence competence.**

1. Principio de separabilidad (o autonomía) del acuerdo de arbitraje.

Principio de separabilidad (o autonomía) del acuerdo de arbitraje: “el acuerdo compromisorio, sea que haya sido concluido separadamente o incluido dentro del acto jurídico de que se trate, presenta siempre —salvo circunstancias excepcionales— una completa autonomía jurídica, excluyendo que pueda encontrarse afectada por la invalidez de dicho acto” (Fallo Gosset de la Corte de Casación francesa, 1963).

Fundamento: La cláusula compromisoria no participa de la ejecución del contrato. Lo que se quiere resaltar es que tiene un “funcionamiento autónomo” del contrato. La separabilidad es una necesidad.

Doble autonomía: del contrato y de la ley.

1. La cláusula es separable del contrato, y los vicios que a éste le afectan pueden no afectarle.
2. En materia internacional: La validez de la cláusula se regirá por la ley del contrato, pero también puede ser que la misma cláusula establezca que ella misma será regida por una ley diferente (técnica del *depeçage* del Derecho int. Privado).

Hay que recordar que la cláusula arbitral puede tener una ley, determinada por las partes, que rijan exclusivamente su validez. Y esto es derivación de la Convención de NY (artículo 5).

Por lo tanto:

En un mismo contrato, hay 2 elementos fundamentales: el documento material y los negocios. En un mismo instrumento pueden haber varios negocios jurídicos p.ej. CV con hipoteca, en que hay una CV, hipoteca y mutuo generalmente, caso en el cual podría eventualmente uno considerar viciada la hipoteca pero no la CV.

Entonces, los vicios de nulidad pueden afectar a ciertos negocios jurídicos y no al resto sin que pierda validez el resto del contrato. Esto sucede en general esto aplica en contratos internacionales que regulan varios negocios.

La cláusula arbitral subsiste a pesar de que el negocio principal está viciado, a menos de que la cláusula está viciada de por sí. Ahora, la cláusula puede estar “separada” del negocio principal pero no es completamente autónoma.

Las cláusulas de designación de ley aplicable también gozan de este principio de separabilidad, porque no podemos hablar de una norma netamente accesorio sino normas que gozan de cierta autonomía. Los vicios del resto del contrato no le afectan a ella misma.

El fundamento de este principio es que esta cláusula no participa de la ejecución propia del contrato y es una modalidad de solución de controversia que no afecta en cómo opera el contrato mismo. Además, si las partes acordaron arbitraje es porque era su intención.

Si el vicio afecta a la cláusula arbitral eso es otro tema. Por ejemplo, si el contrato está suscrito por incapaz no hay duda de si la cláusula es o no válida porque claramente no lo sería. Lo mismo podría suceder si el contrato es válido pero no la cláusula porque la celebra un abogado sin facultades especiales para comprometer.

2. Separabilidad del acuerdo de arbitraje en Chile

El arbitraje doméstico no contiene normas específicas. Sin embargo, los tribunales han reconocido la separabilidad, pero no la competencia del árbitro para resolver sobre su propia competencia.

- CA Stgo., reconoce separabilidad: “El pacto de arbitraje es un contrato autónomo e independiente”, Calzados La Florida Ltda. c/ Calzados Crillón Ltda., 29/05/1980.
- CA Stgo., reconoce separabilidad, pero no kompetenz-kompetenz: “un juez árbitro puede conocer de la demanda en que se pretenda la nulidad de un contrato, no obstante que en una de las cláusulas del mismo se haya acordado someter el conocimiento de las controversias que se susciten con motivo de la validez del mismo a la justicia arbitral. Sin embargo, la conclusión debe ser distinta cuando al menos una de las causas que sustentan la nulidad que se pide sea declarada, tiene su origen precisamente en la estipulación en que se acuerda entregar la solución de los conflictos a la justicia arbitral” (4 de oct. 2017, Rol 3443-2017)

En materia internacional está expresamente regulada:

LACI, Art. 16.1: “El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la nulidad de la cláusula compromisoria”.

3. Principio competence – competence.

Facultad que tienen los árbitros para conocer sobre su propia competencia o jurisdicción.

En el arbitraje doméstico en Chile no se reconoce, mientras que en arbitraje comercial internacional se permite expresamente.

Una manera de poder darle jurisdicción o competencia al árbitro para conocer la existencia o validez del arbitraje, es incorporando esta cláusula. Sin esta mención, es probable que si discutimos en arbitraje doméstico sobre si la cláusula arbitral está viciada, un tribunal civil declare incompetente al árbitro.

Hay un fallo de la CA de Santiago del año 2012 que dice que el árbitro al resolver sobre la nulidad o existencia del acuerdo de arbitraje tiene un interés económico, entonces estaría inhabilitado para pronunciarse, lo que es ridículo.

OJO que cuando en USA se discute sobre la validez del acuerdo de arbitraje, si la discusión es sobre consentimiento el asunto siempre es conocido por tribunales ordinarios.

Durante mucho tiempo sobre todo en Inglaterra el principio de separabilidad no se reconoció mientras el acuerdo de arbitraje no fuera un documento separado, pero con posterioridad la doctrina comienza a reconocer este principio.

4. Ineficacia y cláusulas patológicas

La ineficacia impide la ejecución perfecta del acuerdo de arbitraje, que no es lo mismo que la validez de la cláusula que se relaciona más bien con su existencia.

a) Como todo acuerdo de voluntades, una cláusula de arbitraje podrá adolecer de vicios.

b) Esos vicios no necesariamente serán de nulidad. Podrán ser tales, que impliquen la inejecución del acuerdo de arbitraje.

c) Una cláusula es patológica cuando no cumple alguno de los siguientes funciones fundamentales (F. EISEMANN):

1. Producir efectos obligatorios para las partes;
2. Impedir la intervención de los tribunales estatales;
3. Dar al o a los árbitros el poder para resolver el litigio;
4. Permitir la organización de un procedimiento.

Según Philippe FOUCHARD, una cláusula es patológica cuando de ella “no se puede deducir una voluntad clara y firme de los firmantes de someterse al arbitraje y que, por consecuencia, no se puede aplicar sin un nuevo acuerdo de arbitraje”. **Yves DERAIS** crítica a esta definición: Una cláusula compromisoria patológica supone la existencia de una voluntad de las partes, al momento de su firma, de la voluntad de someter sus litigios futuros y eventuales al arbitraje, pero al mismo tiempo, es ineficaz en razón de una o más deficiencias en su redacción

4.1 ¿Cómo tratar una patología?

En la preparación de un acuerdo de arbitraje es muy importante que haya una conexión entre las distintas áreas de un estudio de abogados. Pero si la cláusula ya es patológica y no produce efectos, ¿qué hacemos?

a) Reglas de interpretación de los contratos.

b) Principios que informan la cuestión:

b.1) Competencia para decidir la cuestión:

b.1.1) Kompetenz-Kompetenz. El árbitro es competente para conocer de su propia competencia o jurisdicción. Esto incluye cuestiones sobre la existencia o validez del acuerdo de arbitraje.

b.1.2) Gateway issues. “El arbitraje es una cuestión contractual, por lo que no puede obligarse a una parte a someter a arbitraje la resolución de una cuestión respecto de la cual no ha consentido en arbitrar” (U.S. Supreme Court, 1960, *United Steelworkers of America v. Warrior & Gulf Nav. Co.*)

b.2) Principio de interpretación pro arbitrii o pro arbitraje. Ante una cláusula que no produce efectos, se prefiere una interpretación que le otorgue efectos.

c) Ley aplicable a la cláusula: Dependerá de si es un arbitraje doméstico o internacional (recordemos que en este último se distinguen *la ley del contrato, de la cláusula o del lugar del arbitraje*).

El problema es que en general uno se da cuenta que la cláusula es patológica cuando ya hay un conflicto entre las partes. Entonces, la herramienta para resolver un conflicto derivado de una mala redacción de un contrato es la interpretación.

Por lo tanto, debemos aplicar las normas de interpretación de contratos aplicable (cc si es arbitraje doméstico, o norma aplicable al caso en el arbitraje comercial internacional). En general hay principios fundamentales de interpretación que se comparten.

4.2 Ejemplos de cláusula patológica

a) Ejemplo número 1. Contrato comercial: (parte chilena y parte británico-rusa):

“DECIMO SEXTO: En caso de existir divergencias en la interpretación del presente contrato, las partes asignan árbitro arbitrador a la persona que designe la Cámara de Comercio de Santiago. Si perdurare el desacuerdo, las partes se someten a los Tribunales de Justicia de Chile y si tal desacuerdo perdurare, las partes se someten a la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales de Comercio”.

En este caso, pareciera ser que no hay efecto obligatorio ni respecto a la cláusula ni a la decisión del árbitro. Además, no se le asigna una función específica al árbitro entonces hay que asumir que se le otorgan facultades jurisdiccionales. Por último, ¿quiénes son los tribunales internacionales de comercio?

Por más que quiera darle efecto útil a esta cláusula, ella se contradice en sí misma. En ese sentido, una cláusula patológica puede no tener cura.

Ojo que el hecho de someterse a la jurisdicción de ciertos tribunales no implica necesariamente contradicción con la cláusula arbitral porque los tribunales ordinarios tienen mucha intervención en el procedimiento, sobre todo antes de que comience el árbitro a conocer el asunto o en relación a cautelares.

b) Ejemplo número 2. Contrato de licencia, parte chilena (Agente), parte costarricense (Empresa).

“NOVENA.- Varios. Se establece que la legislación aplicable para la regulación del presente contrato será la legislación internacional, y se establece que la solución de cualquier conflicto, diferencia o inconveniente se verá primero la mediación entre las partes, de no haber acuerdo se iniciará un proceso arbitral, utilizando la Ley de Arbitraje Comercial Internacional de Costa Rica, con árbitros costarricenses aplicando la ley comercial internacional y en el centro de arbitraje internacional de AMCHAM Costa Rica, dejando siempre como última instancia los tribunales de justicia. La nulidad de alguna de las cláusulas del presente contrato no anula la totalidad del mismo, se procura preservar el contrato para el mantenimiento de la relación, y la eventual subsanación del error. Para notificaciones o comunicados se establece para LA EMPRESA en (dirección física y correo electrónico), para EL AGENTE (dirección física y correo electrónico). Se estima este contrato en la suma de veinticinco mil colones para efectos fiscales”.

c) Ejemplo número 3. Oferta de compra de inmueble.

“OCTAVO: DISCREPANCIAS. Cualquiera duda o dificultad que pueda surgir en la relación entre el proponente y el aceptante de la propuesta, así como entre uno de ellos y los corredores, será resuelta por la Justicia Ordinaria y/o por acuerdo entre las partes, en única instancia y sin forma de juicio por un árbitro arbitrador y amigable componedor, contra cuyo fallo no procederá recurso alguno”

Otros ejemplos de cláusulas (ver doc “ejemplos de cláusulas patológicas”).

OJO que el tema de la patología NO necesariamente supone un vicio de nulidad.

a) Ejemplo 2. Se le dan facultades al centro de arbitraje (que no tiene PJ) para que designe a un árbitro. En este caso concreto, es una cláusula patológica no porque esté mal redactada sino que el problema es que el CAM no tiene personalidad propia, e incluso corresponde a la misma persona de una de las partes (una de las partes es la Cámara de Comercio de Valparaíso); entonces el problema es de independencia de las partes.

b) Ejemplo 3. El problema es que a pesar de determinar arbitraje, las partes se someten a los tribunales que tienen jurisdicción en su domicilio. En un caso en que participó el profesor, de hecho, se dijo que había que preferir lo genérico (tribunales de justicia) antes que arbitraje que es un caso excepcional.

Ahora, otra cosa es que yo determine para qué me someto a los tribunales de justicia. También se considera en ese sentido que los tribunales tienen otros roles como la potestad cautelar o la designación del árbitro, pero por eso la cláusula es patológica porque al final no hay una sola interpretación de la cláusula y no estoy evitando la participación de tribunales ordinarios.

Además, en este caso se considera que el árbitro debe ser elegido por ambas partes pero debe ser “idóneo”, lo que dificulta la elección. Otra cosa es que se dice que el árbitro puede ser PJ, pero esto no es posible. Las PJ como centros de arbitraje estos no resuelven, sino que administran.

c) Ejemplo 4. No hay problema con que se manifieste que la ejecución le corresponda a los árbitros. Es una cláusula enredada pero en realidad ejecutable; lo único que se hace es decidir una sede de ejecución.

d) Ejemplo 5. Es una cláusula “blanca” o abierta. El tema es que la cláusula depende del mismo contrato para ser interpretada.

4.3 Separabilidad, patología y validez del acuerdo de arbitraje

No hay que confundir una patología con vicio de nulidad, porque la primera puede ser un defecto de redacción que no necesariamente la haga nula pero sí inejecutable.

La cláusula es independiente del contrato en que va incluida (principio de separabilidad). Por lo tanto, los vicios del contrato principal no afectan a la cláusula a menos que ella tenga en sí misma vicios de nulidad. En ese sentido:

1) Ya vimos que el acuerdo de arbitraje goza de cierta independencia del contrato en que va incluido, de modo que los vicios de este, no le afectan, a menos que, la misma cláusula tenga defectos que la hagan inejecutable.

2) La cláusula arbitral puede tener defectos en su redacción que la hagan ineficaz o de ejecución imperfecta. Es lo que llamamos clausula patológica. Esa patología no responde necesariamente a un vicio de nulidad.

3) Se dice nulo el negocio jurídico al que le falta algún requisito establecido en la ley para su validez.

4) Siendo el acuerdo de arbitraje un negocio jurídico, este debe cumplir con los requisitos de existencia y validez de todo acto y contrato.

Independiente de la denominación del acuerdo (contrato, convención o mera cláusula), siempre será un negocio jurídico entonces requiere de los requisitos de existencia o validez de cualquier AJ. Si falta algún requisito de validez, el acuerdo es por lo tanto nulo.

Estos requisitos son:

a. Consentimiento exento de vicios.

b. Objeto y causa lícita.

Respecto al objeto, nuestro cc confunde objeto de obligación y de contrato, pero acá nos referimos a las materias que sometemos al arbitraje. Por eso hablamos de “arbitrabilidad”.

c. Solemnidades, en caso que se requieran.

Hay una discusión sobre si la exigencia de un acuerdo arbitral por escrito es un requisito de validez o de prueba. La LACI exige que sea escrito, y el COT dice que el compromiso debe contar por escrito, pero la doctrina mayoritaria cree que la escritura es la vía de prueba, no requisito de validez. Ej. si se graba una conversación que determina un acuerdo de arbitraje, solo basta que se transcriba.

4.3.1 Objeto del acuerdo de arbitraje

Art 1460 del cc. *Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración.*

Doctrina extranjera. **Teoría de la habitabilidad objetiva**, el objeto del contrato se confundiría con las obligaciones que produce.

Necesidad de licitud del objeto. Así se distingue entre:

- a. Arbitrabilidad objetiva: calificación de las materias que pueden ser objeto de arbitraje. En Chile, por ejemplo, todo es arbitrable salvo las materias de arbitraje prohibido y aquellas materias de orden público.
- b. Arbitrabilidad subjetiva: aptitud legal de ciertas personas o entidades para someterse a arbitraje. Tradicionalmente se asocia a la capacidad de un ente público para obligarse en arbitraje

Por lo tanto, esto se mira sobre todo en relación a la capacidad de entes públicos (si se requiere de ley, autorización del parlamento, etc.), más allá de la mera concurrencia del suscriptor. El profesor cree que en realidad lo subjetivo se refiere a la capacidad y no la arbitrabilidad.

4.3.2 Arbitrabilidad

Aquello que es posible de ser arbitrado. Normalmente, lo relacionamos a las materias de libre disposición (transigibles).

Por lo tanto:

1) Aquello que es posible de ser arbitrado

2) Identificación con materias de libre disposición, por tanto, no se puede arbitrar sobre materias prohibidas (art 229-230)

- a. Cuestiones que verse sobre alimentos (futuros).
- b. Cuestiones que versen sobre el derecho de pedir la separación de bienes entre un hombre y una mujer.
- c. Las causas criminales (determinación de responsabilidad penal, no así los efectos civiles del delito o cuasidelito penal).
- d. Causas de policía local (ej. causa de tránsito, no así sus efectos civiles).
- e. Causas que susciten entre un representante legal y su representado. Ahora, es materia de arbitraje forzoso la rendición de cuentas entre representante y representado.

Si soy, por ejemplo, menor incapaz relativa, entonces no quiero que mi representante legal se cree para sí una jurisdicción por eso se explica esta prohibición.

- f. Causas en que debe ser oído el fiscal judicial (informan respecto de ciertas materias relevantes), por ejemplo las causas en que se decide si se otorga o no un exequátur.

3) En caso de que una materia sea a la vez de arbitraje forzoso se preferirá aquello antes de prohibirlo.

4) Lo inarbitrable se suele asociar con el orden público, pero no se agota en ello.

Hay materias de derecho de familia, por ejemplo, que son transigibles porque los padres pueden llegar a un acuerdo (ej. alimentos devengados o cuidado personal), y la única limitación es que ello debe aprobarse por tribunal de familia. Entonces hay una autora -María Fernanda Vázquez- que

dice que si en esa transacción incluyo cláusula arbitral respecto del acuerdo, se transforma en arbitrable algo inarbitrable pero en realidad esto es discutido.

4.3.3 Orden público y arbitrabilidad objetiva

La arbitrabilidad nos lleva a determinar cuándo ciertas materias se pueden o no someter a arbitraje. Si son materias de arbitraje prohibido, la cláusula arbitral sería inválida entonces eso nos lleva a que el procedimiento completo está sujeto a invalidarse por falta de competencia.

Lo que le da competencia al árbitro es el acuerdo de arbitraje (cuando el acuerdo es voluntario), entonces si el acuerdo está viciado la decisión del árbitro emana de un tribunal incompetente. Ahora, en materia internacional lo que procede es el recurso de nulidad.

Todos los derechos son disponibles salvo aquellos que la ley los determine como indisponibles (ej. materia laboral). El límite de la disponibilidad del derecho termina en lo que son las normas de OP.

En general se relaciona lo inarbitrable con el Orden Público (ej. Derecho Penal), pero en realidad no se agota en ello.

En derecho laboral hay materias de arbitraje forzoso. De hecho, la negociación colectiva parte con mediación y sigue con arbitraje. En el arbitraje laboral, el árbitro elige una de las dos opciones presentadas por las partes sin que se puedan mezclar cláusulas entonces las propuestas de las partes son más razonables. Acá la relación ya no es de desequilibrio porque está el sindicato v/s el empleador.

Pero los derechos laborales son irrenunciables y la jurisdicción laboral es parte de los derechos del trabajador, por eso ello corresponde a una materia inarbitrable. Hubo un caso en que se dijo que no importaba el carácter del trabajador (ej. gerente v/s cajero del Jumbo), sino que el principio protector los abarca a todos entonces estas son materias inarbitrales. El tema es lo que ocurre después de que termina la relación laboral, por ejemplo, se pueden resolver las indemnizaciones por la vía del arbitraje.

Normas de orden público

Premisa: no por existir en el asunto materias de OP, se prescindirá de los árbitros en la resolución del conflicto.

Antiguamente ante una norma de OP los árbitros se declaraban incompetentes. Hoy en día se entiende que sí se puede resolver ese asunto en sede de arbitraje, lo que no puede el árbitro es fallar contra la norma de OP.

¿Qué sucede en el caso de árbitros arbitradores? Sabemos que el árbitro arbitrador puede fallar contra ley, pero Philippi dice que también se puede fallar contra una norma de OP por razones de equidad p.ej. antiguamente se distinguía entre hijos legítimos e ilegítimos lo que afectaba en los derechos de sucesión, el árbitro arbitrador podría cambiar esa norma para restablecer la igualdad entre los hijos. Sin embargo, Bordachar cree que esto sería validar un hecho ilícito, entonces el árbitro arbitrador puede fallar contra ley pero no contra una norma de OP.

Algunos ejemplos:

a) Patentes y marcas. Ej. art. 31 y 19 bis Ley de Propiedad Industrial.

Para patentar una invención tengo que cumplir ciertos requisitos, pero lo más importante es que haya una novedad. Esto me va a permitir ser protegido porque el Estado me va a reconocer incluso a nivel internacional para que no me copien, además de que tengo derecho exclusivo y excluyente de explotar esa invención por un cierto plazo.

Entonces, la determinación del cumplimiento de requisito de registrabilidad no puede quedar en manos de un árbitro, pero los derechos derivados de ese registro sí son arbitrables (derivaciones del derecho de propiedad industrial).

Artículo 19.- *Nadie podrá utilizar públicamente una obra del dominio privado sin haber obtenido la autorización expresa del titular del derecho de autor. La infracción de lo dispuesto en este artículo hará incurrir al o los responsables en las sanciones civiles y penales correspondientes.*

Artículo 31.- *Los autores del argumento de la música, de la letra de las canciones, del doblaje y de la obra que, eventualmente, hubiese sido objeto de adaptación cinematográfica, conservan el derecho de utilizar, por separado, sus respectivas contribuciones, siempre que no hayan convenido su uso exclusivo para la producción cinematográfica.*

b) Derechos de autor. Se es autor desde el momento de la creación de la obra, y el Registro solo otorga una presunción simplemente legal de autoridad; es más, hay protección legal aun sin inscripción.

El tema es que la determinación de quién es autor ¿podría ser arbitrable? No porque es un tema que va más allá de los intereses privados y el reconocimiento de un derecho de autor tiene efectos erga omnes, pero sí hay otros elementos sobre los derechos de autor que sí son arbitrables.

Hay un derecho moral de autor y un derecho patrimonial de autor, porque tengo derecho a que se me reconozca como autor de una obra pero también tengo derecho a los efectos patrimoniales que surgen de esa obra. Si JK Rowling cede sus derechos de autor patrimoniales para que se puedan hacer película sus libros, ¿eso es arbitrable? Pareciera lógico que sí.

Entonces el reconocimiento del derecho de autor, siendo norma de OP es inarbitrable, lo que difiere de los efectos patrimoniales que son arbitrables.

c) Libre competencia. Son materias de OP, porque lo que se busca resguardar es al mercado para que no hayan abusos. Ahora, se ha resuelto que hay elementos que sí son arbitrables.

No podría llevar a arbitraje el existir o no un acto contra la libre competencia.

c.1 DL 211, arts. 3 y 26.

Artículo 3º.- *El que ejecute o celebre, individual o colectivamente cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será sancionado con las medidas señaladas en el artículo 26 de la presente ley, sin perjuicio de las medidas preventivas, correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o convenciones puedan disponerse en cada caso.*

Artículo 26º.- La sentencia Ley definitiva será fundada, debiendo enunciar los fundamentos de hecho, de derecho y económicos con arreglo a los cuales se pronuncia. En ella se hará expresa mención de los fundamentos de los votos de minoría, si los hubiere. Esta sentencia deberá dictarse dentro del plazo de cuarenta y cinco días, contado desde que el proceso se encuentre en estado de fallo.

c.2 Caso Thales, CA París 2004.

c.3 Caso SNF v. Cytec, Bruselas/París.

c.4 EEUU, infracciones a la Sherman Act (Mitsubishi Motors Corp v. Soler Chrysler-Plymouth (1985).

d) Arbitraje y corrupción. En un caso de corrupción, lo que el árbitro debería hacer es que el contrato es nulo, aunque no se lo pidan, porque es un acto contra del OP; entonces aplico normas de OP en sede arbitral.

e) Derecho tributario. Hay corriente en Chile a que ciertos puntos puedan ser sometidos a arbitraje.

Caso EEUU, Administrative Dispute Resolution Act 1996 permite resolver por métodos alternativos cuestiones administrativas (incluyendo el arbitraje). En algunos casos se permite arbitrar en materias de doble tributación internacional. Cuestiones comerciales con efectos tributarios.

Análisis del caso Thales

En Europa hay una legislación comunitaria, y es materia de OP la distribución de un mercado. En este caso se celebró un contrato de distribución de un mercado por dos empresas privadas (cartel).

Tratado de la Comisión Europea, art 81 y 82, son considerados como materias de orden publico:

Artículo 81.1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y, en particular, los que consistan en:

a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;

b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;

c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;

d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;

e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.

1) En el fallo arbitral de 2002, el tribunal condeno a Tháles como responsable de incumplimiento del contrato que celebro con Euromissile, pero no declaró los términos de ese contrato como nulos, conforme al artículo 81 del TCE.

Se llevó a arbitraje esta materia y se resuelve a favor de una de las partes el incumplimiento de este contrato. Se condenó a Thales por incumplimiento, pero no se declararon nulos los términos del contrato a pesar de que adolecía de objeto ilícito.

2) Tháles considero ese laudo como contrario al orden publico, por lo que solicito la anulación de este a la CA de Paris.

3) Cuando la CA de Paris reviso el laudo en la anulación, hizo énfasis en que durante el proceso arbitral ni Euromissile ni Tháles habían invocado las normas del TCE para solicitar la nulidad del contrato, pero que sin embargo Tháles lo hacia en la anulación.

Thales recurrió pidiendo la anulación del laudo (recurso que procede respecto de materias contrarias al OP). La Corte da cuenta de que Thales no hizo presente esta situación durante el juicio, entonces surge la duda sobre si el laudo es o no nulo. La Corte considera que no es nulo el laudo porque revisar si el contrato es o no nulo sobrepasaría los límites del recurso de anulación.

4) La CA de París, señalo además, que aunque las disposiciones del contrato pudieren eventualmente ser considerados como contrarias a las normas del TCE, significaría entrar a discutir una materia que requiere un análisis jurídico-económico, que no es propio de un proceso de anulación

Ahora, Bordachar cree que en realidad el laudo es anulable porque la cláusula arbitral se refería a materias inarbitrables por objeto ilícito (el contrato mismo tenía por objeto un acto contra el orden público, que es la creación de un cartel).

Tesis del profesor

Entonces, no por haber una materia de OP en la discusión, esa materia es inarbitrable. Pero el árbitro debe fallar conforme a las normas de OP. Ahora, esto no es un principio absoluto y va a depender de lo que estamos hablando, sobre todo si el tema supone una materia de arbitraje prohibido.

¿Qué pasa si se mezclan materias de OP inarbitrables con materias inarbitrables?

El árbitro solo podría resolver aquellas cuestiones arbitrables, y si hay una norma de OP debe necesariamente aplicarla.

CAPÍTULO IV: Críticas al arbitraje de inversión

El arbitraje, sobre todo de inversión, estaría rodeado de un “halo de misterio”, principalmente porque hay Estados detrás. El arbitraje sería, para sus críticos, una manera en que se podrían cometer fraudes además de que se le entrega soberanía a un privado, a pesar de que un TTII es su origen.

Por esto hay una gran tendencia a que haya un Tribunal Europeo de Inversión permanente, a diferencia de los arbitrajes que se crean para resolver casos concretos.

[VER reportaje “Tribunales de arbitraje: ¿protección de las empresas a costa del Estado?”.](#)

La crítica que hay a este tipo de arbitraje de inversión es que se limita la soberanía interna del Estado porque no podrían dictarse normas, por ejemplo, de energía limpia si hay millones de inversores en carbón. En general, por eso, se falla a favor del inversionista y es excepcional que el Estado demande al inversionista; en general, se trata de asuntos estatales que afectan al inversionista.

Las normas que se usan son normas de DIP (tratados, doctrinas, etc.) principalmente con lo que tiene que ver con la cláusula a favor del más desfavorecido o el estado de necesidad.

Ahora, el halo de secretismo ya está en retroceso porque desde el 2012 se avanza hacia la transparencia. En ese sentido, los reglamentos en general reconocen la confidencialidad, salvo que la ley interna de los Estados no lo permitan.

CAPÍTULO V: Las partes en el arbitraje

“La voluntad como fuente de arbitraje”

No tenemos regulación expresa a esta materia en arbitraje doméstico en Chile, y debemos someternos a las decisiones de los tribunales ordinarios que son bastante formalistas.

Principio base: solo se obligan a recurrir al arbitraje quienes así lo han consentido (de manera expresa o tácita).

En materia civil tenemos los terceros que tienen una pretensión que quieren hacer valer en un juicio (no son partes directas). Como la justicia ordinaria es pública, cualquiera puede intervenir como tercero (si tiene una pretensión), pero como el arbitraje supone consentimiento de las partes, ¿es tan así? Debe haber un consentimiento de las partes que someten el asunto a arbitraje, pero ¿ese tercero debe ser parte del acuerdo? ¿qué efectos puede tener un laudo respecto de terceros?

Acá vamos a tocar temas sobre arbitrajes complejos (arbitrajes multipartes y multicontratos).

1. El concepto de parte

a) En un contrato: quienes concurren con su voluntad para celebrar el contrato.

a.1 Artículo 1545 cc asimila al contratante como parte del contrato. *Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales.*

a.2 El elemento esencial de calificación (para ser parte) es el consentimiento.

b) En un proceso: para ser parte, debo tener una pretensión en juicio (quiero hacer valer un derecho).

b.1 Couture: El concepto de parte es inequívoco en el derecho procesal y denota aquel que pretende algo en juicio, aquel de quién, o contra de quién se pretende algo.

b.2 El elemento esencial es la legitimación (activa o pasiva).

c) En el arbitraje como tal, lo más relevante es que en su origen existe la voluntad de las partes. En cuanto a su función, la decisión del árbitro tiene carácter jurisdiccional; por lo tanto por un lado tenemos el consentimiento de quienes decidieron resolver sus conflictos mediante el arbitraje, además de la legitimidad exigida en cualquier proceso.

Yo puedo transferir un contrato y no necesariamente se cede la calidad de parte dentro del procedimiento arbitral (ej. cesión de derechos, sucesión por causa de muerte). Si me ceden el contrato, ¿accedo también a la cláusula arbitral? Lo importante acá es redactar bien y plasmar lo

que pretenden los clientes, sobre todo sobre el hecho de hasta quiénes afecta el acuerdo de arbitraje.

Entonces volvemos al doble carácter del arbitraje como voluntario su origen y jurisdiccional en sus efectos.

2. Efectos de la calificación de parte

a) Importancia de la calificación en el arbitraje: origen voluntario (contractual) y naturaleza jurisdiccional. Efecto relativo de los contratos.

b) El problema de la legitimación consiste en individualizar a la persona a la cual corresponde el interés para accionar (y, por consiguiente, la acción) y la persona a la cual el mismo corresponde (Liebman)

Si consideramos al arbitraje como convencional o voluntario (una suerte de contrato), tiene efectos relativos y solo obliga a los contratantes. Ahora, tenemos que determinar si hay o no interés de participar en el proceso.

Si se es parte del acuerdo de arbitraje:

- Tendrá efectos procesales relevantes: implicará legitimación activa o pasiva.
- Se generan obligaciones para la parte. Si soy legitimada activa, aunque no haya celebrado directamente el contrato, no puedo recurrir a los tribunales ordinarios u oponer excepción de incompetencia ante el árbitro.
- El resultado de la sentencia le afectará a quien se designe como parte.
- Elemento esencial: determinar la existencia del consentimiento (sea expreso o tácito). Un ejemplo de consentimiento tácito es la prórroga de competencia si me demandan en sede arbitral y no opongo excepción de incompetencia (no es factor de competencia absoluta salvo que sea una materia de arbitraje prohibido o forzoso).

OJO que en materia de SA ya no hablamos de materia de arbitraje forzosa, sino que es un arbitraje por defecto porque siempre el primer demandante va a poder recurrir a tribunales salvo ciertas personas.

3. Partes no signatarias³

Imaginemos que tenemos una empresa extranjera que quiere constituir en nuestro país una SPA que tiene un solo socio con un capital declarado de 100 millones de pesos. Imaginemos también que esa empresa celebra un contrato de distribución de productos en Chile con Bordachar S.A: en ese caso, son partes del contrato la SPA y la SA.

Pero la SPA no es muy atractiva para ser demandada porque su capital es menor a la cuantía de la obligación. Ahora, la matriz de la SPA (extranjera) con la que se negoció originalmente tiene una situación económica espectacular, ¿qué podemos hacer? Tengo que probar 1) consentimiento del

³ https://www.arbitration-icca.org/media/4/80099054862031/media012571271340940park_joining_non-signatories.pdf

acuerdo de arbitraje y 2) legitimación pasiva. ¿Cómo pruebo esto? Podría levantar el velo corporativo pero ahí el peso de la prueba es complejo porque hay que probar la mala fe al momento de constituir la SPA en Chile para cubrir a la matriz.

Como la regla general es el ERC, entonces el tema esencial acá es probar que la matriz es **parte** del ACUERDO de arbitraje (además de ser parte del contrato). **Tengo que encontrar cómo acreditar el consentimiento tácito** de dicha matriz en relación al contrato y al arbitraje.

No solo son partes quienes firmaron sino también quienes manifestaron su consentimiento tácitamente a través de ciertas conductas (ej. puedo demostrar que el negocio en este contrato se llevaba a cabo directamente con la matriz).

3.1 Maneras en que contractualmente un no signatario puede verse afectado por actos de terceros.

- a) Transacciones internacionales y comerciales son cada vez mas complejas.
- b) Grandes proyectos de inversión suponen la participación de diversos actores
- c) Por tanto, pueden verse involucrados (y vinculados) en un eventual conflicto por distintas vías:

c.1) Por transmisión:

- La cláusula arbitral se transfiere a una parte que originalmente no ha firmado el contrato, sustituyéndose a las partes originarias del acuerdo arbitral.
- Puede ser como consecuencia legal o por consentimiento de las partes.

c.2) Por extensión:

- Un no signatario, por distintos medios, ha manifestado su consentimiento para someterse al acuerdo del arbitraje.
- Se mantienen los derechos y obligaciones de los signatarios originales, pero se crean para la parte no signataria nuevos derechos y obligaciones vinculados al convenio arbitral.

3.2 Extensión del acuerdo de arbitraje a partes no signatarias

Sin perjuicio de la distinción antes realizada, en doctrina arbitral, se hablará genéricamente de extensión del acuerdo, significando cualquier incorporación de una parte al arbitraje que no haya sido signataria del mismo, ya como efecto de la transmisión, ya como efecto de la calificación de la extensión, propiamente tal.

Lo que tengo que probar es un consentimiento tácito o expreso a someterse al acuerdo de arbitraje.

3.3 Casos de extensión del acuerdo de arbitraje

- 1) Representación o agencia.
- 2) Beneficiarios de la cláusula y cláusulas de garantía.

- 3) Transferencia de propiedad a título universal o singular. En Francia se dice que las cadenas traslaticias de dominio llevan implícito el acuerdo de arbitraje.
- 4) Estoppel. Debo respetar una conducta previa que le dio a la otra parte la seguridad de que me iba a seguir comportando así en el futuro.
- 5) Incorporación por referencia. El contrato hace referencia a otro contrato en que hay un acuerdo de arbitraje (ej. tenemos un contrato marco y varios contratos chicos, y estos últimos se remiten al contrato marco en cuanto al acuerdo de arbitraje).
- 6) Consentimiento implícito.
- 7) Existencia entre las partes de una comunidad de derechos e intereses.
- 8) Fraude y confusión: alter ego y levantamiento del velo corporativo
- 9) Equidad y buena administración de justicia.
- 10) Cesión del contrato del crédito.
- 11) Mandato.
- 12) Sucesión por causa de muerte: art 1097 y 1394 cc. Es importante recordar que el compromiso no es intuitu persona, entonces no puede el heredero alegar que no le es oponible el acuerdo de arbitraje.
- 13) Garantías, fianza y solidaridad.
- 14) Estipulación a favor de otro y promesa de hecho ajeno arts. 1449 y 1450 cc.

3.4 Incorporación de partes (terceros) no signatarios del acuerdo arbitral

Doctrina del grupo de sociedades: puede afectar al grupo de sociedades o a la persona física controlante del grupo.

a) Caso Dow Chemical c/ISOVER Saint Gobain (Francia 1982): (Dow Chemical, como Sociedad matriz) ejercía el control societario absoluto sobre las sociedades controladas que habían suscrito los contratos pertinentes o que, como en Dow Chemical France, habían participado efectiva e individualmente de su celebración, cumplimiento y extinción.

Acá la matriz demandaba junto con la filial por eso es un tema de legitimación activa no pasiva. El fallo dice que la matriz tenía un control absoluto sobre las sociedades controladas y quien había manejado la relación contractual era la matriz, entonces ella podía actuar como demandante a pesar de no ser signataria del acuerdo. Todo esto dice relación con un tema de buena fe porque la matriz da a entender con su actuar que era la directamente involucrada.

No basta con ser matriz sino que su actuar debe vincularse al acuerdo de arbitraje.

b) **Art 14 LA Peruana:** *El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral o al*

que el convenio esté relacionado. Se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato, según sus términos.

3.5 Las partes en el arbitraje: algunos ejemplos

- 1) Doctrina del levantamiento del velo societario o del alter ego.

Solo seria posible en la medida que el demandado (a quien se acusa de usar un alter ego) utilice una estructura societario con la intencion de evadir normas imperativas o impedir la ejecucion de derechos de una tercera persona.

- 2) Arbitral Estoppel (EEUU)

Equitable estoppel: a party may be estoppel from asserting that the lack of his signature on a written contract precludes enforcement of the contracts arbitration clause when he has consistently maintained that other provisions of the same contract should be enforced to benefit him (caso international Paper c. SchwabedissenMaschinen, 4 circuito, 2000)

Intertwined estoppel: contratos ligados (entrelazados) por referencia entre si, conteniendo uno de ellos la clausula arbitral. Al mismo tiempo, debe haber relacion entre las partes signatarias de unos y otros. Caso First Options of Chicago v. Kaplan, US. Supreme Court, 1995.

CAPÍTULO VI: Arbitraje forzoso

Art. 227 COT. *Deben resolverse por árbitros los asuntos siguientes:*

1°) La liquidación de una sociedad conyugal o de una sociedad colectiva o en comandita civil, y la de las comunidades;

2°) La partición de bienes;

3°) Las cuestiones a que diere lugar la presentación de la cuenta del gerente o del liquidador de las sociedades comerciales y los demás juicios sobre cuentas;

4°) Las diferencias que ocurrieren entre los socios de una sociedad anónima, o de una sociedad colectiva o en comandita comercial, o entre los asociados de una participación, en el caso del artículo 415 del Código de Comercio;

5°) Los demás que determinen las leyes.

Pueden, sin embargo, los interesados resolver por sí mismos estos negocios, si todos ellos tienen la libre disposición de sus bienes y concurren al acto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 802 del Código de Procedimiento Civil.

Los interesados, de común acuerdo, pueden también solicitar al juez que conoce el procedimiento sobre la separación judicial, la declaración de nulidad del matrimonio o el divorcio, que liquide la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales que hubo entre los cónyuges.

Son casos que, al menos para el legislador, provoca resquemor el que se resuelvan en sede pública. Por ejemplo, las particiones de bienes en general proceden respecto de masas hereditarias en que hay relaciones familiares de por medio.

Bordachar no lo considera verdaderamente arbitraje, e incluso podría ser inconstitucional porque se afecta la garantía de acceso a la justicia. Además, en general son casos en que se envuelve un "interés público social".

1. Ley como fuente: materias de arbitraje forzoso

a) Es el impuesto imperativamente por la ley como el único procedimiento para resolver determinados litigios (Alwyn)

b) Fundamento (M.E Ballesteros): evitar a los jueces de letras el trabajo de organizar ciertos pleitos largos y complicados llenos de pequeños incidentes.

Antiguamente era para que se sacara de la esfera de los jueces algunos temas pero porque estos daban desconfianza.

c) Nuestro legislador ha optado en el ultimo tiempo por incorporar mas materias al arbitraje, lo que va en contra de la tendencia internacional.

Somos de los pocos países que aumentan en vez de disminuir los casos de arbitraje forzoso.

1.1 Caso de liquidación de una sociedad o comunidad

“La disolución de una sociedad es la muerte y la liquidación es el entierro”.

La disolución de una sociedad civil forma una comunidad, pero la disolución de una sociedad comercial altera a la sociedad que pasa a estar en liquidación y a estar administrada por un liquidador.

Por lo tanto, este numeral supone casos en que producto de una disolución, se forme una comunidad. Por ejemplo, cuando termina la sociedad conyugal se forma una comunidad de bienes. *OJO. Los bienes adquiridos por al mujer casada en sociedad conyugal con cargo al patrimonio reservado suponen administración libre por parte de la mujer, pero disuelta la sociedad el bien pasa a formar parte de la sociedad conyugal. Los pasivos también entran a esa comunidad.*

a) Sociedad conyugal. Se usan las mismas reglas que en materia de sucesiones.

a.1 Art 1776 cc. Rigen las reglas de partición de comunidades hereditarias y las normas especiales del párrafo 5 del Título XXII

a.2 Reglas especial inciso final 227.

La mujer debe renunciar a los gananciales para quedarse ella con todos sus bienes (lo que conviene si la mujer tiene un patrimonio mayor a lo que se ha ganado).

El inciso final del 227 habla de casos en que se puede recurrir al juez competente, pero ello no ocurre en la práctica, porque hay una mala concepción de que los jueces de familia consideran que no tienen herramientas para liquidar la sociedad conyugal (no pueden determinar si esos son todos los bienes y la liquidación es total, además de que no tienen tiempo ni medios).

b) Sociedad colectiva o en comandita civil.

- Mismo efecto anterior. Disueltas forman una comunidad de bienes.
- También se aplica a las SRL por disposición de la ley 3.918 (la ley no distingue entre sociedades civiles o comerciales).
- Caso especial de sociedades comerciales y SA: participación del liquidador.

En las sociedades comerciales lo que sucede es que procede la liquidación del activo por parte de un liquidador.

c) Comunidades.

- Art 2313 cc
- Asociación o cuenta en participación (art 507 ccom): es un contrato por el cual o dos mas comerciantes toman interés en una o muchas operaciones mercantiles, instantáneas o sucesivas y que debe ejecutar uno de ellos en su nombre y bajo su crédito personal, a cargo de rendir cuenta y dividir sus ganancias o perdidas en la proporción convenida.

La asociación en cuentas de participación se parece a un joint venture y no hay en este caso una personalidad jurídica, pero el profesor cree que se forma una comunidad.

1.2 El caso de la partición

- a) Consiste en la división y repartimiento de una o mas cosas entre los comuneros, es decir, los sujetos que sobre ellas tienen un solo y mismo derecho (Alessandri)
- b) La partición es un acto por el cual se pone fin a la indivisión, liquidando y distribuyendo entre los coparticipes el caudal poseído proindiviso, en proporción a los derechos cuotativos de cada cual (M. Silva Bascañán)
- c) Críticas a su incorporación en otro numeral.
- d) Tiene normas específicas que regulan el juicio de participación (CC y CPC).

Al igual que el caso anterior, supone la distribución de una propiedad común (comunidad): la única diferencia es que antes estábamos, generalmente, ante una universalidad de bienes.

La partición de bienes supone poner fin a la indivisión.

La partición en términos formales no es un juicio porque, de partida, está todo normado en el cc. La labor del partidor en estas materias va a ser decidir casos de conflictos, por ejemplo, respecto de una adjudicación (aunque en estos casos igual todo esta decidido, p.ej si nadie se adjudica el bien se remata).

Hubo un proyecto que se presentó al término de Piñera 1 en que todo el proceso de arbitraje decía de ser jurisdiccional y pasaba a ser administrativo: se hacía una propuesta de partición y se daba lugar a un procedimiento administrativo.

1.3 Rendición de cuentas y juicios de cuentas

- Numeral se divide en dos partes. Moción Fabres en discusión LOT Ley 6.985/41
- Esta disposición no se refiere a la obligación de un juicio de cuentas, sino a las cuestiones que se susciten de él.
- Procedimiento: art 693 y ss del CPC
- Situación a la luz del art 109 del COT, ¿tribunal competente?

Supone dos situaciones distintas: por un lado, la rendición de cuentas que debe hacer el gerente o liquidador de sociedades comerciales, y por otro, los demás juicios sobre cuentas.

¿Cómo se conjuga esto (arts 693 y ss COT) con los artículos 190 COT y 680 CPC?

Art. 680. (838) CPC. *El procedimiento de que trata este Título se aplicará en defecto de otra regla especial a los casos en que la acción deducida requiera, por su naturaleza, tramitación rápida para que sea eficaz.*

Deberá aplicarse, además, a los siguientes casos:

8°. A los juicios en que se persiga únicamente la declaración impuesta por la ley o el contrato, de rendir una cuenta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 696; y

Art. 109 COT. Radicado con arreglo a la ley el conocimiento de un negocio ante tribunal competente, no se alterará esta competencia por causa sobreviniente.

En este caso demando al potencial citado a rendir cuentas para que el tribunal determine si procede o no la rendición. Otra cosa es el problema que pueda suscitarse de la rendición de cuentas, por lo tanto a pesar del artículo 109 del COT (regla de radicación o fijeza), tenemos dos juicios con objetos distintos.

Escenario 1



a) En un juicio sumario se demanda: en este caso pido que se declare la obligación de rendir cuentas y que se fije un plazo para rendirla. Se notifica la demanda y luego se da a lugar a una audiencia de contestación y conciliación. De no haber conciliación, se sigue adelante con el juicio y eventualmente habrá un término probatorio. Finalmente en su sentencia el tribunal debería fijar, a juicio del profesor, un plazo para rendir cuenta además de determinar la procedencia de la rendición de cuentas.

b) Se presenta la cuenta.

c) Si acepto la cuenta o no hago nada, no hay “cuestión” entonces no aplica el 227. Si la observo (no se determina el alcance de esa observación), entonces se entiende que la cuenta presentada es demanda y la observación es la contestación: ahí aparece el juicio de cuentas del 227.

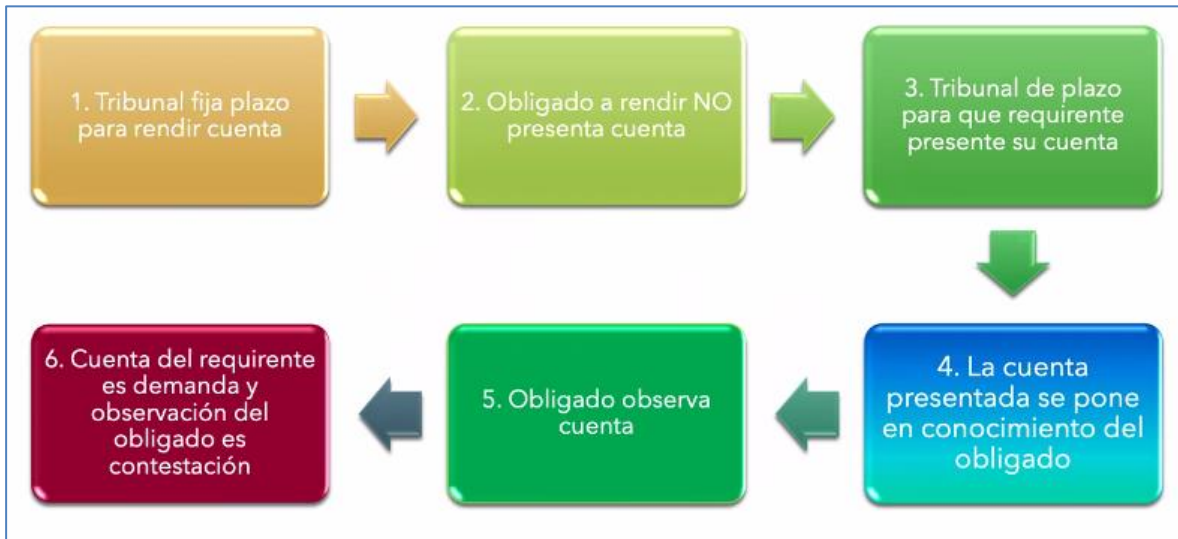
Hasta el punto 4, conoce el tribunal del juicio sumario. Solo en el punto 5, aparece la competencia del árbitro. La palabra claves es “cuestiones” del artículo 227.

¿Qué debiese hacer yo cuando me presentan la cuenta para que la contestación sea completa? Si quiero llegar bien preparada y no hacer una observación meramente genérica, tengo que pedir una prejudicial precautoria de exhibición de libros contables ante el tribunal ordinario que conoció del procedimiento sumario.

¿Qué sucede en el caso de coadministraciones? Supongamos que tenemos 2 socios administradores, pero en la práctica solo uno de ellos administra. Los tribunales han determinado que esto no excluye la obligación de los consocios a rendirle cuentas al otro administrador.

Cuando exijo rendición de cuentas no solo son aspectos contables o administrativos. Cuando me encargan la administración de un negocio también hay una administración de los activos, entonces procede rendición de cuentas sobre el destino y el estado de los bienes. Por lo tanto podemos pedir como precautoria retención de bienes/dinero o secuestro, para que no se dañe la entidad o persona administrada.

Escenario 2: juicio de cuentas



A efectos de la regla de la radicación, vimos que se mantiene la jurisdicción del juez ordinario hasta que existe una observación de la cuenta (porque el artículo 227 habla de “cuestiones”). La observación es una especie de contestación.

Antes vimos qué pasa si efectivamente no hay problemas y se rinden cuentas. ¿Qué pasa si no presenta la cuenta dentro de plazo? Yo tengo que rendir una cuenta alternativa, pero el otro puede hacer observaciones a la cuenta que el requirente formula. La cuenta del requirente es demanda y la observación es la contestación.

Lo importante es que no hay una contradicción del legislador sino que son dos etapas procesales distintas. Tenemos un **primer procedimiento** de determinación de la obligación de rendir cuenta en virtud del cual el tribunal determina si hay obligación de rendir cuenta y se fija un plazo para rendirla, **y por otro lado** tenemos la rendición de cuentas y presentación de observaciones.

Recién cuando hay observaciones, entramos al campo arbitral porque aparecen las cuestiones.

1.4 Diferencias entre socios

Eventualmente puedo acá someter a arbitraje una cuestión que se suscite de la administración, entonces es otra vía de hacer responsable al administrador distinta a la que surge en el caso de rendición de cuentas. Además, puede haber un arbitraje forzoso fundado en más de una causal (ej. números 3 y 4).

En estos casos no aparece una comunidad cuando se disuelve la sociedad, a diferencia de lo que sucede cuando se liquida una sociedad civil.

Ojo que la SA es siempre comercial y por otro lado las sociedades civiles son consensuales y no requieren de inscripción.

Este numeral dice relación con disputas que pueden ocurrir entre los socios, de cualquier tipo.

La normativa común a las sociedades comerciales son las que regulan las sociedades colectivas comerciales. En ese sentido, el artículo 352 del ccom habla de las menciones del estatuto social.

Art. 352 ccom. *La escritura social deberá expresar:*

10. Si las diferencias que les ocurran durante la sociedad deberán ser o no sometidas a la resolución de arbitadores, y en el primer caso, la forma en que deba hacerse el nombramiento;

Podría haber una contradicción entre este numeral y el COT porque el ccom habla de una eventualidad que depende de la voluntad de los socios, mientras que para el COT esto es materia de arbitraje forzoso.

Algunos autores decían esto se podía solucionar porque el ccom habla de “arbitrador”, pero en realidad con arbitrador el código se refiere a árbitro. Por otro lado, aparece el artículo 415 del ccom.

Art. 415 ccom. *Si en la escritura social se hubiera omitido hacer la designación que indica el número 10 del artículo 352, se entenderá que las cuestiones que se susciten entre los socios, ya sea durante la sociedad o al tiempo de la disolución, serán sometidas a compromiso.*

Pareciera que puede haber autorización a pactar algo diverso, porque solo la regla general es el arbitraje.

Alwyn dice que esto es un **arbitraje “semi obligatorio”**, posición que es doctrinal. Los fallos, en la práctica, derechamente establecen que es una materia de arbitraje forzoso e independiente de que las partes sometan las controversias a los tribunales ordinarios, en realidad eso debe ser conocido por árbitros.

Si falta la designación de la calidad del árbitro es de derecho, entonces es mejor no arriesgarse a decir que el asunto lo conoce la justicia ordinaria. Mejor pongo una buena cláusula que determina las facultades del árbitro según lo que las partes quieran.

¿A qué sociedades aplica esto?

- a) Artículo 474 ccom: aplica a la en comandita simple.
- b) Art 491 ccom: aplica a la en comandita por acciones.
- c) Art 511 ccom: aplica a la participación.
- d) Art 4 ley 3918: aplica a SRL.

Art. 474 ccom. *La comandita simple se forma y prueba como la sociedad colectiva, y está sometida a las reglas establecidas en los siete primeros párrafos de este Título, en cuanto dichas reglas no se encuentren en oposición con la naturaleza jurídica de este contrato y las siguientes disposiciones.*

Art. 491 ccom. *Las reglas establecidas en el párrafo anterior son aplicables a la comandita por acciones en cuanto no estén en contradicción con las disposiciones del presente.*

Art. 511 ccom. *Salvas las modificaciones resultantes de la naturaleza jurídica de la participación, ella produce entre los partícipes los mismos derechos y obligaciones que confieren e imponen a los socios entre sí las sociedades mercantiles.*

Art. 4 ley 3.918. *La razón o firma social podrá contener el nombre de uno o más de los socios, o una referencia al objeto de la sociedad. En todo caso deberá terminar con la palabra "limitada", sin lo cual todos los socios serán solidariamente responsables de las obligaciones sociales. En lo no previsto por esta ley o por la escritura social, estas sociedades se regirán por las reglas establecidas para las sociedades colectivas, y les serán también aplicables las disposiciones del artículo 2104 del Código Civil y de los artículos 455 Y 456 del Código de Comercio. La mujer casada y separada parcialmente de bienes, siempre que la separación sea convencional, y la que ejerza un empleo, oficio, profesión o industria con arreglo al artículo 150 del Código Civil, no requerirán la autorización especial de que trata el artículo 349 del Código de Comercio para celebrar una sociedad comercial de responsabilidad limitada, con relación al patrimonio que separadamente administren.*

¿Qué pasa en casos de SA?

Art. 4° Ley SA. *La escritura de la sociedad debe expresar:*

10) La naturaleza del arbitraje a que deberán ser sometidas las diferencias que ocurran entre los accionistas en su calidad de tales, o entre éstos y la sociedad o sus administradores, sea durante la vigencia de la sociedad o durante su liquidación. Si nada se dijere, se entenderá que las diferencias serán sometidas a la resolución de un árbitro arbitrador;

El legislador asume que hay arbitraje y que solo se puede discutir la naturaleza del arbitraje. Además, la hipótesis es mucho más amplia porque no solo son los asuntos que se ventilen entre socios por lo tanto ¿podría existir una demanda de accionistas contra la SA? Si, por ejemplo, se sanciona a la sociedad y el accionista se ve perjudicado por la multa que se le impone.

Si nada se dice, el árbitro es arbitrador.

Art. 125 Ley SA. *En los estatutos sociales se establecerá la forma como se designarán el o los árbitros que conocerán las materias a que se refiere el N° 10 del artículo 4° de la presente ley. En caso alguno podrá nominarse en ellos a una o más personas determinadas como árbitros.*

El arbitraje que establece esta ley es sin perjuicio de que, al producirse un conflicto, el demandante pueda sustraer su conocimiento de la competencia de los árbitros y someterlo a la decisión de la justicia ordinaria. Este derecho no podrá ser ejercido por los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales de la sociedad. Tampoco por aquellos accionistas que individualmente posean, directa o indirectamente, acciones cuyo valor libro o bursátil supere las 5.000 unidades de fomento, de acuerdo al valor de dicha unidad a la fecha de presentación de la demanda.

Está prohibido pactar compromiso, porque la sociedad es de capital y no de persona. Lo importante es el capital, no los socios, entonces la sociedad tiene una vocación de permanencia en el tiempo independiente de que estén vivos los socios o no. Por lo tanto lo mismo sucede con los árbitros: la sociedad dura más que el árbitro que yo pueda nombrar.

El segundo inciso es extraño porque parece estar diciendo que no es una materia de arbitraje forzoso. Sergio Rossel trata de interpretar este artículo para darle un efecto útil a todas estas normas de la SA: el legislador quiso decir que si en el estatuto no se pactó arbitraje, entonces hay

alternativa de recurrir a los tribunales ordinarios, pero si se pactó arbitraje entonces se suprime la competencia de los tribunales ordinarios.

Pero luego se modificó el artículo, estableciendo que era un derecho que le correspondía a ciertos y determinados accionistas. Por lo tanto independiente de lo pactado SIEMPRE se puede recurrir a la justicia ordinaria. Esto busca que los accionistas minoritarios no queden expuestos a circunstancias que limiten su derecho a acceder a la justicia.

La obligación de distribuir utilidades (30%) le corresponde a las SA abiertas. Imaginemos que tenemos una SA cerrada, ahí la decisión depende de la junta de accionistas entonces sería un caso en que el minoritario se puede ver afectado.

¿Es propio de un contrato de sociedad no distribuir sociedades, aunque la ley no me obligue, aunque tengamos la definición de sociedad del cc y el artículo 1546? Al parecer sí, entonces cuando el mayoritario no quiere distribuir utilidades está afectando el contrato de sociedad (no al contrato estipulado sino a la naturaleza de este tipo de contrato). Habiendo utilidades, la no distribución puede suponer que no se cumple el contrato de buena fe porque no se da cumplimiento a elementos propios de las obligaciones y relaciones de los socios.

¿Qué calidad tiene el árbitro? En todo tipo de sociedades comerciales los socios pueden determinar la calidad del árbitro. Pero si nada dicen las partes:

- SA: es árbitro arbitrador.
- En las demás, es árbitro de derecho.

En resumen respecto al "Arbitraje semi obligatorio"

¿Cuándo se aplica el arbitraje semi obligatorio?

- 1) ¿Qué dice el COT?
- 2) Materias objeto de arbitraje:
 - Casos de interpretación y ejecución del contrato de sociedad, administración, resolución o disolución de la sociedad.
 - Diferencias entre los socios en cuanto tales.
 - Diferencias entre los socios y la sociedad y sus administradores (Aylwin).
- 3) ¿Cabe discutir la existencia o validez de la sociedad?
- 4) Situación del socio que demanda a la sociedad: Art 4 N10 de la ley de SA, dependerá de la calidad del accionista.
- 5) Calidad del Árbitro art 352 N10
 - SA: Libertad pero si nada se dice, arbitradores.
 - Otras sociedades mercantiles, libertad pero si nada se dice, serán de derecho (art 235 cot).

Caso de la SPA

Creadas por la ley 20.190 (Mercado de capitales II)

Se regulan en el código de comercio en el nuevo párrafo 8 del Libro II, título VII art 348 y 424-446

No está incluido en el número 227 del COT como materia de arbitraje forzoso, solo como referencia del número 5. Es el Cod Com el que dispone el arbitraje como MASC.

Artículo 441 ccom.- *Las diferencias que ocurran entre los accionistas, los accionistas y la sociedad o sus administradores o liquidadores, y la sociedad y sus administradores o liquidadores, deberán ser resueltas por medio de arbitraje. El estatuto deberá indicar:*

1.- El tipo de arbitraje y el número de integrantes del tribunal arbitral. En silencio del estatuto, conocerá de las disputas en única instancia un solo árbitro de carácter mixto, que no obstante actuar como arbitrador en cuanto al procedimiento, resolverá conforme a derecho, y

2.- El nombre o la modalidad de designación de los árbitros y sus reemplazantes. En silencio del estatuto, los árbitros serán designados por el tribunal de justicia del domicilio social.

El estatuto de la SpA, debe contener:

1.- El tipo de arbitraje y el número de integrantes del tribunal arbitral. En silencio del estatuto, conocerá de las disputas en única instancia un solo árbitro de carácter mixto, que no obstante actuar como arbitrador en cuanto al procedimiento, resolverá conforme a derecho, y

2.- El nombre o la modalidad de designación de los árbitros y sus reemplazantes. En silencio del estatuto, los árbitros serán designados por el tribunal de justicia del domicilio social.

A pesar de ser una sociedad de capital, el artículo exige el nombre del árbitro lo que es un error de la ley.

Cuando el legislador crea las SPA se crea el concepto de árbitro mixto (art 441), pero en realidad son árbitros de derecho en cuanto al fallo y arbitradores en cuanto al procedimiento.

1.5 “Demás que determinen las leyes”

Hay otros casos en leyes especiales.

- a) Cuestiones sobre repartición de aguas y ejercicio de derechos en comunidades de aguas y asociaciones de canalistas.
- b) Negociación colectiva. En la negociación colectiva se opta por una u otra opción de contrato presentada.
- c) Avería común, seguros y comercio marítimo. ¿Aplican las normas del ccom o de la LACI? La mayoría cree que aplican las normas de arbitraje del ccom, lo que tiene efecto por ejemplo, en el nombramiento del árbitro (en el ccom interviene la justicia ordinaria si las partes no hacen designación).
- d) Sociedad por acciones.
- e) Acciones colectivas en materia de propiedad intelectual.

CAPÍTULO VII: El árbitro

Normalmente en los arbitrajes a nivel internacional los tribunales arbitrales se componen de tres árbitros; 2 elegidos por las partes, y el tercero por lo general va a depender del tipo de arbitraje, es decir, si es ad hoc o institucional.

Además, generalmente el presidente del tribunal se elegirá entre los árbitros elegidos por las partes. Sin embargo, en los arbitrajes administrados por la CCI es la Corte la que designa al presidente.

En relación con el tema de que las partes pueden ser quienes elijan al árbitro, se suele mal hablar de “arbitraje de parte” como si fuese una suerte de representante de las partes, cosa que no es así.

También, como materia introductoria es importante señalar que hay ciertas comunicaciones que se dan entre las partes y el árbitro que no se consideran mal vistas, pero todo tiene su límite. Por ejemplo es perfectamente permitido que cuando las partes están eligiendo al árbitro lo llamen para confirmar su disponibilidad, siempre y cuando no le exijan emitir un juicio sobre la materia.

1. Quién es el árbitro

Art. 222 COT. *Se llaman árbitros, los jueces nombrados por las partes, o por la autoridad judicial en subsidio, para la resolución de un asunto litigioso.*

Este artículo se concentra en dos formas de designación; (1) juez nombrado por las partes (2) juez nombrado por la autoridad judicial en subsidio, pero ¿por qué se podrían nombrar a través de un Centro de Arbitraje, por ejemplo por una cámara de comercio? Precisamente porque las partes en su designación se remiten a un reglamento que autoriza a que sean ellas quienes nombre al árbitro, pero precisamente es por un nombramiento previo que hacen las partes.

Ahora, es interesante lo que menciona el artículo 1324 del cc, ya que habla de el partidor (que es una suerte de árbitro) que puede ser designado por el causante en su testamento. En este caso, el partidor es un mero ordenador de la masa hereditaria.

Las legislaciones que han adoptado la Ley Modelo de UNCITRAL o que se han inspirado en ella (ej: España, Perú, Francia), en general, no han adoptado una definición propia de arbitraje mas allá de aquella que nosotros definimos al comienzo de semestre (tercero imparcial, nombrado por las partes, para resolver un asunto litigioso o controvertido). Tampoco hay una asimilación de la figura de un árbitro a la del juez, pero si bien los árbitros están fuera del poder judicial, ellos están dentro del control de aquél, ya que, por ejemplo, se les puede sancionar disciplinariamente y están sujetos al recurso de queja, *entonces se les reconoce la facultad de juzgar, pero no se les reconoce el carácter de jueces.*

En este sentido es interesante mencionar la definición que da Thomas Clay, quien los define como un “juez privado designado por aquellos respecto de quienes debe resolver el litigio”.

1.1 Capacidad, calidad y cualidad de los árbitros

La doctrina distingue entre capacidad y cualidad.

1) La capacidad, es la aptitud legal para ser designado árbitro. La norma general es la del artículo 225 del COT que exige:

- Tener mayoría de edad.
- Libre disposición de sus bienes
- Saber leer y escribir.

No hay norma expresa que requiera que sea abogado, ya que por ejemplo un árbitro arbitrador podría eventualmente no ser abogado. Ahora, si es un arbitraje de derecho, se exige que sea abogado y se excluye, en principio, el requisito de la mayoría de edad (pero en realidad es imposible que alguien sea abogado antes de los 18).

Es interesante mencionar (y todavía no se ha planteado en la discusión), que no hay una referencia directa en la LACI sobre la condición de abogado, porque también respecto de quien se entiende abogado, ello está expresamente determinado por la ley (licenciatura en derecho de cualquier país, práctica y juramento; en el caso de extranjeros se deben haber cumplido cursos además de otros requisitos).

Ahora, en materia de arbitraje internacional solo tenemos abogados que son extranjeros y que solo son abogados de acuerdo con el estado al que ellos pertenecen, en este sentido se han dado casos con sede no en Chile en que laudos se han anulado por ser arbitrados por abogados no habilitados en la jurisdicción de donde se dictó (se dio un caso así con sede en Costa Rica).

Lo que sucede en casos como el anterior es que como hay normas que mencionan que la nacionalidad de los árbitros no será impedimento para poder asumir como árbitro, nos deja abierta la norma la cuestión de la especialidad que pueda tener al árbitro en otras jurisdicciones.

2) La cualidad, tiene como premisa fundamental que el árbitro debe ser y permanecer independiente e imparcial, por ende si durante la ejecución de su cargo hay alguna circunstancia que afecta su imparcialidad debe hacerlo constar (esto no está expreso en arbitraje doméstico, pero sí en la LACI).

Acá nos referimos aspectos mas allá de lo jurídico, se mira a razones personales y morales de la persona del árbitro.

Como menciona el artículo 222 del COT, el árbitro es un juez y por ende se le deben exigir los mismos requisitos personales: independencia e imparcialidad.

En este sentido corresponde distinguir dos características o cualidades que se exigen del árbitro:

- Independencia: posición del árbitro frente a las partes (vínculo que afecta su capacidad para ser independiente). Acá no importa si el árbitro es o no capaz de disociar la relación que tiene con las partes porque son condiciones objetivas.
- Imparcialidad: desvinculación con la materia en particular, es decir, que no tenga un prejuicio sobre la materia (que no tenga decisión tomada). En este sentido es importante considerar cuando el árbitro es a su vez profesor o tiene escritos sobre un tema en particular que adopta una postura, ¿qué sucede? Se ha dicho que ello no afecta la imparcialidad en la medida en que no se está pronunciando sobre el caso concreto.

En el arbitraje de inversión tenemos un tribunal que resuelve una controversia, pero no sobre materias de Derecho de Privado sino de DIPRI, entonces se incluyen acá principios en ese orden. Ej. luego del Corralito en Argentina, este país argumentaba el principio del estado de necesidad.

Dos autores; Gavalda y Lucas señalan que además de la independencia e imparcialidad se requiere neutralidad cuando es arbitraje internacional principalmente, que quiere decir, que el árbitro se desvincule de sus propios valores, de su estado, etc, en el fondo que sea abierto de espíritu.

Estas cualidades **son todas interdependientes**, es decir, todas se relacionan.

a) Independencia, “cualidad más antigua”

Dijimos que la independencia se refiere a la posición del árbitro respecto de las partes. El concepto de partes es sumamente relevante ya que no solo se extiende a las partes formales sino que también sus representantes (sus abogados).

Esta se mira en **abstracto**, es decir, como dijimos no importa si el árbitro es o no capaz de disociar la relación que tiene con las partes porque son condiciones objetivas. Se mide a partir de términos netamente objetivos.

Algunos autores señalan que la ausencia de independencia no se puede apreciar sino que de manera objetiva, midiendo “in abstracto” la consecuencia de los hechos que ligan a un árbitro a una parte, porque no es posible medir el aspecto psicológico subjetivo del vínculo así creado o presumiblemente creado para ser árbitro.

Esto porque sino podría ser que en teoría quien detenta la calidad de tío, in abstracto podría haber una causal que afecta su independencia (ej. tío odia al sobrino).

b) Imparcialidad, “cualidad más delicada”

Capacidad del árbitro de abstraerse del litigio en particular: lo importante es que no haya un bias o prejuicio.

Se refiere a la posición del árbitro frente al litigio de que se trata, por ejemplo no será imparcial cuando el árbitro antes de su designación ha manifestado su parecer sobre el caso que le tocará conocer (prejuicio).

Según Caivano, es la falta de designio anticipado o prevención a favor o en contra de personas y cosas, que permite juzgar o proceder con rectitud.

c) Neutralidad, “cualidad propia del arbitraje internacional”

Que el árbitro pueda desvincularse de sus valores o corrientes jurídicas, y que sea abierto de espíritu. Se refiere a la facultad del árbitro de conservar la independencia e imparcialidad dentro del ambiente internacional, caracterizado por diferencias políticas, culturales o religiosas.

No todos los autores lo consideran como una cualidad, y en general, es propio del arbitraje internacional.

1.2 Deber de revelación

Aunque no esté consagrado legalmente en Chile (salvo en la LACI) es un deber ético.

Este es un deber ético y se refiere a que los árbitros están en el deber de poner en conocimiento de las partes cualquier causal o circunstancia que pudiese poner en duda su imparcialidad o independencia. Este examen lo hace el árbitro pero no desde el punto de vista personal: sino que debe ponerse en la posición de las partes.

Como ejemplo tenemos el código de procedimiento Francés, que es bastante estricto en el tema y consagra como un deber el revelar cualquier circunstancia que sea susceptible de afectar su independencia e imparcialidad, antes de aceptar o durante el proceso y debe mantenerse en su cargo hasta que tenga una causa legal de cese.

Nuestra LACI también contempla este deber en su artículo 12.1 y no así en nuestro arbitraje doméstico.

Artículo 12 LACI.- Motivos de recusación.

1) La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. El árbitro, desde el momento de su nombramiento y durante todas las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias a las partes, a menos que ya les haya informado de ellas.

Se trata de analizar cual es el alcance de esta disposición, es decir, de identificar qué circunstancia pudiese dar lugar a una causal de recusación o implicancia, y en general, hay modelos mas estrictos que otros; algunos creen que si, por ejemplo, es un dato que esta disponible en google y el árbitro no lo ha revelado, no es causal de anulación del laudo. Otros creen que siempre que no se revele, es causal de anulación del laudo.

En muchos Estados cuando se lleva el laudo a nulidad y surge el problema, el no revelar puede dar lugar a la anulación aunque objetivamente la causal no es tan relevante. El hecho de no revelar implicaría por sí sola falta de legitimidad da a lugar a la anulación del laudo.

En la CCI, el reglamento establece esto en su artículo 11.

1.3 Recusación e implicancia

Es importante mencionar que si vemos el listado de causales de implicancias y recusaciones, muchas de ellas no son aplicables a los árbitros. Incluso extendiéndonos a la causales que afectan a los abogados integrantes, son muy pocas las que podríamos aplicar a los árbitros.

De este modo coexisten dos sistemas y que en Chile son muy marcados:

1. La réplica de una lista de causales que afectan a los árbitros (es así en Chile en el arbitraje doméstico) y a los jueces permanentes.
2. Un método flexible con causales genéricas ("toda circunstancia que pueda dar lugar a dudas sobre la independencia o imparcialidad del árbitro").

En Chile las causales de implicancia y recusación están en el código orgánico de tribunales, y se contempla la posibilidad de renunciar anticipadamente a ellas, si se conoce de ella o el árbitro lo pone en conocimiento de las partes. Ej. una parte podría ser partidario si todos los demás están de acuerdo.

Por lo tanto, la regulación en Chile es:

- Aplica el artículo 243 del COT.

Art. 243 COT. *Los árbitros nombrados por las partes no pueden ser inhabilitados sino por causas de implicancia o recusación que hayan sobrevenido a su nombramiento, o que se ignoraban al pactar el compromiso.*

En algunos casos pueden ser renunciables las causales como dice el artículo 226:

Art. 226 COT. *No pueden ser nombrados árbitros para la resolución de un asunto las personas que litigan como partes en él, salvo lo dispuesto en los artículos 1324 y 1325 del Código Civil.*

Asimismo, no puede ser nombrado árbitro para la resolución de un asunto el juez que actualmente estuviere conociendo de él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 317.

Ahora, si el árbitro declaró la recusación eventualmente el profesor cree que podrían las partes renunciarlas. Otra cosa es que las partes hagan referencias a las normas de la IVA.

- Los árbitros designados por terceros son recusables (arts 414 y 416 CPC sobre nombramiento de peritos).

Art. 414 (416) CPC. *Para proceder al nombramiento de peritos, el tribunal citará a las partes a una audiencia, que tendrá lugar con sólo las que asistan y en la cual se fijará primeramente por acuerdo de las partes, o en su defecto por el tribunal, el número de peritos que deban nombrarse, la calidad, aptitudes o títulos que deban tener y el punto o puntos materia del informe.*

Si las partes no se ponen de acuerdo sobre la designación de las personas, hará el nombramiento el tribunal, no pudiendo recaer en tal caso en ninguna de las dos primeras personas que hayan sido propuestas por cada parte.

La apelación que se deduzca en los casos del inciso 1° de este artículo no impedirá que se proceda a la designación de los peritos de conformidad al inciso 2°.

Sólo después de hecha esta designación, se llevará adelante el recurso.

Art. 416 (418) CPC. *Cuando el nombramiento se haga por el tribunal, lo hará de entre los peritos de la especialidad requerida que figuren en las listas a que se refiere el artículo siguiente y la designación se pondrá en conocimiento de las partes para que dentro de tercero día deduzcan oposición, si tienen alguna incapacidad legal que reclamar contra el nombrado. Vencido este plazo sin que se formule oposición, se entenderá aceptado el nombramiento.*

IVA

La IVA (International Var Association) dictó una guía de independencia e imparcialidad de los árbitros que establece un sistema de semáforos; el rojo son cuestiones que son irrenunciables, es decir, aun que las partes quisieran no pueden renunciar a ellos, pero también hay ciertos rojos renunciables. Los naranjo y amarillo, son una especie de línea gris, donde las partes deciden si renuncian o no y los verdes son casos en que bajo ningún punto de vista se acepta la recusación de un arbitro.

2. Clasificación de los árbitros de acuerdo a sus facultades

- a) Árbitros de derecho o árbitros iuris
- b) Árbitros arbitradores o amigable componedor o arbitro ex aequo et bono.
- c) Árbitro mixto

En arbitraje internacional, tenemos:

a) Árbitros de equidad

b) Árbitros de derecho. Las legislaciones inspiradas en la Ley Modelo, corresponden a los árbitros mixtos (procedimiento determinado por las partes, y fallo conforme derecho que determinan las partes). El profesor cree que esto es lo más lógico porque preserva la verdadera flexibilidad del árbitro.

2.1 Árbitros de derecho

Art 223 COT. *El árbitro de derecho fallará con arreglo a la ley y se someterá, tanto en la tramitación como en el pronunciamiento de la sentencia definitiva, a las reglas establecidas para los jueces ordinarios, según la naturaleza de la acción deducida.*

Art. 628. CPC (785). *Los árbitros de derecho se someterán, tanto en la tramitación como en el pronunciamiento de la sentencia definitiva, a las reglas que la ley establece para los jueces ordinarios, según la naturaleza de la acción deducida.*

Fallan con arreglo a la ley y el procedimiento es el que corresponda según la naturaleza de la acción, por ejemplo, si es una acción ordinaria, será un procedimiento ordinario y si es sumaria el procedimiento será tal.

Actualmente se ha dado una tendencia, sobretodo en materia de árbitros mixtos y algunos casos en árbitros de derecho, de modificar ciertas normas probatorias. Nosotros consideramos que, eventualmente podría ser un error en un arbitraje de derecho o mixto considerar que el árbitro puede apreciar la prueba conforme a la sana crítica.

También es común que se supriman las tachas (normalmente quien más sabe, está expuesto a ellas por ejemplo un empleado).

Los árbitros de derecho deben ajustar su sentencia a lo que contempla el artículo 170 del CPC.

Art. 170 (193) CPC. *Las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, contendrán:*

1°. La designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión u oficio;

2°. La enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante y de sus fundamentos;

3°. Igual enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el demandado.

4°. Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia;

5°. La enunciación de las leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; y

6°. La decisión del asunto controvertido. Esta decisión deberá comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio; pero podrá omitirse la resolución de aquellas que sean incompatibles con las aceptadas.

En igual forma deberán dictarse las sentencias definitivas de segunda instancia que confirmen sin modificación las de primera cuando éstas no reúnen todos o algunos de los requisitos indicados en la enunciación precedente.

En cuanto al procedimiento, debe seguirse adicionalmente lo que señalan los artículos 628-635 del CPC. Con procedimiento nos referimos a que, en general, los tribunales permanentes tienen

ciertas modalidades de actuación, por ejemplo la mayoría de las resoluciones se notifican por Estado de Diario pero esto no existe en materia arbitral, entonces estos artículos nos señalan específicamente ciertas particularidades que deben tener los procedimientos arbitrales (no es que haya un procedimiento especial para el arbitraje de derecho).

2.2 Árbitro arbitrador

Art 223 COT. *El arbitrador fallará obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren, y no estará obligado a guardar en sus procedimientos y en su fallo otras reglas que las que las partes hayan expresado en el acto constitutivo del compromiso, y si éstas nada hubieren expresado, a las que se establecen para este caso en el Código de Procedimiento Civil.*

Se caracterizan por:

- En cuanto al fondo: resolver conforme a lo que la prudencia y equidad le dictan. Ahora, esto no es imperativo ya que el arbitro puede fallar también conforme a la ley, e incluso a veces contra ley, lo anterior es porque se entiende que la ley ya tiene un componente de prudencia y equidad (de hecho, puede ocurrir lo que se denomina “epiqueya”: aplicación directa de la norma es injusta en el caso concreto).
- En cuanto a la forma: resuelven de acuerdo al procedimiento fijado por las partes y si las partes nada dicen se aplicará el procedimiento que establezca la ley.

La unanimidad de los autores señalan que si bien el árbitro puede fallar contra ley, jamás podría fallar en contra de una norma de OP. De esta opinión discrepa Julio Philippi.

En nuestra legislación se exige que las sentencias se fundamenten (art 640 CPC), es decir, que se exprese cuáles fueron los argumentos que condujo a ese resultado en prudencia y equidad. Algunas legislaciones no lo consideran necesario y otras, siendo mas estrictas, directamente anulan las sentencias que no están fundamentadas.

Es interesante mencionar una “contradicción” que hay entre los artículos 223 y 640 del COT; en uno dicen fallar conforme a su prudencia **y** equidad y el otro dice prudencia **o** equidad, a lo que Philippi resuelve que es fallar conforme a lo que considera equitativo, a través de la prudencia.

La equidad. En ningún artículo se menciona lo que se entiende por equidad (solo se menciona en algunos arts como el 24 del cc o 170 del CPC), pero en definitiva, en filosofía del derecho se entiende **como lo que es justo y bueno (ex aequo et bono)**, incluso cuando ello pugna con la ley formal (epiqueya). Ulpiano, por su parte, entiende que es la **constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo que corresponde**, pero en esta definición se genera un problema ya que, en general, se cree que el árbitro falla según aquello que su “guata le indica”, pero no es así, ellos fallan según lo que se prueba en el juicio y la valoración de los hechos.

Procedimiento aplicable:

- El señalado por las partes.
- En subsidio, el señalado en el CPC, arts. 637 y sigs.

2.3 Árbitros mixtos

Son una combinación de los dos sistemas antes señalados, no obstante ellos tienen ciertas características esenciales:

- Fallan conforme a derecho.
- El procedimiento es el que señalen las partes o el que señale la ley en subsidio.

2.4 Normas comunes a todos los tipos

En todos los tipos, se exige el deber de archivo, lo que demuestra que la confidencialidad no es un principio esencial del arbitraje: es un principio pero las partes deben convenirlo.

3. Consideraciones finales

a) El arbitraje de derecho es la regla general: Bordachar siempre cree que es mejor el árbitro mixto ya que la norma da una suerte de previsibilidad en torno al fallo y un árbitro arbitrador, será conveniente según el tipo de materia.

Hasta antes de la LACI, se aplicaban las normas procedimentales del CPC cuando la sede era Chile. Esto era una cuestión que desalentaba a Chile como sede de arbitraje.

b) En legislaciones comparadas cuando se habla del árbitro de derecho se entiende que se refiere únicamente a la forma de fallar, no al procedimiento, que queda a la determinación de las partes. Esto facilita mucho cuando hablamos de árbitros extranjeros que no conocen los procedimientos locales.

c) ¿Por qué elegir cada tipo de árbitro?

El profesor prefiere siempre el mixto porque la norma da estabilidad y previsión sobre las consecuencias. Arbitrador conviene cuando son materias que escapan a la aplicación de la ley.

Obviamente la forma de litigar cambia caso a caso porque, por ejemplo, voy a tener que cuestionar si es justo o no aplicar la norma concreta.

d) Instalación del tribunal

Esta es una cuestión relevante, sobre todo en arbitrajes domésticos.

La ley no define expresamente cuándo comienza la instancia arbitral. Tres interpretaciones:

- Desde la designación.
- Desde el juramento y aceptación.
- Desde el comparendo de instalación.

Importancia: Comienza el cómputo del plazo de duración del arbitraje.

Exigencia legal de una aceptación y juramento: Sólo en arbitraje doméstico (art. 236 COT). No se contempla en el arbitraje comercial internacional.

Art. 236 COT. *El árbitro que acepta el encargo deberá declararlo así, y jurará desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible.*

Por lo tanto, siempre es conveniente tener presente la instalación del tribunal arbitral, sobre todo en los arbitrajes domésticos, teniendo en cuenta el plazo máximo que establece la ley (2 años) y

considerando que la ley no establece el cuándo comienza la instancia arbitral propiamente tal, pero nos da ciertos hitos como la existencia legal de aceptación y juramento. Para esto hay criterios muy distintos (ej. al profesor le ha tocado jurar por teléfono).

Si no hay juramento y aceptación, el arbitraje es nulo.

¿Cuándo se entiende instalado el tribunal?

- El profesor cree que si hay un compromiso hay tribunal instalado desde que se notifica al árbitro y este acepta.
- Si es ad hoc el arbitraje, será en el momento en que sea nombrado por las partes o el tribunal y este jure, ahora, en general se hace un comparendo de fijación de bases que determina el momento en que se empiezan a contar los plazos. Esto quita todo el tiempo perdido, por ejemplo, de notificaciones de las partes (ej. caso de una partición con 15 herederos).

La audiencia de fijación de bases y procedimientos no existe en la ley, pero internacionalmente sí existe una audiencia así donde se fijan fechas relevantes (ej. presentación de la demanda).

Por último en cuanto a la constitución del tribunal arbitral, es importante mencionar que ellos tienen una exigencia legal de aceptación y prestación de juramento, ya que si no se jura y se acepta, se entiende nulo.

CAPÍTULO VIII: Procedimiento arbitral (arbitraje doméstico)

Al profesor le llegó un caso actual de designación de árbitro sobre materias de navegación. El com dice que los árbitros designados en el caso de la navegación son árbitros de Derecho. ¿Será necesario citar a una audiencia de fijación de bases del procedimiento? No porque el procedimiento se rige por el CPC de acuerdo a la naturaleza de la acción (eventualmente podrían modificarse normas de notificación). Desde el momento en que el árbitro jura y acepta ya es sede jurisdiccional entonces.

La eventual imposibilidad de llevar a cabo audiencias de fijación de bases en casos de pandemia, estaría en este caso superado. Por lo tanto solo se notifica a las partes para que tengan conocimiento de que pueden interponer demandas.

1. Inicio de la instancia arbitral

Hay tres grandes posiciones, como vimos la clase pasada. Pero mayoritariamente la jurisprudencia se inclina por el inicio desde la aceptación y juramento.

Art. 235 COT. *Si las partes no expresaren con qué calidad es nombrado el árbitro, se entiende que lo es con la de árbitro de derecho.*

Si faltare la expresión del lugar en que deba seguirse el juicio, se entenderá que lo es aquel en que se ha celebrado el compromiso.

Si faltare la designación del tiempo, se entenderá que el árbitro debe evacuar su encargo en el término de dos años contados desde su aceptación.

No obstante, si se hubiere pronunciado sentencia dentro de plazo, podrá ésta notificarse válidamente aunque él se encontrare vencido, como asimismo, el árbitro estará facultado para dictar las providencias pertinentes a los recursos que se interpusieren.

Si durante el arbitraje el árbitro debiere elevar los autos a un tribunal superior, o paralizar el procedimiento por resolución de esos mismos tribunales, el plazo se entenderá suspendido mientras dure el impedimento.

OJO que al plazo de 2 años se le resta el tiempo en que el árbitro no pudo acceder al expediente.

Requisito esencial: aceptación y juramento. *La designación en caso de cláusula es distinta al caso en que haya un compromiso.*

- Cuando quiero designar a un árbitro que no está determinado por el acuerdo de arbitraje se inicia un procedimiento contencioso en que se solicita al tribunal que cite a la otra parte para que se designe de común acuerdo un árbitro, de lo contrario lo designa el tribunal. Esto se denomina **“designación de árbitro”**.

Por medio de receptor judicial se notifica la sentencia que designa al árbitro, pero también puede comunicarse directamente el nombramiento al árbitro. Es importante que la sentencia esté ejecutoriada porque puede que este procedimiento se lleve a cabo en rebeldía de una de las partes, para evitar nulidad del procedimiento arbitral por incompetencia.

Este procedimiento se remite a la designación de peritos que se realiza en el término probatorio (por lo tanto se notifica a las partes por el Estado). Por eso se conviene que se notifique siempre por cédula.

- En el caso del compromiso o le aviso directamente al árbitro para que este jure y acepte ante ministro de fe (ej. notario). Pero también puedo iniciar un procedimiento voluntario no contencioso donde se notifica al árbitro para que este acepte el encargo. Esto se denomina **“notificación de árbitro”**.

El árbitro tiene que aceptar y jurar para que se constituya el tribunal. La fórmula, según el artículo 236 es “juro desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible”.

Hay una nómina de la CS y ellos se eligen *preferentemente*. Pero hay otros registros, como en el caso de procedimientos concursales.

1.1 Primera audiencia o audiencia de instalación

Es la audiencia de determinación de bases del procedimiento, en casos de arbitraje mixto o de árbitro arbitrador. Ahora, en caso de derecho también se usa para evitar y rectificar algunos errores, por ejemplo en casos de partición en que no se pide la liquidación por el todo, de hecho ha habido casos en que hay arbitrajes de liquidación de herencias que son paralelos entonces no puede haber remate.

También puede servir esta audiencia para ampliar la competencia del árbitro fijada por la sentencia que lo designa. Ahora, sin perjuicio de esto obviamente lo que manda es lo que las partes fijan en sus demandas/contestaciones, pero la demanda arbitral debe circunscribirse a lo que diga la cláusula arbitral/la sentencia del juez/ lo que hayan dicho las partes al determinar la competencia del árbitro.

2. Normas

Se regula en el título VII del Libro III del CPC. Se divide en tres párrafos:

- Juicios seguidos ante árbitros de derecho (art 628-635)
- Juicios seguidos ante arbitradores (art 636-643)
- Disposiciones comunes (art 644)

3. Juicios seguidos ante árbitros de derecho

Principio general: los árbitros se someten a las reglas que la ley establece para los jueces ordinarios, según la naturaleza de la acción deducida (artículo 628 CPC).

¿Debe someterse a las reglas del juicio ordinario? NO, depende de la naturaleza de la acción que puede ser sumaria o de otro tipo.

¿Se pueden modificar las reglas legales? En principio no. Pero por ejemplo el artículo 629 permite la modificación de normas de notificación (ej. carta certificada).

Art. 629. (786) CPC. *En los juicios arbitrales se harán las notificaciones personalmente o por cédula, salvo que las partes unánimemente acuerden otra forma de notificación.*

3.1 Instalación del tribunal

El tribunal arbitral es un nuevo tribunal, por tanto las partes no han sido notificadas del inicio del procedimiento. Tampoco sirven los mandatos judiciales o patrocinios presentados durante el procedimiento de designación del árbitro.

Por lo tanto, **el árbitro es un nuevo tribunal**, entonces:

- 1) Se requiere de un nuevo emplazamiento para la comparecencia de las partes.
- 2) Hay que notificarlas personalmente de la resolución que instala al tribunal (NO es la notificación de la demanda), o por avisos eventualmente.

Es común que en esta resolución se indique que se puede notificar por el 44 siempre que se acreditan los requisitos del artículo sin necesidad de petición por escrito de la otra parte.

También puede eventualmente citarse a comparendo y en ese caso es importante dejar claro que el comparendo afecta incluso a las partes que no comparezcan.

- 3) Las partes deben acreditar patrocinio de abogado.

Principio dispositivo: las partes son las que inician el juicio propiamente tal.

- Necesidad de presentación de la demanda.
- Es recomendable dejar claro en las bases del procedimiento que si no se presenta la demanda, se tiene por desistido el juicio.

3.2 Notificaciones

Esto se rige por el artículo 629 del CPC. El profesor cree que también puede ser por avisos.

3.3 Tribunales colegiados

Acuerdo en tribunales colegiados: artículos 630 y 631 CPC. Solo en el arbitraje doméstico pueden haber tribunales colegiales de número par.

Art. 630 CPC. (787). *Si los árbitros son dos o más, todos ellos deberán concurrir al pronunciamiento de la sentencia y a cualquier acto de substanciación del juicio, a menos que las partes acuerden otra cosa.*

No poniéndose de acuerdo los árbitros, se reunirá con ellos el tercero, si lo hay, y la mayoría pronunciará resolución.

Art. 631 CPC. (788). *En caso de no resultar mayoría en el pronunciamiento de la sentencia definitiva o de otra clase de resoluciones, siempre que ellas no sean apelables, quedará sin efecto el compromiso, si éste es voluntario. Si es forzoso, se procederá a nombrar nuevos árbitros.*

Cuando pueda deducirse el recurso, cada opinión se estimará como resolución distinta, y se elevarán los antecedentes al tribunal de alzada, para que resuelva como sea de derecho sobre el punto que haya motivado el desacuerdo de los árbitros.



OJO que el tercero en discordia sólo puede dirimir, no puede presentar una nueva opción.

¿Qué carácter tiene la decisión de la CA? Si la Corte resuelve una apelación, es sentencia de segunda instancia (esto cree el profesor porque el CPC dice que la resolución debe ser apelable). Pero otros creen que es un tercero en discordia entonces la resolución es apelable.

La misma regla se aplica en el arbitraje de arbitradores, si las partes dispusieron que la sentencia fuera apelable. En ese sentido, las resoluciones de arbitradores nunca son apelables por la naturaleza de la CA, salvo que las partes hayan dispuesto que la sentencia sea apelable y hayan nombrado el tribunal de segunda instancia. En este último caso, aplican las mismas normas del caso de árbitros de derecho.

3.4 Autorización de las actuaciones del árbitro de derecho (art 632 CPC)

Art. 632 CPC. (789). *Toda la substanciación de un juicio arbitral se hará ante un ministro de fe designado por el árbitro, sin perjuicio de las impugnaciones o recusaciones que puedan las partes reclamar; y si está inhabilitado o no hay ministro de fe en el lugar del juicio, ante una persona que, en calidad de actuario, designe el árbitro.*

Cuando el árbitro deba practicar diligencia fuera del lugar en que se siga el compromiso, podrá intervenir otro ministro de fe o un actuario designado en la forma que expresa el inciso anterior y que resida en el lugar donde dichas diligencias han de practicarse.

- Ministro de fe
- Arbitro partidor: En el caso del partidor tiene que ser un secretario del tribunal o un notario.
- Diferencias con el arbitrador. En el caso del arbitrador no es necesario tener ministro de fe, pero su sentencia debe ser autorizada por ministro de fe o dos testigos.

3.5 Prueba de testigos (art 633 CPC)

Art. 633. (790) CPC. *No podrá el árbitro compeler a ningún testigo a que concurra a declarar ante él.*

Sólo podrá tomar las declaraciones de los que voluntariamente se presten a darlas en esta forma.

Cuando alguno se niegue a declarar, se pedirá por conducto del árbitro al tribunal ordinario correspondiente que practique la diligencia, acompañándole los antecedentes necesarios para este objeto.

Los tribunales de derecho podrán cometer esta diligencia al árbitro mismo asistido por un ministro de fe.

Aplican las mismas reglas generales pero no puedo obligar al testigo a comparecer. En ese caso se exhorta al tribunal ordinario para que tome la declaración lo que se realiza directamente en el tribunal civil por el árbitro o se le pide al tribunal que tome la declaración.

3.6 Ejecución de la sentencia (art 635 CPC)

Art. 635. (792) CPC. *Para la ejecución de la sentencia definitiva se podrá ocurrir al árbitro que la dictó, si no está vencido el plazo por que fue nombrado, o al tribunal ordinario correspondiente, a elección del que pida su cumplimiento.*

Tratándose de otra clase de resoluciones, corresponde al árbitro ordenar su ejecución.

Sin embargo, cuando el cumplimiento de la resolución arbitral exija procedimientos de apremio o el empleo de otras medidas compulsivas, o cuando haya de afectar a terceros que no sean parte en el compromiso, deberá ocurrirse a la justicia ordinaria para la ejecución de lo resuelto.

Podemos recurrir ante al árbitro o tribunal ordinario competente para la ejecución de la sentencia.

Si se requiere de fuerza pública, hay que oficiar al tribunal civil competente para que preste el auxilio de la fuerza pública.

4. Juicios seguidos ante árbitros arbitradores

Art. 636. (793) CPC. *El arbitrador no está obligado a guardar en sus procedimientos y en su fallo otras reglas que las que las partes hayan expresado en el acto constitutivo del compromiso.*

Si las partes nada han dicho a este respecto, se observarán las reglas establecidas en los artículos que siguen.

Principio general: *el arbitrador no está obligado a guardar en sus procedimientos y en sus fallos otras reglas que las que las partes hayan expresado en el compromiso (art 636).*

Usa el procedimiento que han definido las partes, y lo más importante es que fallan conforme a lo que la prudencia/equidad les dicte.

En silencio de las partes, el arbitrador debe seguir las reglas del párrafo 2 del título VIII del libro III del CPC. Lo importante es que si nada dicen las partes sobre el procedimiento, aplican las normas procesales mínimas establecidas en el CPC.

Caso especial de la partición: se rige por su propio título (IX Libro III CPC)

La ley se remite directamente a ellos en ciertas ocasiones (ej. SA), pero en el resto de los casos las partes tienen que otorgarle facultades de arbitrador al árbitro.

4.1 Reglas mínimas del debido proceso

Art. 637 CPC. (794). *El arbitrador oír a los interesados; recibirá y agregará al proceso los instrumentos que le presenten; practicará las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos, y dará su fallo en el sentido que la prudencia y la equidad le dicten.*

Podrá oír a los interesados por separado, si no le es posible reunirlos.

Las normas de los artículos 637 en adelante buscan asegurar el debido proceso, sobre todo el principio de contradicción y bilateralidad de la audiencia. Se garantiza como principio base que el árbitro debe escuchar a las partes incluso de manera separada, esto es, que debe escuchar a las dos partes en iguales términos. En ese sentido, las partes debiesen siempre comunicarse con el juez por medio de escritos, por eso debiesen evitarse las comunicaciones directas privadas, como hablar por teléfono.

En el caso de los partidores ellos son árbitros de derecho pero se le pueden dar facultades de arbitrador. Ahora, ello dice relación con el procedimiento más que con el contenido de la resolución, dado que en realidad estas normas sustantivas son muy mecánicas.

¿Qué pasa si quiero presentar un experto pero no perito para controvertir la prueba pericial, sobre todo en casos de partición? Puedo acompañar un documento con la opinión del experto y además lo presento como testigo. En esos casos se entiende la prueba como base de presunción.

4.2 Ley 18.120

Las partes pueden comparecer sin abogado, por el artículo 2 de la ley 18.120.

Artículo 2 ley 18.120.- *Ninguna persona, salvo en los casos de excepción contemplados en este artículo, o cuando la ley exija la intervención personal de la parte, podrá comparecer en los asuntos y ante los tribunales a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, sino representada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, por procurador del número, por estudiante actualmente inscrito en tercero, cuarto o quinto año de las Escuelas de Derecho de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de alguna de las universidades autorizadas, o por egresado de esas mismas escuelas hasta tres años después de haber rendido los exámenes correspondientes. La autoridad universitaria competente certificará, a petición verbal del interesado, el hecho de estar vigente la matrícula o la fecha del egreso, en su caso. La exhibición del certificado respectivo habilitará al interesado para su comparecencia.*

(...) Exceptúanse, también, del cumplimiento de dichas obligaciones, solicitudes sobre pedimentos de minas que se formulen ante los tribunales, sin perjuicio de cumplirse tales exigencias respecto de las tramitaciones posteriores a que den lugar. No regirán tampoco respecto de los asuntos de que conozcan los jueces de subdelegación y de distrito; los alcaldes; los jueces de policía local, salvo en los asuntos sobre regulación de daños y perjuicios de cuantía superior a dos unidades tributarias mensuales; los juzgados de menores; los árbitros arbitradores;

El problema que emana es especialmente en los casos que una parte se presenta con abogado y la otra sin, lo que es muy común en casos de partición. En estos casos el profesor apercibe a la parte para que designe abogado y los remite a centros de defensa gratuitas. De lo contrario, la parte va a presentar escritos de manera informal y hay que proveerlos igual para asegurar la defensa de las partes.

4.3 Comparendos

El árbitro tiene libertad para oír a los interesados y esto puede hacerse en comparendos.

4.4 Período de prueba (art 638)

Art. 638. (795) CPC. *Si el arbitrador cree necesario recibir la causa a prueba, decretará este trámite. Es aplicable a este caso lo dispuesto en los artículos 633 y 634.*

- Queda a criterio del arbitro recibir la causa a prueba (según lo dispongan las partes).
- Se aplican las normas de las pruebas de testigos de los árbitros de derecho.
- No puede obligar el árbitro a un testigo para que comparezca a declarar, lo debe hacer por medio de un tribunal.

4.5 Sustanciación (art 639)

Art. 639. (796) CPC. *El arbitrador practicará solo o con asistencia de un ministro de fe, según lo estime conveniente, los actos de substanciación que decreta en el juicio, y consignará por escrito los hechos que pasen ante él y cuyo testimonio le exijan los interesados, si son necesarios para el fallo. Las diligencias probatorias concernientes al juicio de compromiso que se practiquen ante los tribunales ordinarios se someterán a las reglas establecidas para éstos.*

a) No es obligatorio que haya un ministro de fe como en el caso de árbitro de derecho. Pero en los juicios particionales siempre debe haber un notario o secretario de tribunal, so pena de nulidad. Ahora, si se opta por no tener un actuario, la sentencia debe autorizarse por notario o dos testigos.

El ministro de fe es quien autoriza las diligencias. El receptor judicial es quien, por ley, hace las notificaciones pero eventualmente las partes pueden asignarle esta función a un ministro de fe para que efectúe las notificaciones.

El profesor siempre prefiere tener un notario de confianza. El problema es que los notarios hacen FEA a través de un sistema computacional, no a través del “pendrive” que se usa generalmente. Entonces escanean el documento en papel y el documento escaneado lo firman.

b) Consignación por escrito de las diligencias: se debe llevar un expediente escrito empastado o cocido (solo así lo acepta el archivero judicial).

c) Las partes pueden pedirle al árbitro que consigne hechos.

d) Diligencias en tribunales ordinarios: se siguen las reglas generales y no las pueden cambiar las partes.

¿Las diligencias se hacen por oficio o exhorto? Depende del caso. Por ejemplo, si lo que quiero es que otro tribunal tome una declaración de testigo será por exhorto.

4.6 Contenido de la sentencia

El artículo 170 aplica para el caso del árbitro de derecho, pero en el caso del arbitrador hay algunas diferencias porque por ejemplo, se exige enunciación de leyes o principios de equidad a falta de ley. En resumen, el contenido es el siguiente:

- a) Designación de las partes litigantes
- b) Enunciación breve de las peticiones del demandante
- c) Enunciación de la defensa

- d) Razones de prudencia o equidad que le sirven de fundamento a la sentencia ¿puede fundarse en la ley?
- e) Decisión del asunto controvertido
- f) Fecha y lugar en que se expide, firmas

¿Puede fallar conforme a la ley? Si, porque las normas de derecho son expresión de actos del legislador que implica justicia y prudencia.

Nada se dice sobre la motivación pero la sentencia siempre debe ser motivada y fundamentada. No basta decir que con “prudencia y equidad” se llega a una determinada resolución, en tanto la sentencia debe tener un fundamento lógico como parte del debido proceso. El justiciable tiene que saber por qué gana y por qué pierde.

4.7 Acuerdos en tribunales colegiados (art 641)

- Siempre deben concurrir todos los árbitros a todas las actuaciones
- Tercero en discordia
- Si no puede formarse mayoría, caso SIN apelación
- Si no puede formarse mayoría caso CON apelación
- Tribunal de apelación. Diferencia con el de derecho.

Art. 641. (798) CPC. *Si son dos o más los arbitradores, deberán todos ellos concurrir al pronunciamiento de la sentencia y a cualquier otro acto de substanciación, salvo que las partes acuerden otra cosa.*

Cuando no haya acuerdo entre los arbitradores, se llamará al tercero, si lo hay; y la mayoría formará resolución.

No pudiendo obtenerse mayoría en el pronunciamiento de la sentencia definitiva o de otra clase de resoluciones, quedará sin efecto el compromiso si no puede deducirse apelación. Habiendo lugar a este recurso, se elevarán los antecedentes a los arbitradores de segunda instancia, para que resuelvan como estimen conveniente sobre la cuestión que motiva el desacuerdo.

La excepción es que las sentencias sean apelables, hay que tener ojo con eso, a menos que se haya establecido un tribunal de apelación de segunda instancia.

¿Qué ocurre con los árbitros mixtos? Se aplican los principios de los árbitros de derecho entonces si no se ha renunciado, procede apelación.

4.8 Ejecución de la sentencia

Lo que se hace es que la parte lleva la sentencia al tribunal ordinario.

Art. 635. (792) CPC. *Para la ejecución de la sentencia definitiva se podrá ocurrir al árbitro que la dictó, si no está vencido el plazo por que fue nombrado, o al tribunal ordinario correspondiente, a elección del que pida su cumplimiento.*

Tratándose de otra clase de resoluciones, corresponde al árbitro ordenar su ejecución.

Sin embargo, cuando el cumplimiento de la resolución arbitral exija procedimientos de apremio o el empleo de otras medidas compulsivas, o cuando haya de afectar a terceros que no sean parte en el compromiso, deberá ocurrirse a la justicia ordinaria para la ejecución de lo resuelto.

5. Procedimiento ante árbitros mixtos

- 1) En cuanto al procedimiento, se rige por las normas de los arbitradores.
- 2) Sin perjuicio de ello, estimamos que se les deben exigir la autorización de las sentencias por un ministro de fe.
- 3) Las partes deben ir patrocinadas por abogados (art 1 y 2 de la Ley 18.120)
- 4) Sentencia debe tener los mismos requisitos que los árbitros de derecho: art 170 CPC.
- 5) Valoración de la prueba. La presentación y la valoración de la prueba se realiza conforme a las normas del cc y CPC.

6. Disposiciones comunes

6.1 Archivo

Art. 644. (801) CPC. *Los expedientes fallados por árbitros o arbitradores se archivarán en la comuna agrupación de comunas donde se haya constituido el compromiso, en el oficio del funcionario a quien correspondería su custodia si se hubiera seguido el juicio ante los tribunales ordinarios.*

Es obligatorio archivar los expedientes en todos los casos, en virtud del artículo 644 del CPC. Además, esto se realiza en el oficio del funcionario a quien correspondería la custodia si se hubiera seguido el juicio ante un tribunal ordinario.

6.2 Medidas precautorias

- 1) El arbitraje es una jurisdicción análoga a los de los tribunales ordinarios.
- 2) Art 2 y 3 del CPC hacen extensivas las reglas de procedimiento ordinario en ausencia de norma
- 3) Medidas que exigen medidas de apremio y medidas que afectan a terceros.
- 4) Medidas prejudiciales precautorias.

Los árbitros están habilitados para dictar y ordenar medidas precautorias. Ahora, en el caso de las prejudiciales se pueden pedir ante el tribunal arbitral ya constituido pero si no lo está puedo pedirlo al tribunal civil (pero ahí tengo que interponer demanda dentro de 10 días). En este caso, la solicitud de designación de árbitro supondría el cumplimiento del requisito de presentación de la demanda.

Si hay apremios o medidas que afectan a terceros hay que exhortar al tribunal civil.

6.3 Recursos

- 1) Arbitraje de derecho
 - Caben todos los recursos, si no se han renunciado (art 238 y 239 COT)
- 2) Arbitraje de arbitrador.
 - Apelación solo ante tribunal arbitrador de segunda instancia.
 - Casación en la forma siempre permitida (art 545 inciso 1 COT).
 - Tramites esenciales son definidos por las partes (art 796 CPC).

- Casación en el fondo, expresamente prohibido. Se prohíbe la casación fondo porque no se falla conforme a derecho.

3) Son irrenunciables en ambos casos

- Casación en la forma ultra petita e incompetencia.

Las partes, a través de un acuerdo de arbitraje, le dan competencia al árbitro. El árbitro no puede resolver más cosas que el ámbito de competencia en el que se encuentra en virtud de la determinación que hacen las partes. Por lo tanto, la incompetencia viene dada por el límite que dan las partes al árbitro en el acuerdo de arbitraje.

Por otro lado, la ultra petita procede cuando el juez otorga más de lo que se le pidió.

- Recurso de queja.

En el recurso de queja, se explica porque hay una superintendencia correctiva de la CS. Procede cuando ha habido manifiesta falta y abuso.

- Recurso de revisión (art 810 y ss CPC).

El recurso de revisión procede cuando se ha dictado una sentencia fundada sobre prueba fraudulenta.

7. Arbitraje institucional

Si las partes se someten al reglamento, por ejemplo, del CAM, ya están definidas las reglas del procedimiento y no pueden ellas modificarse por las partes. Si se modifica alguna cuestión específica de común acuerdo con las partes, lo que puede terminar pasando es que quedan procedimientos inconexos.

Entonces, en principio yo podría modificar elementos pero eso no es conveniente porque lo más probable es que la institución no lo permita. Lo que sí podría hacer es realizar ciertas especificaciones.

Si me someto al reglamento, ESAS son las normas procedimentales. Por lo tanto no faltaría determinación del procedimiento por las partes y no aplican las normas del CPC.

CAPÍTULO IX: Arbitraje comercial internacional (ACI)

1. Acuerdo de arbitraje

En arbitraje Doméstico la diferencia entre cláusula compromisoria y compromiso es la designación del árbitro, además de que la cláusula compromisoria supone siempre encontrarnos dentro de la esfera del arbitraje, no así en el caso de los compromisos.

- a) Cláusula compromisoria: cuando hay un litigio futuro.
- b) Compromiso: litigio actual. Ya ha devenido el conflicto.

2. Principios fundamentales

a) Libertad contractual. Pactamos arbitrajes porque somos libres de hacerlo.

b) Seguridad. En el arbitraje internacional, es fundamental que los actores del arbitraje (partes y árbitro) sepan que el laudo sea ejecutable, es decir, que pueda ser cumplido no solo en el estado sede del arbitraje sino en cualquier lugar donde el que “pierde” tiene activos.

La Convención de NY permite ejecutar el laudo en distintas jurisdicciones.

3. Por qué recurrir al ACI

Es claro que nos da más confianza litigar frente a un tribunal imparcial en torno a la nacionalidad de las partes, en vez de un tribunal estatal de alguna de las partes. Entonces este es el medio natural de solución de controversias internacionales tanto para compensar la inicial desconfianza respecto de tribunales estatales, sino que además los Estados se han encargado de hacer ejecutable los fallos sin un doble exequátur.

4. Reglas propias del ACI

El ACI permite resolver controversias internacionales entonces debemos permitir que el sistema cumpla con ese objetivo. Por lo tanto aparecen principios como el de separabilidad y el de kompetenz – kompetenz.

5. Sistemas de regulación del arbitraje

Existen dos grandes sistemas.

a) Sistema monista: se agrupan en el mismo sistema normativo los arbitrajes domésticos e internacionales. Eventualmente pueden hacer normas particulares precisas que supongan una distinción, por ejemplo, en Perú solo procede el recurso de anulación pero si es ACI y no hay partes peruanas se podría renunciar a este recurso.

Brasil, España, Perú, RD, Costa Rica, entre otros.

b) Sistema dualista: hay doble regulación. No necesariamente deben haber dos cuerpos normativos distintos como sucede en Chile con el COT/CPC y la LACI. Francia, en su CPC, regula ambos tipos de arbitraje y lo mismo sucede con la Ley Colombiana.

Chile, Colombia, Francia, etc.

5.1 Teoría de la localización o deslocalización

Al final esto depende de una opción de cada país. Ahora, algunos tratadistas (sobre todo franceses) dicen que NO puede haber un sistema monista porque son tipos jurídicos diferentes. El arbitraje internacional aplica normas internacionales entonces no hay vinculación a una norma estatal.

Esto es lo que se denomina **“teoría de la localización o deslocalización”**: aunque haya una sede arbitral, el resultado del arbitraje sigue siendo internacional. Entonces, por ejemplo si se anula el laudo en Chile, yo podría ejecutar el laudo en otro Estado. Para que el laudo no sea ejecutable, debe ser contrario al orden público internacional.

Otros creen que esto no es correcto. La sede entraña un efecto de responsabilidad de las partes, y una elección respecto de foros. Al elegir la sede se asumen tribunales de apoyo para facilitar el

arbitraje, pero también se determina cuál es el tribunal de la anulación. En resumen, si en esa sede se anula el laudo entonces este no nació a la vida del derecho y no puede ejecutarse.

5.2 Ley Modelo CNUDMI/ UNCITRAL

Se dictó en 1985 y sufrió enmiendas en 2006 sobre formas de la cláusula y medidas precautorias.

6. Fuentes del ACI

En Chile se distinguen:

- 1) Fuentes privadas.
- 2) Fuentes públicas

2.1) De orden nacional.

2.2) Orden internacional.

En el orden internacional, encontramos:

- Convención de NY (1958).

No es una Convención de arbitraje sino que vincula a los Estados signatarios para reconocer o ejecutar laudos arbitrales extranjeros (en relación al lugar donde se quieren ejecutar; por ejemplo el laudo se dictó en Argentina y quiere ejecutarse en Chile). No es lo mismo laudo arbitral extranjero que internacional, porque este último es el que se dicta en un ACI.

Su artículo 2 se refiere a la obligatoriedad de parte de los estados signatarios para reconocer por escrito el acuerdo que obliga a las partes a someterse a arbitraje y establece ciertas condiciones.

- Convención de Ginebra (Europa).
- Convención de Washington (1965).

Se refiere a la solución de controversias en relación a inversionistas, y se remite al CIADI.

- Convención de Panamá (1975).

Es igual a la de NY con ciertas precisiones, por ejemplo, si no hay centro de arbitraje se establece uno en particular.

7. El ACI en Chile

Existe desde siempre, pero la regulación propia comienza en 2004 con la dictación de la ley 19.971, que se aprobó de forma bastante inmediata en el país.

7.1 Antecedentes

- a) Ley modelo UNCITRAL.
- b) Propuesta del colegio de abogados, CAM Santiago y CAM AMCHAM. Esta última se disuelve y la CAM toma su lugar en sede internacional.
- c) Marco normativo inexistente para ACI con sede Chile. Teníamos economía abierta pero no habían suficientes incentivos para inversionistas privados que quisieran invertir en Chile para tener un método apropiado de solución de controversias.

Recordemos que en ACI, los árbitros de derecho se someten a un procedimiento mucho más flexible y fijado por las partes. Sin embargo, como no había regulación al respecto en Chile en la práctica el árbitro de derecho se remitía al CPC.

7.2 Fundamentos de la LACI (mensaje)

- a) Multiplicación de transacciones con cláusula arbitral por efecto del intercambio comercial internacional. Chile no era sede atractiva porque nuestro marco normativo era poco flexible, entonces normalmente se elegía una sede fuera de Chile, lo que significaba encarecimiento de los costos transaccionales del litigio para los chilenos.
- b) Incentivo de juicio en Chile, lo que beneficia a las PYMES.
- c) Chile como centro de arbitraje.

Se trató de transformar a Chile en centro de arbitraje, pero en realidad nuestra ubicación geográfica dificulta este objetivo porque los costos operacionales de traer juicios a Chile, además de la infraestructura (ej. hotelería, traductores, etc), son desincentivos.

7.3 Importancia de la uniformidad

- a) Unifica sistemas de common law y civil law. Toma las mejores prácticas de ambas para que tengamos un marco conocido previamente por las partes.
- b) Ley Modelo y no Convención (excluye reservas). Las Convenciones son tratados internacionales y los estados pueden establecer reservas (ciertas disposiciones no se les aplican), lo que no pasa en las Leyes Modelos. Respecto de la Ley Modelo yo puedo tomar lo que me interesa, con mayor flexibilidad, por ejemplo, Perú tiene un régimen aun más liberal que la ley modelo.

En 2004 se “copia” la ley modelo original de 1985, pero el 2006 esta ley se reforma dando mayores flexibilidades en materia de medidas cautelares. España ya en 2003 hizo modificaciones, pero nosotros no lo hicimos.

7.4 Principios

- a) Dispositivo.
- b) Controversia (contradicción) o bilateralidad de la audiencia.
- c) Principio inquisitorio o de verdad material, es decir, el árbitro debe reconstruir y comprobar los hechos.
- d) Eficacia (conseguir los resultados) y eficiencia (menor costo posible) del procedimiento arbitral.

Artículo 4º LACI.- *Renuncia al derecho de objetar. Se considerará que la parte que prosiga el arbitraje conociendo que no se ha cumplido alguna disposición de esta ley de la que las partes puedan apartarse o algún requisito del acuerdo de arbitraje y no exprese su objeción a tal incumplimiento sin demora injustificada o, si se prevé un plazo para hacerlo, dentro de ese plazo, ha renunciado a su derecho a objetar.*

- e) Oralidad y escrituración.

Artículo 24 LACI. *Audiencias y actuaciones por escrito.*

1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias para la presentación de pruebas o para alegatos orales, o si las actuaciones se sustanciarán sobre la base de documentos y demás pruebas. No obstante, a menos que las partes hubiesen convenido que no se celebrarían audiencias, el tribunal arbitral celebrará dichas audiencias en la fase apropiada de las actuaciones, a petición de una de las partes.

2) Deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración de las audiencias y las reuniones del tribunal arbitral para examinar mercancías u otros bienes o documentos.

3) De todas las declaraciones, documentos o demás información que una de las partes suministre al tribunal arbitral se dará traslado a la otra parte. Asimismo, deberán ponerse a disposición de ambas partes los peritajes o los documentos probatorios en los que el tribunal arbitral pueda basarse al adoptar su decisión.

7.5 Ámbito de aplicación de la LACI

a) Materia

a.1 Arbitraje. No se define para evitar encasillar el objeto de la LACI, entonces entendemos por arbitraje un tercero imparcial que tiene facultades jurisdiccionales de resolución de una controversia.

a.2 Comercial. No es la comercialidad del ccom, y esto sí es definido por la ley.

a.3 Internacional. Esto está determinado por la ley, sin perjuicio de aquellos casos en que las partes hayan fijado la internacionalidad a través de Tratados Internacionales.

Art. 1.3 LACI. *Un arbitraje es internacional si:*

a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en Estados diferentes, o

b) Uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las partes tienen sus establecimientos:

i) El lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje;

ii) El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha, o

c) Las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un Estado.

a.4 Tratados Internacionales.

b) Territorio

b.1 Sede debe ser Chile.

b.2 Excepción (art 1.2). Casos en que hay que ejecutar un laudo extranjero, es decir, se aplican estas normas a laudos productos de un arbitraje que se lleva en el extranjero.

Artículo 1º LACI. - *Ámbito de aplicación.*

1) Esta ley se aplicará al arbitraje comercial internacional, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente en Chile.

2) Las disposiciones de esta ley, con excepción de los artículos 8º, 9º, 35 y 36, se aplicarán únicamente si el lugar del arbitraje se encuentra en el territorio nacional.

b.3 Todo esto sin perjuicio de arbitrajes establecidos por TTII.

c) Reservas de inarbitrabilidad. Son materias que no se pueden llevar a arbitraje.

Artículo 1.5 LACI. 5) Esta ley no afectará a ninguna otra ley en virtud de la cual determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje o se puedan someter a arbitraje únicamente de conformidad con disposiciones que no sean las de la presente ley.

7.5.1 Internacionalidad del arbitraje

a) Establecimientos en Estados distintos. Esto ya se contemplaba en la Convención de Viena en su artículo 1.

b) Uno de los siguientes lugares está situado fuera del Estado en que las partes tienen sus establecimientos.

- Lugar del arbitraje.
- Lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tiene una relación más estrecha.

c) Partes lo convienen expresamente. Acá no hay libertad absoluta, y el profesor cree que procede en ciertos casos, como por ejemplo que haya sociedades filiales de empresas extranjeras domiciliadas en Chile.

Límite: “no podría declararse internacional una controversia que no tenga efectivamente algún elemento extranjero de cierta relevancia o contravenga normas de orden público como por ejemplo las relativas a protección al consumidor” (mensaje de la ley).

7.5.2 Casos en que es lícito someterse a una jurisdicción extranjera

Fallo CS exequátur “State Street Bank c. Inversiones Errázuriz y otros” (2007)

Fue un exequátur de una sentencia emanada de un tribunal de NY que se pretendía ejecutar en Chile. Inversiones Errázuriz alegaba que no se podía ejecutar en NY porque ellos no se podían someter a otra jurisdicción.

Existencia de un contrato internacional:

- a) Elemento subjetivo, nacionalidad de las partes.
- b) Elemento objetivo. Independiente de la nacionalidad de las partes hay bienes o servicios en diferentes Estados, se desplazan o se ven afectados en sus consecuencias directa o indirectamente por la Convención celebrada en un Estado diverso. Por ejemplo, el contrato se ejecuta fuera del país.

Concepto francés de internacionalidad

CPC: “es internacional el arbitraje que involucra intereses del comercio internacional”.

No depende del derecho aplicable (fondo o procedimiento) sino que de la naturaleza de la operación que está en el inicio del litigio.

7.5.3 Problemas en relación a los establecimientos

Artículo 1º LACI.- Ambito de aplicación.

3) Un arbitraje es internacional si:

a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en Estados diferentes, o

b) Uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las partes tienen sus establecimientos:

i) El lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje;

ii) El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha, o

c) Las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un Estado.

4) A los efectos del numeral 3) de este artículo:

a) Si alguna de las partes tiene más de un establecimiento, el establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje.

b) Si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su residencia habitual.

La ley se pone en este caso en los artículos 1.3 a) y b).

- Si hay más de un establecimiento, el establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje.
- Si no hay establecimiento, será el lugar de residencia habitual.

7.5.4 Carácter comercial de la controversia

La LACI da una definición bastante amplia y adopta ejemplos de las notas explicativas de la Ley Modelo pero no los restringe.

No aplica acá el artículo 3 del ccom en cuanto a los actos de comercio.

Artículo 2 g) LACI. La expresión "comercial" debe interpretarse en un sentido amplio para que abarque todas las cuestiones que se plantean en las relaciones de esta índole, contractuales o no. Se comprenden dentro de éstas, por ejemplo, cualquier operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios, acuerdo de distribución, representación o mandato comercial, transferencia de créditos para su cobro, arrendamiento de bienes de equipo con opción de compra, construcción de obras, consultoría, ingeniería, concesión de licencias, inversión, financiación, banca, seguros, acuerdo o concesión de explotación, asociaciones de empresas y otras formas de cooperación industrial o comercial, transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima, férrea o por carretera.

7.6 Renuncia al derecho a objetar

Se refleja en el artículo 4 de la LACI que tiene como base los principios de eficiencia y eficacia del arbitraje. Se pierde el derecho a objetar cuando no se ha hecho de manera oportuna: si se que hay un vicio de nulidad, si no lo alego oportunamente no lo puedo hacer en fecha posterior. Ç

Artículo 4º LACI.- Renuncia al derecho de objetar. Se considerará que la parte que prosiga el arbitraje conociendo que no se ha cumplido alguna disposición de esta ley de la que las partes puedan apartarse o

algún requisito del acuerdo de arbitraje y no exprese su objeción a tal incumplimiento sin demora injustificada o, si se prevé un plazo para hacerlo, dentro de ese plazo, ha renunciado a su derecho a objetar.

7.7 Intervención de tribunales chilenos

¿Hasta dónde pueden intervenir los tribunales chilenos?

Artículo 5º LACI.- Alcance de la intervención del tribunal.

En los asuntos que se rijan por la presente ley, no intervendrá ningún tribunal salvo en los casos en que esta ley así lo disponga.

La regla general, del artículo 5 LACI, es la **NO INTERVENCIÓN**, esto porque las partes libremente han determinado que el asunto será conocido por árbitros. Pero se le dan a los tribunales ciertas facultades de colaboración, es decir, contribuyen a darle validez al acuerdo de arbitraje.

Artículo 6º LACI.- Tribunal para el cumplimiento de determinadas funciones de asistencia y supervisión durante el arbitraje.

Las funciones a que se refieren los artículos 11, numerales 3) y 4); 13, numeral 3); 14 y 16, numeral 3), serán ejercidas por el Presidente de la Corte de Apelaciones del lugar donde debe seguirse o se sigue el arbitraje y la del artículo 34, numeral 2), será desempeñada por la respectiva Corte de Apelaciones.

Entonces se establecen, de forma excepcional, ciertas **funciones de apoyo y asistencia**.

a) Actúa el presidente de la CA respectiva como juez de apoyo:

- 1) En la designación del árbitro a falta de acuerdo o por no hacerlo quien debía (arts 11.3 y 11.4).
- 2) Recusaciones (art 13.3).
- 3) Declaración de falta o imposibilidad del árbitro (art 14).
- 4) Decisión del tribunal arbitral de declararse competente (art 16.3). Se le pide al juez de apoyo que resuelva esta cuestión.

El kompetenz kompetenz supone una regla de prioridad porque quien primero resuelve sobre la competencia es el propio árbitro pero eso puede ser revisado por el tribunal de apoyo.

¿Cuál es la CA respectiva? Cuando se determina una sede también se designa una ciudad entonces eso determina la CA competente.

b) CA como tribunal de revisión

En este caso, conocen del recurso de nulidad del laudo (art. 34). Esto lo ve una sala de la Corte.

7.8 Definiciones y reglas de interpretación

Artículo 2º LACI.- Definiciones y reglas de interpretación.

Para los efectos de esta ley:

- a) "arbitraje" significa cualquier arbitraje con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente la que haya de ejercitarlo.
- b) "tribunal arbitral" significa tanto un solo árbitro como una pluralidad de árbitros.
- c) "tribunal" significa un órgano del sistema judicial de un país.

d) Cuando una disposición de esta ley, excepto el artículo 28, deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad entraña la de autorizar a un tercero, incluida una institución, a que adopte esa decisión.

e) Cuando una disposición de esta ley se refiera a un acuerdo que las partes hayan celebrado o que puedan celebrar o cuando, en cualquier otra forma, se refiera a un acuerdo entre las partes, se entenderán comprendidas en ese acuerdo todas las disposiciones del reglamento de arbitraje en él mencionado.

f) Cuando una disposición de esta ley, excepto la letra a) del artículo 25 y la letra a) del numeral 2) del artículo 32, se refiera a una demanda, se aplicará también a una reconvencción, y cuando se refiera a una contestación, se aplicará asimismo a la contestación a esa reconvencción.

g) La expresión "comercial" debe interpretarse en un sentido amplio para que abarque todas las cuestiones que se plantean en las relaciones de esta índole, contractuales o no. Se comprenden dentro de éstas, por ejemplo, cualquier operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios, acuerdo de distribución, representación o mandato comercial, transferencia de créditos para su cobro, arrendamiento de bienes de equipo con opción de compra, construcción de obras, consultoría, ingeniería, concesión de licencias, inversión, financiación, banca, seguros, acuerdo o concesión de explotación, asociaciones de empresas y otras formas de cooperación industrial o comercial, transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima, férrea o por carretera.

a) Arbitraje, tribunal arbitral y tribunal. La ley no define arbitraje en términos formales sino funcionales. Además, cuando se habla de "tribunales" se refiere al tribunal estatal.

b) Facultad de las partes de decidir libremente.

c) Referencia a reglamentos son parte de los acuerdos.

d) Alcance del concepto de demanda. Excepciones: arts. 25.a y 32.2.

Artículo 25 LACI.- Rebeldía de una de las partes. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando, sin invocar causa suficiente:

a) El demandante no presente su demanda con arreglo al numeral 1) del artículo 23, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones.

Artículo 32 LACI.- Terminación de las actuaciones.

2) El tribunal arbitral ordenará la terminación de las actuaciones arbitrales cuando:

a) El demandante retire su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y el tribunal arbitral reconozca un legítimo interés de su parte en obtener una solución definitiva del litigio.

b) Las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones.

c) El tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resultaría innecesaria o imposible.

e) Concepto de comercial (art 2.g).

7.9 Acuerdo de arbitraje

Artículo 7º LACI.- Definición y forma del acuerdo de arbitraje.

1) El "acuerdo de arbitraje" es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente.

La distinción de cláusula o compromiso depende de los criterios que hemos ya estudiado a nivel internacional (litigos actuales o futuros).

El acuerdo debe siempre constar por escrito.

Artículo 7º LACI.- *Definición y forma del acuerdo de arbitraje.*

2) *El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá que el acuerdo es escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, télex, telegramas u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo, o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por la otra. La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula compromisoria constituye acuerdo de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.*

Nuestra legislación acepta el concepto de cláusulas por referencia, es decir, cláusulas de un contrato que hacen referencia a otro contrato que sí tiene cláusula arbitral. Ej. un contrato marco tiene cláusula de arbitraje pero los contratos anexos no.

7.10 Recepción de comunicaciones

Nos referimos a la notificación.

Acá se da una paradoja porque no hay receptores o ministros de fe internacionales entonces podemos hacer notificaciones por medio de courriers.

Artículo 3º LACI.- *Recepción de comunicaciones escritas.*

1) *Salvo acuerdo en contrario de las partes:*

a) *Se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido entregada personalmente al destinatario o que haya sido entregada en su establecimiento, residencia habitual o domicilio postal; en el supuesto de que no se descubra, tras una indagación razonable, ninguno de esos lugares, se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido enviada al último establecimiento, residencia habitual o domicilio postal conocido del destinatario por carta certificada o cualquier otro medio que deje constancia del intento de entrega.*

b) *La comunicación se considerará recibida el día en que se haya realizado tal entrega.*

2) *Las disposiciones de este artículo no se aplican a las comunicaciones habidas en un procedimiento ante un tribunal.*

7.11 Demanda ante tribunal estatal

El principio general es que no debe intervenir el tribunal estatal por el artículo 5 de la LACI. ¿Pero qué pasa si se interpone demanda en tribunal estatal?

Artículo 8º LACI.- *Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo ante un tribunal.*

1) *El tribunal al que se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar, en el momento de presentar el primer escrito sobre el fondo del litigio, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible.*

2) *Si se ha entablado la acción a que se refiere el numeral 1) del presente artículo, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el tribunal.*

La única posibilidad que tiene de retener la competencia el tribunal estatal es si el acuerdo de arbitraje es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. Esto es una diferencia de otras legislaciones,

como por ejemplo en Perú se sanciona al juez que intervenga pese a la prohibición. En otros casos (Francia), el acuerdo debe ser “**manifiestamente** nulo, ineficaz o de ejecución imposible” (es tal el grado de nulidad que, ha dicho la jurisprudencia francesa, “cegue a los ojos”).

El procedimiento arbitral no se detiene aunque se discuta una excepción de incompetencia en sede ordinaria, o se discuta sobre la validez del acuerdo de arbitraje. El demandado en esa causa puede iniciar el procedimiento arbitral y no se suspende este último.

7.12 Medidas precautorias en la ley

Se tratan en los artículos 9 y 17. La ley modelo en su modificación de 2006, modificó todo este régimen.

- a) Pueden ser prejudiciales precautorias o propiamente tales.

Artículo 9º LACI.- Acuerdo de arbitraje y adopción de medidas provisionales por el tribunal.

No será incompatible con un acuerdo de arbitraje que una parte, ya sea con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicite de un tribunal la adopción de medidas cautelares provisionales ni que el tribunal conceda esas medidas.

Artículo 17 LACI.- Facultad del tribunal arbitral de ordenar medidas provisionales cautelares.

Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a petición de una de ellas, ordenar a cualquiera de las partes que adopte las medidas provisionales cautelares que el tribunal arbitral estime necesarias respecto del objeto del litigio. El tribunal arbitral podrá exigir de cualquiera de las partes una garantía apropiada en conexión con esas medidas.

- b) Interpretación amplia: gama variada y no limitativa. En el fondo se admite todo aquello que tiene por objeto asegurar el resultado del juicio o de la prueba. Ahora, el artículo 17, si bien es genérico, nos limita a medidas que afecten a terceros y aquellas que se remiten al objeto del litigio.
- c) Puede recurrirse al tribunal ordinario nacional o de otro país si no esta constituido el tribunal arbitral.
- d) La LACI y la Ley Modelo le dan facultades a los árbitros para dictar y **ejecutar** medidas precautorias.

¿Significa una renuncia al arbitraje solicitar una precautoria ante un tribunal estatal? No, porque puedo pedir una prejudicial a un tribunal estatal sin que ello sea renuncia al arbitraje.

1) Requisitos mínimos

- a) Fumus boni iuris. Es la apariencia de buen derecho.
- b) No es un ante-juicio (prejuzgamiento). Se considera en el mérito la solicitud, por eso los jueces deben considerar el efecto que producirá esa medida.
- c) Periculum in mora. Es decir, de no concederse los perjuicios que puede provocar, son mayores que aquellos que se van a producir al imponer la medida.

Los tribunales arbitrales pueden dictar sus decisiones de diferentes maneras; a través de laudos (finales o provisionales) u órdenes procesales. Normalmente las medidas precautorias son órdenes,

lo que genera un problema respecto del cumplimiento ya que las órdenes no pueden ejercerse por medio de la fuerza pública y sobretodo, ello se agrava cuando se refiere a la ejecución de la medida precautoria emanada de tribunal arbitral en un territorio distinto, ya que por ejemplo no podrían acogerse a la Convención de NY porque ella se refiere a sentencias definitivas (entonces no podemos pedir que se ejecuten laudos parciales u órdenes procesales en virtud de esta Convención). Por lo tanto desde un punto de vista práctico, lo que convendría ahí sería solicitar la medida ante el tribunal estatal que se pretende ejecutar.

Desde el año 2012, se incorporó la figura del **árbitro de emergencia**, y para acceder a él como único requisito se requiere que el acuerdo de arbitraje se haya suscrito con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley. **Y ¿qué es?** es un tribunal arbitral especial, constituido únicamente para conocer de una medida prejudicial precautoria, constituido aún antes del tribunal arbitral que conocerá del asunto (esto procede mientras se designa al tribunal arbitral).

La mayor parte de los reglamentos institucionales recogen la figura de este árbitro de emergencia.

2) Ejecución de medidas cautelares en otras jurisdicciones

Calificación jurídica de la resolución arbitral: laudo provisorio o auto procesal. Esta determinación genera problemas prácticos como ya vimos. La ley peruana permite que la sentencia del árbitro se pueda ejecutar en materia de precautorias.

3) Definición restrictiva de la LACI: art 17

Hay una limitación a medidas que afectan a terceros, y medidas que se remitan al objeto del litigio.

4) Normas sobre Medidas cautelares en la Ley CNUDMI (enmiendas 2006)

Artículo 17 Ley Modelo. *Toda medida temporal, otorgada en forma o no de laudo, por la que, en cualquier momento, previo a la emisión del laudo, por el que se dirima definitivamente la controversia, el tribunal ordene a una de las partes que (...)*

Luego menciona los requisitos y el objeto de la medida:

- 1) Mantener o restablecer el status quo. Por ejemplo que no se cobre una boleta de garantía.
- 2) Impedir algún daño actual o inminente.
- 3) Proporcionar medios para preservar bienes que permitan ejecutar el laudo.
- 4) Preservar elementos de prueba.

Respecto a las condiciones de otorgamiento (art 17A de la ley modelo), se establecen:

- 1) Inminencia del daño, más grave que el que pueda sufrir la afectada.
- 2) Posibilidad razonable de obtener la demanda, lo que no constituye perjuicio.

Órdenes preliminares (art 17B)

- 1) Se diferencian de las medidas cautelares porque se otorgan sin dar aviso a la otra parte (ex parte).

- 2) El tribunal puede otorgarla si considera que la notificación previa entraña riesgo de que se frustre la medida.
- 3) Las condiciones de otorgamiento son las mismas que las señaladas en el art 17A.

7.13 Composición del tribunal

Si las partes nada dicen, el tribunal se compondrá de 3 árbitros (en arbitraje doméstico sería un árbitro).

En cuanto a la designación se hace según las partes decidan; cada parte elige a un árbitro y el tercero es elegido de común acuerdo, siendo este último el pdte del tribunal.

1) Forma de designación

La nacionalidad del árbitro nunca va a ser obstáculo para su designación.

Las partes eligen al árbitro libremente en el procedimiento de designación. Si no hay acuerdo, cada parte nombra un árbitro y ellos nombran al tercero.

¿Cuándo entra el juez de apoyo? (pdte CA respectiva). Entrará cuando:

- Los árbitros no puedan ponerse de acuerdo en la designación del tercero.
- Una parte no ha nombrado a su árbitro.
- Un tercero⁴ o la institución de arbitraje no cumple su misión.

La decisión del juez de apoyo es inapelable.

Ahora, hay que tener claro que no porque la parte nombre a un árbitro, este se transforma en su mandatario ni su vocero.

2) Consideraciones para designar el árbitro

Artículo 11 LACI.- *Nombramiento de los árbitros.*

1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no será obstáculo para que esa persona actúe como árbitro.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 4) y 5) de este artículo, las partes podrán acordar libremente el procedimiento para el nombramiento del árbitro o los árbitros.

3) A falta de tal acuerdo:

a) En el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro y los dos árbitros así designados nombrarán al tercero; si una parte no nombra al árbitro dentro de los treinta días del recibo de un requerimiento de la otra parte para que lo haga, o si los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los treinta días contados desde su nombramiento, la designación será hecha, a petición de una de las partes, por el Presidente de la Corte de Apelaciones correspondiente al lugar donde deba seguirse el arbitraje.

b) En el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del árbitro, éste será nombrado, a petición de cualquiera de las partes, por el Presidente de la Corte de Apelaciones correspondiente al lugar donde deba seguirse el arbitraje.

⁴ En los arbitrajes CNUDMI, que tiene su reglamento tienen en él una autoridad de nominación que designa al árbitro.

4) Cuando en un procedimiento de nombramiento convenido por las partes:

- a) Una parte no actúe conforme a lo estipulado en dicho procedimiento, o
- b) Las partes, o dos árbitros, no puedan llegar a acuerdo conforme al mencionado procedimiento, o
- c) Un tercero, incluida una institución, no cumpla una función que se le confiera en dicho procedimiento, cualquiera de las partes podrá solicitar al Presidente de la Corte de Apelaciones correspondiente al lugar donde deba seguirse el arbitraje que adopte la medida necesaria, a menos que en el acuerdo sobre el procedimiento de nombramiento se prevean otros medios para conseguirlo.

5) Toda decisión sobre las cuestiones encomendadas en los numerales 3) ó 4) de este artículo al Presidente de la respectiva Corte de Apelaciones será inapelable. Al nombrar un árbitro, el tribunal u otra autoridad tendrá debidamente en cuenta las condiciones requeridas para un árbitro por el acuerdo entre las partes y tomará las medidas necesarias para garantizar el nombramiento de un árbitro independiente e imparcial. En el caso de árbitro único o del tercer árbitro, tendrá en cuenta asimismo la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta a la de las partes.

7.14 Recusación del árbitro.

En este ámbito hay un deber esencial que es el **deber de revelación** (art 12.1). Esta es una obligación permanente.

Artículo 12 LACI.- Motivos de recusación.

1) La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. El árbitro, desde el momento de su nombramiento y durante todas las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias a las partes, a menos que ya les haya informado de ellas.

1) Requisitos

- a) Duda justificadas sobre su imparcialidad o independencia
- b) Falta de cualificaciones convenidas por la partes. Se refiere al no cumplir con los requisitos que señalen las partes (art 12.2), no en cuanto a las competencias técnicas.

Artículo 12 LACI.- Motivos de recusación.

2) Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia, o si no posee las cualificaciones convenidas por las partes. Una parte sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya participado, por causas de las que haya tenido conocimiento después de efectuada la designación.

2) Procedimiento de recusación

- Las partes tienen libertad para determinarlo (en caso de reglamento, él se entiende por “aquellos que las partes convinieron”), y si nada han dicho se deberá comunicar por escrito al tribunal dentro de los 15 días siguientes, al conocimiento de la causal.
- El tribunal decidirá de la recusación, salvo en caso de renuncia del árbitro o que se acepte la recusación de la contraparte. No se excluye al árbitro objeto de la recusación (incluso aunque sea un tribunal unipersonal), como sucede con el reglamento CIADI.
- Si el tribunal la rechaza, tiene 30 días para pedir al pdte de la CA que resuelva la cuestión.

Para que no sea una “táctica de guerrilla” y que se obstaculice de esta forma el proceso arbitral, se establece que mientras se tramita la recusación, se sigue adelante con el juicio e incluso puede dictar sentencia.

7.15 Falta de árbitros y sustitución

Se indican causales de cesación del cargo del árbitro en el art 14.

Artículo 14 LACI.- Falta o imposibilidad de ejercicio de las funciones.

1) Cuando un árbitro se vea impedido de jure o de facto en el ejercicio de sus funciones o por otros motivos no las ejerza dentro de un plazo razonable, cesará en su cargo si renuncia o si las partes acuerdan su remoción. De lo contrario, si subsiste un desacuerdo respecto a cualquiera de esos motivos, cualquiera de las partes podrá solicitar del Presidente de la Corte de Apelaciones correspondiente al lugar donde deba seguirse el arbitraje una decisión que declare la cesación del mandato, decisión que será inapelable.

2) Si, conforme a lo dispuesto en este artículo o en el numeral 2) del artículo 13, un árbitro renuncia a su cargo o una de las partes acepta la terminación del mandato de un árbitro, ello no se considerará como una aceptación de la procedencia de ninguno de los motivos mencionados en este artículo o en el numeral 2) del artículo 12.

Las partes pueden determinar las causales por las cuales se entiende faltar el árbitro, pero si entre ellas no hay acuerdo, decidirá el pdte de la CA, sin ulterior apelación.

En caso de sustitución, se replica el procedimiento de designación del artículo 15 de la LACI.

7.16 Competencia del tribunal

En materia de arbitraje internacional se consagra el **principio kompetenz-kompetenz** (regla de PRIORIDAD), incluso extendiéndose a la existencia o validez de la cláusula. Ahora, sus excepciones, son:

a) Incompetencia del tribunal

- El plazo para alegar la incompetencia: el momento de presentar la contestación de la demanda.
- La participación en la designación del tribunal no entraña reconocimiento de la competencia del árbitro.

b) Si el tribunal se excede de su mandato deberá alegarse tan pronto como se conozca la situación.

Además, se consagra expresamente la **autonomía del acuerdo arbitral**.

Todas las cuestiones sobre la competencia deben plantearse como cuestión previa (antes de entrar al fondo del asunto) o en el laudo definitivo:

- Competencia del tribunal como cuestión previa: se tienen 30 días para oponerse ante el pdte de la CA y su decisión es inapelable.
- Mientras este pendiente la cuestión se continua la tramitación.

7.17 Sustanciación de las actuaciones arbitrales

Como ya sabemos, el principio rector del arbitraje, de todo procedimiento y de sobretodo el arbitraje internacional **es el trato equitativo de las partes** (art. 18). Ahora, ¿qué es lo que dice la Ley?, dice que deberá tratarse con igualdad a las partes y darse a cada una de ellas plena oportunidad para hacer valer sus derechos, esto es de nuevo una expresión de lo que es el principio de la bilateralidad de la audiencia o el principio contradictorio.

Artículo 18 LACI.- *Trato equitativo de las partes. Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos.*

1. Determinación del procedimiento

¿Cómo se determina el procedimiento?, volvemos a ver la regla general que establece la ley, primero son las partes en que se define cómo se va a llevar el procedimiento, entonces el principio es la **libertad para determinarlo**.

Entonces aquí entra a jugar el Artículo 19, ¿cuál es el principio general? El 19 número 1 nos dice que primero estaremos a la voluntad de las partes, ellas son las que determinan el procedimiento.

Ahora, el límite de la libertad de las partes está dado por la ley. No podría darse el caso en que las partes establezcan, por ejemplo, que solo se va oír a alguna de ellas (por el principio rector de trato equitativo).

Artículo 19 LACI.- *Determinación del procedimiento.*

1) *Con sujeción a las disposiciones de esta ley, las partes tendrán libertad para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones.*

2) *A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto en esta ley, dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye la de determinar la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas.*

A falta de determinación de las partes, será el procedimiento que determine el tribunal. ¿Alcances de esta facultad del tribunal (art. 19)? esto lo dice claramente el Artículo 19, esta competencia que le corresponde al árbitro para determinar:

- Admisibilidad de las pruebas
- Pertinencia de las pruebas
- Valor de las pruebas

2. Lugar del arbitraje.

Es importante y esencial a lo que es el concepto de Arbitraje Comercial Internacional la definición de lugar del arbitraje (art. 20), también se habla de Estévez del arbitraje. ¿Por qué? Porque las partes pueden determinar libremente la sede del arbitraje.

Esta ley aplica cuando se escoja como sede a Chile, por regla general.

Artículo 20 LACI.- *Lugar del arbitraje.*

1) *Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje, atendidas las circunstancias del caso, inclusive las conveniencias de las partes.*

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral precedente, el tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones entre sus miembros, para oír a los testigos, a los peritos o a las partes, o para examinar mercancías u otros bienes o documentos.

A falta de acuerdo, determinará el propio tribunal y es la ley misma la que señala cuáles son esos criterios. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral precedente, el tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones entre sus miembros.

En caso de no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje, atendidas las circunstancias del caso, inclusive las conveniencias de las partes.

Ahora, ¿cuál es la importancia de determinar la sede del arbitraje? Nos va a fijar cuál va a ser el tribunal de apoyo. Lo anterior por el “apoyo” del presidente de la corte de apelaciones respectiva a ese lugar, y también nos va a determinar cuál va a ser el tribunal de la anulación (la Corte de Apelaciones respectiva). Esto es lo que define el lugar del arbitraje.

Pero se hace la distinción entre el **lugar del arbitraje** y la **sede de las reuniones** (el lugar donde se pueden desarrollar las reuniones) diciendo que salvo acuerdo en contrario las partes, podrá desarrollarse en cualquier parte, y ahí es donde va a poder presentarse el testigo y revisarse las pruebas. Esto también es relevante por lo que hoy día se está viendo en litigación online.

3. Inicio de actuaciones arbitrales.

¿Cuándo se inician las actuaciones arbitrales? Lo dice el art. 21. Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales respecto de una determinada controversia se iniciarán en la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter esa controversia a arbitraje, es decir, desde la solicitud de arbitraje y no desde la demanda arbitral.

Artículo 21 LACI.- *Iniciación de las actuaciones arbitrales.*

Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales respecto de una determinada controversia se iniciarán en la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter esa controversia a arbitraje.

A partir de la recepción de la solicitud de arbitraje comienzan a contarse los plazos.

4. Idioma

Las partes son las que van a definir, también es muy común por ejemplo que tengamos un tribunal que dice que el procedimiento se llevará en español, pero los documentos se podrán presentar indistintamente sin necesidad por ejemplo de traducción, en un idioma distinto, por ejemplo en inglés, esto es muy común cuando tenemos contratos que han sido generados justamente en otro idioma.

Eso a pesar de que nos establece un procedimiento que va a ser en español nos va a exigir que justamente los árbitros tengan conocimiento en otro idioma.

Puede haber uno o más idiomas, determinado por las partes. A falta de acuerdo del idioma, lo va a determinar el tribunal:

Aplicación: Salvo acuerdo:

- Escritos de parte
- Audiencias
- Cualquier laudo, decisión o comunicación que emita el tribunal.

Además, el tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier prueba documental vaya acompañada de una traducción al idioma o los idiomas convenidos por las partes o determinados por el tribunal arbitral. Esto lo establece el Artículo 22 párrafo 2.

5. Demanda y contestación.

Artículo 23 LACI.- *Demanda y contestación.*

1) Dentro del plazo convenido por las partes o determinado por el tribunal arbitral, el demandante deberá alegar los hechos en que se funda la demanda, los puntos controvertidos y el objeto de la demanda, y el demandado deberá responder a los planteamientos alegados en la demanda, a menos que las partes hayan acordado otra cosa respecto de los elementos que la demanda y la contestación deban necesariamente contener. Las partes podrán aportar, al formular sus alegaciones, todos los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar.

2) Salvo acuerdo en contrario de las partes, en el curso de las actuaciones arbitrales cualquiera de las partes podrá modificar o ampliar su demanda o contestación, a menos que el tribunal arbitral considere improcedente esa alteración en razón de la demora con que se ha hecho.

Se debe distinguir entre la solicitud de arbitraje y la demanda; la **solicitud del arbitraje**, no cierra cuáles van a ser las pretensiones finales sino que netamente lo que hace es comunicarle a la otra parte, sea directamente o por intermedio de una institución que hay un procedimiento arbitral que se va a iniciar y la distinción con la **demanda arbitral** que es aquella en la que fijamos justamente cuáles van a ser los puntos sobre los cuales se va a ejercer la acción, es decir, cuáles van a ser las pretensiones finales de las partes.

Las partes o el tribunal deben fijar un plazo para presentar la demanda y contestarla. Esto es lo que podríamos determinar que se hace en una *audiencia donde se fijan las bases del procedimiento y el calendario procesal*.

Las partes determinan elementos que debe contener, es decir, no nos atenemos a las formalidades procesales de cada legislación interna respecto a sus demandas. Ahora, lo que sí tiene que tener porque es la norma subsidiaria, al menos son:

- La determinación de los hechos en que se funda
- Puntos controvertidos
- Objeto de la demanda

Las partes tienen la posibilidad de ampliar o modificar la demanda o contestación, salvo que el tribunal estime lo contrario en razón de la demora con la que se ha hecho la modificación.

6. Audiencias y actuaciones por escrito

El tribunal decide sobre la pertinencia de audiencias orales y su momento, cuándo se van a desarrollar. ¿Cuál es el límite? Siempre va a estar definido por la voluntad de las partes.

Lo único que se pide es que haya una notificación anticipada si por ejemplo se presenta un escrito o se cita a una audiencia y debe ser suficiente en cuanto a su contenido para que tome conocimiento la parte interesada, y con esto se garantiza la bilateralidad que es nuestro principio fundamental: el principio de contradicción y de bilateralidad.

Artículo 24 LACI. *Audiencias y actuaciones por escrito.*

1) *Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias para la presentación de pruebas o para alegatos orales, o si las actuaciones se sustanciarán sobre la base de documentos y demás pruebas. No obstante, a menos que las partes hubiesen convenido que no se celebrarían audiencias, el tribunal arbitral celebrará dichas audiencias en la fase apropiada de las actuaciones, a petición de una de las partes.*

2) *Deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración de las audiencias y las reuniones del tribunal arbitral para examinar mercancías u otros bienes o documentos.*

3) *De todas las declaraciones, documentos o demás información que una de las partes suministre al tribunal arbitral se dará traslado a la otra parte. Asimismo, deberán ponerse a disposición de ambas partes los peritajes o los documentos probatorios en los que el tribunal arbitral pueda basarse al adoptar su decisión.*

Las audiencias orales se usan normalmente en el common law, lo que demuestra el carácter unitario de esta ley en cuanto a dichos sistemas jurídicos.

7. Rebeldía

Artículo 25 LACI.- *Rebeldía de una de las partes. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando, sin invocar causa suficiente:*

a) *El demandante no presente su demanda con arreglo al numeral 1) del artículo 23, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones.*

b) *El demandado no presente su contestación con arreglo al numeral 1 del artículo 23, el tribunal arbitral continuará las actuaciones, sin que esa omisión se considere por sí misma como una aceptación de las alegaciones del demandante.*

c) *Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas documentales, el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones y dictar el laudo basándose en las pruebas de que disponga.*

Se reconoce la posibilidad de que haya rebeldía, en este caso **del mismo demandante**, como es él el que está llamado a presentar esa demanda, a falta de demanda se entiende que va a terminar el arbitraje porque que no se puede estar eternamente con un proceso abierto.

- Efecto: terminación del arbitraje

En cambio, cuando hay una **rebeldía del demandado**, lo que ocurre es que continúa el proceso

- Efecto: continuación del procedimiento

¿Puede faltar una de las partes a una audiencia o que no presente que no presente pruebas?, podría ser, y en ese caso se va a continuar, o sea no va a ser un obstáculo justamente para la dictación del laudo, porque podría darse el caso que el potencial demandado no comparezca en todo el proceso y evidentemente va a tener que hacerlo probablemente cuando tenga un recurso de anulación, y si tuviéramos que esperarlo a este litigante rebelde (el demandado) tendríamos que suspender el procedimiento, cosa que va contra los mismos valores y principios de esta

legislación que busca que el arbitraje sea eficiente en cuanto a su tiempo, o sea que no se dilate más allá de la cuenta, y que se eficaz, cuando hablamos de eficacia en el arbitraje comercial internacional estamos refiriéndonos a una eficacia respecto del resultado, que el laudo sea ejecutado.

- Efecto: Continuación y dictación con las pruebas que se tengan.

8. Peritajes.

Artículo 26 LACI.- *Nombramiento de peritos por el tribunal arbitral.*

1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral:

a) Podrá nombrar uno o más peritos para que le informen sobre materias concretas que determinará el tribunal arbitral.

b) Podrá solicitar a cualquiera de las partes que suministre al perito toda la información pertinente o que le presente para su inspección todos los documentos, mercancías u otros bienes pertinentes, o le proporcione acceso a ellos.

2) Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando una parte lo solicite o cuando el tribunal arbitral lo considere necesario, el perito, después de la presentación de su dictamen escrito u oral, deberá participar en una audiencia en la que las partes tendrán oportunidad de hacerle preguntas y de presentar peritos para que informen sobre los puntos controvertidos.

- El tribunal podrá pedir informe de peritos
- Puede pedir a las partes que suministre información al perito (discovery). Discovery es el sistema probatorio del derecho anglosajón, en que contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestro derecho, lo que ocurre es que las partes están obligadas a entregar toda la información que tienen referidas al caso y ahí será resorte de la contra parte, demandado o demandante según el caso, de revisar uno a uno esos documentos.
- Participación del perito en audiencias (cross examination) ¿Cómo participa el perito de las audiencias? Puede efectivamente participar y ahí en ese caso va a ser interrogado por el mismo tribunal respecto de su informe y por las mismas partes.

Es interesante acá también que cuando se pide un informe pericial, más que hacerlo en términos generales, lo que debería hacer primero el tribunal arbitral es establecer cuáles son los puntos respecto a los cuales va a informar. La idea no es solamente establecer puntos de prueba sino que se le deben formular preguntas. Ej. si el material usado en la construcción hubiese sido otro, qué habría pasado.

Es importante que haga un dictamen respecto de lo que se le pregunta y no de opiniones jurídicas. Pero no califica jurídicamente el hecho porque eso le corresponde al árbitro y eso podría desmerecer su propia prueba como perito.

Sumado a todo lo anterior, se consagra la posibilidad de acudir a cualquier tribunal de Chile para la prueba (art. 27)

Artículo 27 LACI.- *Asistencia de los tribunales para la práctica de pruebas.*

El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con la aprobación del tribunal arbitral podrá pedir la asistencia de un tribunal competente de Chile para la práctica de pruebas. El tribunal podrá atender dicha solicitud dentro del ámbito de su competencia y de conformidad con las normas que le sean aplicables sobre medios de prueba.

7.18 Laudo arbitral

1. Clasificación

- 1) Laudo final. El laudo es la sentencia definitiva; hay una decisión final y total sobre las materias definitivas y es vinculante para las partes.

En sus primeros trabajos preparatorios de la ley modelo, la CNUDMI, se estableció que vamos a hablar de *laudo final como aquel que resuelve todas aquellas cuestiones que han sido sometidas al tribunal*, pero en el proceso pueden darse distintas cuestiones como también lo vemos en nuestro proceso interno cuando tenemos una sentencia que tiene carácter de interlocutoria, que resuelve un incidente o pone término al juicio haciendo imposible su continuación.

Qué ocurre por ejemplo si yo alego la incompetencia del tribunal, el tribunal tiene 2 alternativas, puede resolverlo antes, una cuestión previa, o bien realizar todo al final en una sola sentencia, esto es lo que se llama bifurcar el procedimiento: por una parte nos vamos a enfocar en la discusión de lo que es la competencia y en el otro vamos a revisar el fondo una vez que ya resolvamos la competencia. Claramente si tenemos una decisión respecto de la competencia podría ser calificado eventualmente como laudo final, porque se resuelve de manera definitiva respecto a la competencia, sin perjuicio que ya lo vimos respecto al tribunal de apoyo, este pudiera modificar aquella decisión.

- 2) Laudos parciales. También tenemos laudos parciales y laudos interinos o interlocutorios, están todos englobados en este concepto, generalmente en doctrina, que puede ser final en cuanto a su naturaleza.

Puede ser final en cuanto a su naturaleza pero se refiere a una cuestión precisa del arbitraje. Ej. competencia.

Y aquí es donde tenemos la confusión siempre y es que hay otro sector de la doctrina que dice que esos laudos son parciales o interinos o interlocutorios porque no son definitivos, no son finales, el asunto de la competencia podría ser final pero podría no serlo en la medida que el tribunal de apoyo lo modifique. También podría ser respecto de las medidas precautorias, una medida precautoria es una decisión que no es permanente en su definición, que va a ser provisoria por lo tanto algunos lo sostienen como que sería un laudo parcial, interino.

Puede ser de orden sustantivo o procesal.

- 3) Laudos por acuerdo entre partes. Aquí es donde entramos y lo vamos a ver más adelante con el tema de las transacciones.

Pueden terminar los litigios por una transacción, o por un avenimiento y en materia internacional tenemos un instrumento de movilidad que es la convención de Nueva York.

La convención de NY nos permite llevar este laudo, cumpliéndose requisitos formales a distintas jurisdicciones para ejecutarlo, la idea es evitar doble control de cada uno de los órganos jurisdiccionales que participan en esta gestión, entonces si nosotros celebrásemos una transacción, la transacción por definición es un contrato, ¿le pone termino al juicio?, sí le pone termino al juicio, pero ¿tiene fuerza ejecutiva? Depende, va a tener fuerza ejecutiva y de manera directa en el mismo lugar donde se celebró porque va a cumplir esas formalidades y puede efectivamente servir como título ejecutivo si se celebró por escritura pública pero si yo quisiera ejecutarlo en un lugar distinto de aquel en que se celebró o aquel en donde naturalmente pensamos en un principio que podría ejecutarse, claramente no vamos a poder ejecutar una transacción celebrada a menos que demandemos.

Para evitar un nuevo litigio, hay que transformar el acuerdo en una sentencia. No es que hago una transacción y acudo al tribunal, sino que toda la transacción será la sentencia y por eso hablamos de laudo acuerdo entre partes.

Aquí no tenemos una transacción que se aprueba, sino que el laudo está compuesto por los acuerdos, y eso le da justamente esa sentencia arbitral la posibilidad de ser ejecutada sin tener que iniciar un procedimiento ejecutivo de acuerdo a las leyes del lugar y sin tener que demandar el cumplimiento del contrato de transacción.

También tenemos otras resoluciones que no son laudos:

- Órdenes procesales.
- Órdenes para medidas cautelares.
- Órdenes que derivan de los acuerdos entre partes.

2. Ley aplicable al fondo.

Este es un elemento que es esencial cuando estamos hablando de un arbitraje comercial internacional.

Aunque tengamos un arbitraje con sede en Chile, no necesariamente ese tribunal está obligado a aplicar la ley chilena de cuanto a la decisión, esto es lo que se llama Ley aplicable al fondo, es decir, *bajo que perspectiva jurídica y bajo qué legislación los árbitros deberán fallar.*

Nuestra legislación cuando hablamos de Ley aplicable al fondo, no habla de ley aplicable el artículo 28 sino dice ***normas aplicables al fondo de*** litigio, y es una elección que no viene porque sí, lo que se quiso hacer por la comisión de naciones unidas para el derecho mercantil internacional (CNUDMI) y que nosotros hemos adoptado, es la posibilidad de que no necesariamente nos enfoquemos oelijamos un foro jurídico, una legislación estatal para poder determinar quién gana o pierde en el arbitraje *sino que hablamos de **normas** que es un sentido mucho más amplio*, es decir, podríamos no tener ley material, podríamos aplicar usos comerciales que también es una manera (de hecho, hay muchos contratos que ustedes van a ver carácter internacional, que se va a resolver de acuerdo a los usos y costumbres internacionales o mercantiles, eso podría ser una norma y ser válido para efectos del contrato).

Artículo 28 LACI.- Normas aplicables al fondo del litigio.

1) El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes como aplicables al fondo del litigio. Se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto de leyes.

Cuando hablamos de normas de derecho ¿podemos hacerlo referente al Estado?, sí, podemos decir la ley de Chile, la ley de Estado de Nueva York pero también podemos determinarlo o remitirnos a un cuerpo normativo convencional por ejemplo la UNIDROIT, que tiene unos principios UNIDROIT para el derecho de los contratos (reunifica distintos principios jurídicos de ambos sistemas tanto *common law* y el *civil law* en este cuerpo normativo) y yo podría remitirme a eso pero ¿por qué?, lo que prima siempre es la ley del contrato y podría tomar todo ese cuerpo normativo e incluso las legislaciones de otro Estado e incorporarlas directamente en mi contrato y sería parte de esta ley del contrato pero cuando nos habla de normas de derecho lo hace en términos amplios y podríamos justamente establecer estos principios generales que están determinados por comisiones.

Ahora si las partes no decidieran cual va a ser la ley aplicable al fondo, son los árbitros los que van a determinar la decisión conforme a las normas de conflicto de leyes que estimen más apropiadas al caso, es decir, que toman aquellos elementos internacionales del caso y se aplican a esa disposición en concreto que está en riesgo o está en discusión dentro de este contrato, y hay una prohibición a actuar como amigable componedor o como arbitro de equidad, porque solamente pueden hacerlo cuando las partes ya han permitido hacerlo.

Fallará en equidad sólo con autorización expresa de las partes

3. Cómo se adoptan las decisiones

Las decisiones del tribunal se adoptan por mayoría, pero ahora ¿cómo adoptamos decisiones? Se adoptan por mayoría y aquí hay una particularidad:

El árbitro presidente dirime con su voto sólo en cuestiones de procedimiento, porque obviamente si es por mayoría el árbitro va a concurrir con uno de los dos votos en caso de que sea así. Es difícil ver sentencias arbitrales que tengan disidencia, normalmente para justamente evitar anulaciones del laudo, los árbitros terminan poniéndose de acuerdo. Pero el juez presidente podría tener la posibilidad de decidir por sí solo cuestiones de procedimiento, pero para eso tiene que estar autorizado por las partes. Así nos dice el artículo 29 de la Ley del arbitraje comercial internacional.

Artículo 29 LACI.- *Adopción de decisiones cuando hay más de un árbitro. En las actuaciones arbitrales en que haya más de un árbitro, toda decisión del tribunal arbitral se adoptará, salvo acuerdo en contrario de las partes, por mayoría de votos de todos los miembros. Sin embargo, el árbitro presidente podrá decidir cuestiones de procedimiento, si así lo autorizan las partes o todos los miembros del tribunal.*

A. Adopción de decisiones cuando hay más de un árbitro.

En las actuaciones arbitrales en que haya más de un árbitro, toda decisión del tribunal arbitral se adoptará, salvo por el acuerdo contrario de las partes, por la mayoría de votos de todos los miembros. Sin embargo, el árbitro presidente podrá decidir cuestiones de procedimiento si así lo autorizan las partes o todos los miembros del tribunal. Es decir, la regla general va a ser por

mayoría, la excepción podría darse, por ejemplo, en cuestiones de procedimiento que el árbitro presidente o el presidente decida como tribunal y personal, pero para eso tiene que estar habilitada por las mismas partes.

B. Transacción y laudo

Si las partes llegan a transacción, se da por terminado el procedimiento. Si lo piden ambas partes, puede constar la transacción en forma de laudo arbitral (laudo por acuerdo de partes).

El laudo por acuerdo de partes tiene la misma forma, naturaleza y efectos de cualquier laudo arbitral. De esta manera, teniendo la forma de laudo, tiene los mismos efectos como si fuera un laudo dictado sin llegar a acuerdo.

4. Forma y contenido del laudo (art. 31)

- Escrituración y firma de todos los árbitros.
- Motivación Si el laudo no se motiva, es causal de anulación, a menos que haya laudo por acuerdo de partes.
- Fecha y lugar del arbitraje.
- Notificación Se entiende que se dicta dentro de plazo cuando los árbitros firman dentro de plazo: da lo mismo que se notifique después.

Artículo 31 LACI.- Forma y contenido del laudo.

1) El laudo se dictará por escrito y será firmado por el árbitro o los árbitros. En actuaciones arbitrales con más de un árbitro bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del tribunal arbitral, siempre que se deje constancia de las razones de la falta de una o más firmas.

2) El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido en otra cosa o que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo 30.

3) Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje determinado de conformidad con el numeral 1) del artículo 20. El laudo se considerará dictado en ese lugar.

4) Después de dictado el laudo, el tribunal lo notificará a cada una de las partes mediante entrega de una copia firmada por los árbitros de conformidad con el numeral 1) de este artículo.

5. Ley aplicable

- Las partes eligen las “normas de derecho” que quieren que se aplique al fondo del litigio.
- Si no hay acuerdo, el tribunal aplicará las normas de conflicto que estime aplicables.
- Resolverá ex aequo et bono sólo si las partes lo autorizaron expresamente.
- En todos los casos decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y los usos mercantiles (lex mercatoria).

Normas de derecho vs. ley sustantiva

- Permite no sólo aplicar la legislación interna de un Estado
- Se pueden elegir normas internacionales: Principios UNIDROIT, Convención de Viena sobre compras internacionales, etc.
- Soluciones en Derecho internacional privado:

a) Norma de policía. Desconoce el elemento internacional y aplica la norma interna. Son disposiciones irrenunciables por las partes.

b) Norma material: reconoce el elemento internacional del caso y damos solución de fondo. Le da una solución substancial al asunto: p.ej: Art. 1028 CC sobre forma de otorgamiento del testamento por extranjero en Chile.

c) Norma de conflicto: Reconoce el elemento internacional del caso y lo soluciona indirectamente, entregando la solución al derecho que aparece más vinculado con la situación planteada. Art. 955 CC: la sucesión se rige por la ley del último domicilio del causante.

7.19 Terminación de las actuaciones y funciones del tribunal

Distinción entre actuaciones y funciones del tribunal. El tribunal puede terminar su labor pero no termina de realizar ciertos actos.

a) Cese de actuaciones:

Artículo 32 LACI.- Terminación de las actuaciones.

1) Las actuaciones arbitrales terminan con el laudo definitivo o por una orden del tribunal arbitral dictada de conformidad con el numeral 2) de este artículo.

2) El tribunal arbitral ordenará la terminación de las actuaciones arbitrales cuando: a) El demandante retire su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y el tribunal arbitral reconozca un legítimo interés de su parte en obtener una solución definitiva del litigio. b) Las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones. c) El tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resultaría innecesaria o imposible.

3) El tribunal arbitral cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales, salvo lo dispuesto en el artículo 33 y en el numeral 4) del artículo 34.

- Laudo definitivo (art. 32).
- También por orden del tribunal:

Cuando se retiro de la demanda (desistimiento, una vez notificada la demanda). Excepción: rebeldía del demandante (art. 25.a) que no interpone demanda dentro de plazo.

No es lo mismo retiro que desistimiento de la demanda, porque el desistimiento procede cuando ella ya se ha notificado. Si la parte ya tomó conocimiento de la demanda lo lógico es que se de traslado para que manifieste su acuerdo.

- Mutuo acuerdo.
- Prosecución del juicio es innecesaria o imposible a juicio del tribunal.

b) Cese de funciones del tribunal (art. 33): cuando termina las actuaciones arbitrales. Excepciones:

- Corrección del laudo (como el recurso de aclaración).
- Interpretación del laudo (un punto o parte concreta), previa petición de las partes.

c) Laudos adicionales (art. 33.3).

- Definiciones. Respecto de reclamaciones que no hayan sido resueltas, es decir, que son omitidos en el laudo.
- Admisibilidad en el arbitraje internacional y en LACI.

Artículo 33 LACI.- Corrección e interpretación del laudo y laudo adicional.

1) Dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, salvo que las partes hayan acordado otro plazo: a) Cualquiera de las partes podrá, con notificación a la otra, pedir al tribunal arbitral que corrija en el laudo cualquier error de cálculo, de copia o tipográfico o cualquier otro error de naturaleza similar. b) Si así lo acuerdan las partes⁵, cualquiera de ellas podrá, con notificación a la otra, pedir al tribunal arbitral que dé una interpretación sobre un punto o una parte concreta del laudo. Si el tribunal arbitral estima justificado el requerimiento, efectuará la corrección o dará la interpretación dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud. La interpretación formará parte del laudo.

2) El tribunal arbitral podrá corregir cualquier error del tipo mencionado en la letra a) del numeral 1) de este artículo por su propia iniciativa dentro de los treinta días siguientes a la fecha del laudo.

3) Salvo acuerdo en contrario de las partes, dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, cualquiera de las partes, con notificación a la otra parte, podrá pedir al tribunal arbitral que dicte un laudo adicional respecto de reclamaciones formuladas en las actuaciones arbitrales, pero omitidas del laudo. Si el tribunal arbitral estima justificado el requerimiento, dictará el laudo adicional dentro de sesenta días.

4) El tribunal arbitral podrá prorrogar, de ser necesario, el plazo en el cual efectuará una corrección, dará una interpretación o dictará un laudo adicional con arreglo a los numerales 1) ó 3) de este artículo.

5) Lo dispuesto en el artículo 31 se aplicará a las correcciones o interpretaciones del laudo o a los laudos adicionales.

En resumen, terminadas las funciones del tribunal, aún mantiene cierta competencia (art. 32.3).

a) El tribunal puede volver a revisar su laudo, una vez recibido por las partes:

a.1 Corrección del laudo:

- Error de cálculo.
- Error de copia o tipográfico.
- Otro error de naturaleza similar.

a.2 Interpretación del laudo:

- Limitado a un punto o parte concreta del laudo

Plazo: 30 días siguientes a la recepción del laudo.

La posibilidad de corrección y de interpretación exige el respeto del principio de contradicción.

Interpretación sólo es posible si las partes lo han acordado.

El tribunal resuelve en 30 días desde la recepción de la solicitud. La interpretación formará parte del laudo.

b) También puede de oficio corregir en los 30 días siguientes al fallo.

c) Laudos adicionales:

- Plazo para solicitarlo: 30 días.
- Notificación a la otra.

⁵ Pareciera ser que el requerimiento de interpretación debe estar determinado ex ante por las partes en la determinación del procedimiento.

- Se pide por las partes cuando el tribunal ha omitido en el laudo reclamaciones ventiladas en el juicio.
- Condiciones y plazo para dictarlo: justificación del requerimiento y 60 días

El tribunal puede prorrogar los plazos para corregir, interpretar o dictar un laudo adicional. Forma: las mismas del artículo 31.

7.20 Impugnación del laudo

Por regla general sólo procede la petición de nulidad (único recurso). El TC, sin embargo, ha determinado que procede el recurso de queja (que procedería contra la sentencia de la CA que resuelve el laudo).

El recurso de queja tiene un plazo de 5 días pero el de nulidad tiene un plazo mayor entonces presentar queja podría no ser beneficioso porque por la teoría de los actos propios después no podría anular. Ahora, **para este curso SOLO PROCEDE anulación.**

Hubo una sentencia reciente que declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación porque la voluntad de las partes no puede exceder la ley. Solo correspondería el recurso de anulación contra el laudo arbitral pero se dedujo recurso de queja. La Corte rechazó la queja porque no había manifiesta falta o abuso pero de oficio modifica la sentencia que declara inadmisibile el recurso, fundado en el consentimiento de las partes para permitirles la apelación. Entonces se remite el laudo a la CA para que conozca de la apelación.

El tema es que el recurso de anulación no busca conocer de los hechos y del derecho.

Características y causales

- a) Plazo máximo de 3 meses contados desde la recepción del laudo. Son plazos individuales.
- b) Tribunal competente: Corte de Apelaciones.
- d) Causales señaladas en el art. 34 N.º 2. Son de dos especies:

d.1 Condiciones de admisibilidad (a probar por la parte que interpone el recurso) (art. 34.2.a).

1) Problemas con el acuerdo de arbitraje.

- Por causa de una de las partes (incapacidad o sin facultades). No se ha aceptado como causal de anulación que el abogado tenga facultades expresas, porque le he dado la creencia a la contraparte de que tenía suficientes facultades.
- Validez según la ley aplicable al acuerdo (aplican también cláusulas patológicas). En subsidio, validez según la ley chilena.

2) Falta de debida notificación de la designación del árbitro, o de actuaciones arbitrales o porque no ha podido hacer valer sus derechos (falta de emplazamiento).

3) Laudo abarca controversias no previstas en el acuerdo o exceden sus términos.

Posibilidad de anular parcialmente respecto de cuestiones no sometidas al acuerdo.

4) Problemas con la composición del tribunal.

d.2 Condiciones de admisibilidad de comprobación de la CA (art. 34.2.b). Pueden no haber sido alegadas por las partes.

1) Inarbitrabilidad de la controversia.

2) El laudo es contrario al orden público **de Chile** (debiera ser orden público internacional, no limitarse únicamente en Chile).

Elementos especiales

- Plazo: 3 meses desde la recepción del laudo o de la resolución del art. 34.3.
- Posibilidad de suspender la tramitación de la nulidad (art. 34.4).
- Preferencia en la vista de la causa (art. 34.5).

7.21 Reconocimiento de las sentencias arbitrales

- La ley chilena reconoce la validez de las sentencias arbitrales extranjeras.
- Antes de la Ley de arbitraje comercial internacional:
 - a) Aplicación de normas del CPC de reconocimiento de sentencias extranjeras: artículos 242 y sigs.
 - b) Aplicación de la Convención de NY de 1958 y Convención de Panamá de 1975.
- Después de la LACI
 - a) Se siguen aplicando normas del CPC. Críticas: No tiene mucho sentido, que se pase por un nuevo control exequátur por la CS, lo mejor sería que el laudo sea título ejecutivo.
 - b) Introduce normas equivalentes a la CNY en los arts. 35 y 36.

Artículo 35 de la LACI

En principio, se replican las normas de la CNY. Pero el problema es que si revisamos el artículo y las normas interpretativas de la CNY, lo que se trató de hacer fue evitar un doble exequátur.

La interpretación de Bordachar es que el laudo ejecutoriado podría constituir título ejecutivo: no tiene sentido el exequátur conocido por la CS porque debemos darle movilidad a una sentencia que posiblemente ya fue revisada por el tribunal de la anulación (sobre todo si este laudo se dictó en Chile).

Artículo 35 LACI.- Reconocimiento y ejecución.

1) Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, será reconocido como vinculante y, tras la presentación de una petición por escrito al tribunal competente, será ejecutado en conformidad con las disposiciones de este artículo y del artículo 36.

2) La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original debidamente autenticado del laudo o copia debidamente certificada del mismo, y el original del acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 7º o copia debidamente certificada del mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuviera redactado en un idioma oficial de Chile, la parte deberá presentar una traducción debidamente certificada a ese idioma de dichos documentos.

Artículo 36 de la ley 19.971

“ARTÍCULO 36.- Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución

- 1) Solo se **podrá** denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado:
 - a. A instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando esta parte pruebe ante el tribunal competente del país en que se pide el reconocimiento o la ejecución:”
 - i. Incapacidad de parte o invalidez del acuerdo arbitral.
 - ii. Violación al debido proceso.
 - iii. Ultra petita.
 - iv. Disociación entre acuerdo de partes y procedimiento arbitral.
 - v. ***Laudo “prematureo” o nulo (según tribunal de la sede de arbitraje).*** *Aplica la teoría de la localización.* Hubo un caso en Chile que en relación con un laudo prematuro se concedió el exequátur porque estaba pendiente y no había sentencia definitiva sobre la anulación (teoría de la deslocalización).
 - b. Cuando el tribunal compruebe:
 - i. Que, según la ley de Chile, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; o
 - ii. que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios al orden público de Chile.
- 2) Si se ha pedido a un tribunal de los previstos en el inciso v) del apartado a) del párrafo 1) del presente artículo, la nulidad o la suspensión del laudo, el tribunal al que se pide el reconocimiento o la ejecución podrá aplazar, si lo considera procedente, su decisión y, a instancia de la parte que pida el reconocimiento o la ejecución del laudo, podrá también ordenar a la otra parte que dé garantías apropiadas.”

Mecánica o lógica del reconocimiento y la ejecución de laudos

- Art. 247 del CPC: competencia a la Corte Suprema para r/e.
- Arts. 242 y 246 CPC. remiten a CNY.

(1) Tratado internacional, (2) sino reciprocidad (norma propia del DIPRI) y (3) análisis de fondo si se cumplen los deberes del debido proceso.

- Art. I CNY: “laudos extranjeros”, se refiere al r/e de laudos arbitrales extranjeros.
- Art. V CNY: causales de denegación de r/e.
- Art. 36 Ley 19.971. Ahora, Bordachar cree que primero aplica la LACI, luego la CNY y finalmente el CPC.

CNY no se aplica a decisiones cautelares, según Corte Suprema.

CAPÍTULO X: Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales internacionales (clase Valeria Galíndez)

En Chile la LACI es una reproducción de la Convención de NY en materia de anulación y de reconocimiento/ejecución de laudos extranjeros o internacionales.

1. Finalidad de los procedimientos de reconocimiento y ejecución

1.1 Finalidades generales

a) Posibilidad de que haya un control por parte de las cortes de los estados del laudo arbitral. Ese control no es profundo, y hay restricciones en cuanto a qué se puede analizar en materia de reconocimiento y ejecución pero es necesario para garantizar que durante el procedimiento arbitral (en que los árbitros no necesariamente son abogados o no son especialistas en el derecho aplicable) haya un control del resultado de que al menos los principios esenciales de debido proceso y contradictorio se han respetados, además del OP.

Este control puede tener lugar tanto en el reconocimiento como en la ejecución.

b) Legitimación del sistema porque a través del reconocimiento o ejecución de un laudo en una jurisdicción distinta en la que se dicta, trae consigo que el laudo arbitral tenga un tránsito mucho más flexible y rápido para fines de eficacia del procedimiento arbitral.

La ley 19.971 preve justamente, al incorporar reglas consagradas en DIP, la forma de legitimar el arbitraje internacional. Sin esta legitimación el arbitraje internacional podría ser inocuo.

c) Colaboración con el tribunal arbitral. Hay situaciones que el tribunal puede dictar una interlocutoria y es necesario reconocer o ejecutar estas resoluciones durante el procedimiento. Si el sistema no funciona de una forma que permita que eso ocurra, eso puede crear problemas para el árbitro que sigue actuando. Entonces, hay una relación horizontal con el tribunal de colaboración.

1.2 Finalidades específicas

a) Reconocimiento y ejecución son procedimientos autónomos y tienen objetivos diferentes. Si bien la ejecución requiere de un reconocimiento previo, el reconocimiento no requiere de una ejecución.

En Chile la CS reconoce y la ejecución la hace otro tribunal, pero en otros países el mismo tribunal cumple con ambas funciones (sobre todo en el common law).

b) Reconocimiento o exequátur: es el control de la introducción de la decisión a un determinado país; tiene naturaleza meramente declaratoria. En Brasil lo hacía la Corte Constitucional pero esto pasó a la última instancia en materia infra constitucional.

c) Ejecución: obligar el cumplimiento del laudo. Sin reconocimiento, normalmente no hay ejecución.

2. Marco legal

a) Ámbito internacional. La principal es la CNY de 1958 y estar vinculado a este estatuto es una señal de desarrollo del ámbito arbitral de un país.

b) Ámbito local. Tenemos dos sistemas legales: la ley del país en que se pide el reconocimiento/ejecución y la ley del país de origen.

Hay una discusión internacionalmente sobre la deslocalización del arbitraje, es decir, que el arbitraje internacional no estaría bajo ningún sistema jurídico pero en realidad esta teoría no cabe. Hoy en día los laudos y el arbitraje internacional siguen vinculados a algún sistema legal, lo que se origina en la necesidad de controlar los laudos internacionales porque sin sistema legal ese control pierde su punto de referencia.

La CNY en su artículo 6.1 prevé que los sistemas legales nacionales contengan reglas propias para e/r de laudos. Pero la ley dice que esos sistemas no pueden ser más gravosos para quien quiere hacer reconocer o ejecutar el laudo; mientras más flexible el sistema, más favorable.

El sistema Francés es un sistema muy flexible para el reconocimiento y ejecución de laudos internacionales.

c) Arbitraje de inversión. Aplica la Convención de Washington de 1965 (sistema propio para arbitrajes bajo el Convenio CIADI). Hay eliminación de sistema reconocimiento entonces hay una ejecución directa.

3. Régimen de la CNY

3.1 Generalidades

a) Aplicación a todos los laudos “extranjeros” (con independencia de la sede). Todo depende de cómo el sistema legal del estado receptor trata un laudo extranjero, por ejemplo, bajo el derecho Chileno hay requisitos para la aplicación de la ley de arbitraje internacional que no solo tiene que ver con la sede o nacionalidad de partes. Pero en Brasil, el criterio para considerar un laudo como extranjero tiene que ver únicamente con la sede.

La CNY no define qué es extranjero y remite al sistema legal del país receptor.

b) No define qué es sentencia (laudo): aplicación de las normas del país firmante. Esto genera discusiones prácticas, por ejemplo si una resolución de medida cautelar califica o no como sentencia.

c) Posibilidad de restricción del campo de aplicación. Algunos países exigen reciprocidad y carácter comercial del laudo, por aplicación del artículo 1.3 de la CNY.

d) Primacía de reglas más favorables (art 7.1 CNY). Se aplican las normas más favorables, e incluso puede haber un híbrido. Entonces, aplicar un sistema legal no conlleva ignorar totalmente la CNY.

3.2 Tipos de reglas

Dos tipos de regla:

- a) Procesales.
- b) Fondo.

Dos fuentes para la denegación:

- a) Oposición de parte.
- b) De oficio.

3.2.1 Reglas procesales

a) Para el estado receptor.

a.1 Artículo 3: Total libertad para establecer el procedimiento de e/r, pero esto sin imponer reglas más rigurosas o costos más elevados de los aplicables a sentencias nacionales. Si la condición es más rigurosa o más cara, debe prevalecer el sistema más favorable.

Brasil dejó de exigir exequátur para cualquier tipo de laudo en los 90. En Francia se concede exequátur inmediatamente y luego recién se traslada a la contraparte para que pueda oponerse, lo que demuestra que es un país con un sistema muy flexible.

***Artículo III CNY.** Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes. Para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la presente Convención, no se impondrán condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas más elevados, que los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales.*

a.2 Artículo 4: carga de la prueba de autenticidad del laudo es de la parte demandante en cuanto a la existencia y la autenticidad del laudo.

Hasta la CNY la carga de la prueba era de la parte que demandaba r/e, que debía probar la existencia del laudo y su validez. Pero hoy en día el laudo arbitral es reconocido como un título ejecutivo.

***Artículo IV CNY 1.** Para obtener el reconocimiento y la ejecución previstos en el artículo anterior, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución deberá presentar, junto con la demanda:*

- a) El original debidamente autenticado de la sentencia o una copia de ese original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad;*
- b) El original del acuerdo a que se refiere el artículo II, o una copia que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad.*

2. Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un idioma oficial del país en que se invoca la sentencia, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución de esta última deberá presentar una traducción a ese idioma de dichos documentos. La traducción deberá ser certificada por un traductor oficial o un traductor jurado, o por un agente diplomático o consular.

Entonces:

1. Inversión histórica de la carga de la prueba.
2. Laudo constituye un título ejecutivo.
3. Autenticación esencial para comprobar la integridad del laudo.

4. Posibilidad de presentar documentos en otro momento. Muchos países permiten que las partes presenten una copia del laudo traducida y una prueba del CNY, y luego que se produzca la prueba de autenticación del laudo.
5. Juez no puede analizar la existencia y validez del convenio, de oficio.

a.3 Artículo 5: la parte demandada tiene la carga de la prueba que se opone al r/e. Antes esta carga la tenía la parte demandante pero actualmente se presume que el laudo existe y es válido.

b) Para el estado de origen (sede).

b.1 No se exige doble exequátur. No debe ser reconocido primero en el estado de origen y luego en el estado receptor.

b.2 Art 5.1.e: La decisión debe ser obligatoria (es causal de denegación de la solicitud de r/e). Pero no se define qué es “obligatoria”. El enfoque más aceptado es aquél que se rige por las normas del país de origen.

No se habla de sentencia sino de decisión porque no solo hay sentencias.

Laudos parciales, decisiones cautelares y laudos finales pueden ser considerados como sentencias obligatorias y por lo tanto r/e en algunas jurisdicciones. Antiguamente en Brasil no se aceptaba la ejecución o el reconocimiento de laudos parciales (laudo final sobre parte del litigio sometido a arbitraje).

El gran problema es en relación a decisiones cautelares (interlocutorias). Por ejemplo, en materia de producción de pruebas hay resoluciones de naturaleza procesal que son finales y una parte puede querer que sea reconocida en otro estado. Imaginemos que se producen documentos, una parte no los presenta y el árbitro dicta una resolución sobre producción de documentos obligando a la parte a presentarlos. La otra parte podría querer r/e esa decisión.

Recordemos que en cuanto a la “obligatoriedad” muchas veces los reglamentos suponen renuncia a recursos pero siempre aplica la anulación entonces la pregunta es si es obligatoria la resolución si está pendiente el recurso de nulidad. Esta es una causal de fondo de denegación de ejecución/resolución, y es claro que si está pendiente un recurso de anulación ello afecta a la obligatoriedad del laudo.

b.3 Artículo 5.1.e y 6: Incidencia de procedimientos de anulación o suspensión en el país de origen.

Hay una discusión doctrinaria de si hay que analizar las causales de anulación o suspensión o si opera esto automáticamente.

El artículo 6 es la puerta para permitir que el procedimiento de r/e siga adelante mediante una garantía apropiada.

Artículo VI CNY. *Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el artículo V, párrafo 1 e), la anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad ante la cual se invoca dicha sentencia podrá, si lo considera procedente, aplazar la decisión sobre la ejecución de la sentencia y, a instancia de la parte que pida la ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que dé garantías apropiadas.*

Algunas consideraciones

1. La CNY NO reconoce la deslocalización del arbitraje: siempre hay contacto con un estado (receptor, de origen o cuya ley es aplicable).
2. Algunas jurisdicciones admiten r/e de laudos anulados, dependiendo de las razones por las que se anuló el laudo (ej. se anuló por la violación de OP y la regla violada no es de OP en el estado receptor). Esto es una doctrina francesa principalmente.

Un caso típico fue en Indonesia en que hubo un contenido político para la anulación del laudo. Las Cortes Americanas entendieron que no podía ser reconocido el laudo que había sido anulado en su país de origen, pero en Francia se permitió su reconocimiento porque el proceso de anulación había sido poco transparente y por lo tanto inválido.

Otro ejemplo podría ser el de una anulación en que hubo corrupción en las cortes estatales de otro país. En Perú se dio el caso contrario, porque en casos de corrupción se anularon todos los laudos dictados por los árbitros.

3.1.2 Reglas de fondo (art 5)

1. El numeral 1 (a-d) tiene las causales que puede invocar la **parte demandada** (el juez, de oficio, no puede hacerlas valer).

Artículo V CNY 1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución:

a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo II estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia; o

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del 10 procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o

c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o

d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje; o

e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia.

a) Invalidez del convenio arbitral.

Hay que probar que las partes estaban sujetas a una incapacidad en virtud de la ley aplicable, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes han sometido (si nada dicen, en virtud de la ley del país donde se dicta la sentencia).

- Se trata de incapacidad pero no de falta de poderes, es decir, se confunden ambos conceptos sobre todo jurisprudencialmente.
- No se define el derecho aplicable al análisis de la capacidad, porque se remite a las reglas del estado de recepción. Ahora, también se puede hacer el análisis dependiendo del estado de origen de las partes o derecho aplicable al caso. La tendencia es considerar las reglas del estado de recepción.
- Importancia del local del arbitraje para la validez del convenio arbitral (ley del local del arbitraje aplica a falta de voluntad de las partes). ¿Debería tener la sede tanta importancia? No necesariamente las partes han considerado que la sede también definiría derecho aplicable al convenio, pero es el criterio que adopta la CNY.

Hay que tener claro que el derecho aplicable al convenio no es el mismo derecho aplicable al arbitraje.

b) Violación al principio contradictorio, es decir, que la parte contra la cual se invoca la r/e no ha sido notificada para la constitución del tribunal o para el procedimiento, o no ha podido hacer valer sus medios de defensa.

- CNY tiene su propio estándar de lo que es considerado principio esencial de contradicción.
- Blinda el arbitraje en caso de que haya una parte que no quiera participar del arbitraje. No cualquier caso supone violación al contradictorio, lo que evita la existencia de “partes terroristas”.
- La parte NO tiene que comprobar perjuicio, es suficiente la violación.
- Se confunde con violación del OP.

c) Extrapolación de los límites de la convención de arbitraje.

- No son laudos con extra o infra petita.
- Estamos hablando de inarbitrabilidad objetiva, esto es, decisiones que extrapolan el objeto del convenio arbitral (no son decisiones que extrapolan solicitudes de las partes cuando el arbitraje ya está iniciado).

d) Irregularidad en la constitución del tribunal o del procedimiento.

- Potencial conflicto entre voluntad de las partes y normas imperativas: ¿qué prevalece? No hay posición clara.
- Ratificación de la importancia que le da la CNY a la sede.
- Potencial conflicto de reglas de anulación con renunciaciones a recursos a través de las partes.

2. Recusación *ex officio*

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución, comprueba:

a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; o

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país.

a) Inarbitrabilidad de la disputa.

Es en el plano internacional, no es lo mismo que la inarbitrabilidad en el plano doméstico.

b) Violación del OP.

Debe ser contrario al OP del país receptor dentro del plano internacional (que solo busca resguardar el sistema jurídico en nivel internacional, distinta de la preocupación que se tienen en el ámbito doméstico con normas de OP).

Se usa como causal “paragua” para dejar de reconocer o ejecutar un laudo, porque las demás causales estarían abarcadas por la noción de OP lo que no es verdad porque estamos ante un concepto de OP internacional. Las partes también invocan el OP como causal adicional a las causales de las letras a) a d), a pesar de que no es una causal que puede invocar la parte.

4. Conclusión

El régimen sobre reconocimiento y ejecución determina igualmente otros conceptos y practicas importantes en materia de arbitraje internacional.

El local de arbitraje sigue teniendo gran importancia.

Sistema simplificado que ha funcionado bien.